

제22장

사건관리 및 변론의 진행

-
- 제1절 사건관리방식 486
 - 제2절 답변서 미제출 사건의 처리 503
 - 제3절 답변서 제출 사건에 대한
기록심사 511
 - 제4절 변론준비절차 518
 - 제5절 변론기일의 운영 584
 - 제6절 집중증거조사 618
 - 제7절 소송절차의 정지 631
 - 제8절 회생·파산이 민사소송에 미치는
영향 649

제1절 사건관리방식

1. 총 설

1960년 민사소송법 제정 이래 오랫동안 유지되어 온 우리 민사재판의 사건처리방식은 한 사건에 대하여 여러 차례의 기일이 열리고, 법정이 개정되는 날에는 여러 건의 사건이 한꺼번에 기일이 지정되는 이른바 ‘분산·병행 심리방식’이었다. 즉, 당사자들이 더 이상 제출할 주장과 증거가 없다고 하거나 혹은 판사의 입장에서 사건이 너무 지연되어 일단 변론을 종결할 필요성이 있다고 판단할 때까지, 불연속적인 기일을 주로 1달 단위로 진행하는 경우가 일반적이었다. 전체적으로 심리는 서면주의에 의존하였고, 심리의 핵심은 ‘변론’이 아니라 ‘기록’에 있었으며, 당시의 심리는 ① 분산화된 병행심리, ② 변론의 형해화, ③ 형식화된 증인신문, ④ 재판부의 사건 장악력 부족, ⑤ 변론종결 후 서면에 의한 심증형성으로 특징되었다.

이러한 종전의 심리모델은 개혁의 요구에 직면하게 되었는데, 급격한 사건 증가와 소송의 복잡화·전문화 경향 또한 효율성의 측면에서 개선을 불가피하게 만들었다. 종전 심리방식에 대한 극복노력은 1990년 전후부터 구체적으로 시작되어 1990. 1. 13. 개정된 구 민사소송법 245조는 “변론은 집중되어야 한다.”라고 규정하여 ‘집중심리원칙’을 선언하였고, 1990년 초반부터 2001년까지 집중심리 시범재판부가 확대 지정되었으며, 이러한 흐름은 점차 사건의 분류와 심리계획의 수립, 변론기일 전 쟁점정리, 변론기일에서의 구술토론, 법관의 사건장악력 제고, 법관의 쟁점에 대한 적극적 의견표명 등 심리에서의 법관 주도성 강화의 방향으로 나아가게 되었다.

대법원은 1996년 민사소송법 개정위원회를 구성하고 공청회를 거쳐 1999년 변론준비절차를 통한 서면절차의 선행과 집중적인 구술심리방식을 내용으로 하는 새로운 소송모델을 확정하였다. 그러나 2001. 3. 1.부터 이를 구

체화한 ‘사건관리방식에 관한 예규’가 시행되고, 2002. 1. 26. 민사소송법이 개정되어 2002. 7. 1. 시행됨으로써, 전국 법원에서는 종래의 민사사건 심리방식을 전면적으로 개편하여 새로 구성한 민사사건 관리방식(이하 ‘신모델’이라 한다)이 실시되었다. 신모델은 변론의 집중과 집중된 변론에서의 충실한 심리를 지향하여, 사건관리 측면에서는 분산심리방식에서 집중심리방식으로 전환을 꾀하는 한편 소송심리 측면에서는 종래 소홀하였던 구술심리의 활용을 추구하였다.

신모델의 주요 내용은 2002년 개정 민사소송법 및 민사소송규칙에 반영되었는데, 사건관리 측면에서 종전의 심리방식과 신모델을 비교 요약하면 다음 표와 같다.

[신모델과 종전 심리방식의 비교]

항목	종전 심리방식	신모델
핵심개념	사건처리 (분산·병행심리 관행)	사건관리 개념 도입 (집중심리 지향)
관리의 기준	접수의 시간적 순서에 따른 확일적 진행	사건의 특성에 따른 차별적 관리
관리의 특성	양적 관리 미제사건수 중심	질적 관리 적정처리건수 중심
관리의 대상	기일진행사건 중심의 관리	전체사건 관리
관리의 방법	기록을 통한 점검(off-line)	전산적 관리(on-line)
관리의 개방성	폐쇄적 관리 재판장의 독자적 관리	개방적 관리 참여사무관등의 역할 제고

‘사건관리’란 법관이 사건에 적극적으로 관여하여 절차진행의 주도권을 행사하는 한편 당사자의 소송행위를 조정하고 관리하는 활동을 말한다. 법원이 접수된 사건을 처리한다는 형식적인 측면에서 본다면 종전 심리방식에서도 사건관리가 전혀 없었던 것은 아니다. 그러나 사건관리는 당사자주의에 기반한 미국 민사소송에서의 ‘case management’를 벤치마킹한 것으로 법관의 적극적인 역할을 통하여 소송이 장기화되고 소송비용이 늘어나는 것

을 방지하기 위해 도입된 개념이다. 신모델은 이를 우리 소송실무에 도입하여 종래의 재판구조를 개혁하고자 하였다.

사건관리는 1차적으로 신속하고 경제적인 사건처리를 하기 위함이지만, 그 기본이념은 심리의 충실을 통하여 적절한 재판이 이루어지게 함에 있다. 우리 재판실무에서도 신모델의 사건관리방식이 어느 정도 정착된 이후에는 소송심리방식으로서의 구술주의를 좀 더 충실하게 구현해야 한다는 요구가 대두되었고, 이를 반영하여 당초 제시되었던 신모델에 따른 사건관리방식도 부분적인 변화를 겪었다.

2. 신모델의 주요 내용

2002년 민사소송법 개정 이래 몇 차례 부분적인 민사소송법 개정이 이루어졌으나, 현행 민사소송법 아래에서도 신모델의 핵심 요소는 변함없이 유지되고 있다.

가. 차별화된 사건관리

신모델에서는 우선 다툼이 없는 사건과 다투는 사건, 간단한 사건과 복잡한 사건, 신속처리가 가능한 사건과 신중한 심리가 필요한 사건을 구분하여 그 절차진행의 경로를 다르게 함으로써 유형별로 사건관리방식을 차별화하였다.

나. 서면절차와 구술절차의 명확한 구분

신모델에서는 법정에서 진행되는 구술절차와 법정 밖에서 진행되는 서면절차를 명확하게 구별하여 그 특성이 분명하게 드러나도록 운영방식에 반영하였다. 이에 따르면 서면절차만으로 충분한 소송행위는 서면절차 안에서 완결되도록 하고, 아울러 서면공방은 1:1의 대응관계를 명확하게 유지하면서 진행되게 함으로써 불필요한 주장의 반복 또는 쟁점에서 벗어난 공방이

이루어지지 않도록 하였다. 그 대신 구술절차는 그 횟수를 최소화하되 일단 열리면 내용이 있는 실질적인 변론이 이루어지도록 여러 가지 제도적 장치를 마련하였다.

다. 서면공방의 선행

2002년 개정 당시의 민사소송법은 모든 사건에 대하여 변론준비절차를 거치는 것을 원칙으로 하고 있었다(구 민소 258조 1항). 그러나 이 원칙을 실무에 구체적으로 어떻게 적용할 것인가 반드시 분명한 것은 아니었다. 우선 소장이 접수되면 가능한 한 빠른 시기에 첫 변론기일을 지정하여 진행을 한 후 변론준비절차 회부 여부를 결정하는 이른바 ‘조기1회기일 방식’이 있을 수 있고, 반대로 첫 변론기일 이전에 서면에 의한 변론준비절차를 먼저 거치는 ‘서면공방선행 방식’이 있을 수 있다. 초기의 신모델은 그중 서면공방선행 방식을 원칙으로 하였다. 이는 모든 사건을 조기1회기일 방식으로 진행하기에는 각 재판부의 보유 사건수가 적정수준을 초과한 경우가 대부분이라는 현실여건의 제약을 감안한 것이지만, 효율성 측면에서도 서면공방선행 방식이 더 우월하다고 본 데 따른 것이다.

그러나 그 후 신모델이 실무에 정착됨에 따라, 2008. 12. 26. 개정된 현행 민사소송법 258조 1항은 아래 3.에서 보는 바와 같이 변론기일 지정방식을 원칙으로 채택하였다.

라. 재판기일의 최소화

서면공방선행 방식의 심리가 효과적으로 진행된다면, 법원에서 열리는 재판기일은 원칙적으로 쟁점정리기일과 증인신문을 주목적으로 하는 집중증거조사기일의 2회로 압축될 수 있다. 민사소송법에서도 “법원은 변론준비절차를 마친 경우에는 첫 변론기일을 거친 뒤 바로 변론을 종결할 수 있도록 하여야” 하고(민소 287조 1항), “증인신문과 당사자신문은 당사자의 주장과 증거

를 정리한 뒤 집중적으로 하여야 한다.”라고 규정함으로써(293조), 재판기일의 최소화 및 집중적 운영의 방향을 분명히 하고 있다.

마. 주장·증거의 적시제출

2002년 개정 민사소송법은 “공격 또는 방어의 방법은 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하여야 한다.”라고 하여(민소 146조), 구법의 수시제출주의(구 민소 136조)를 적시제출주의로 전환하였고, 변론준비기일이 종결되면 원칙적으로 새로운 공격방어방법을 제출할 수 없는 실권효가 생기는 것으로 규정하였으며(민소 285조), 나아가 특정사항에 관하여 주장을 제출하거나 증거를 신청할 기간을 제한할 수 있는 재정기간 제도를 도입하였다(147조).

바. 당사자 본인의 절차 참여 확대

신모델에서는 소송당사자에게 절차진행 과정에 적극 참여하고 법관 면전에서 직접 진술할 수 있는 기회를 최대한 보장함으로써, 법원으로 하여금 분쟁의 실체를 더 정확하게 파악할 수 있는 기회를 가지게 하고, 당사자의 입장에서 하고 싶은 말을 다한 뒤에 법원의 판단을 받았다는 절차적 만족감을 느끼게 하여 재판에 대한 신뢰와 승복률을 높이도록 하였다. 예컨대 소송대리인이 선임되어 있는 경우에도 필요한 때에는 쟁점정리기일에 당사자 본인을 출석하게 하여 말로 진술할 기회를 부여하고(민소 282조 1항, 민소규 29조의2 참조), 집중증거조사기일에도 당사자 본인이 증인탄핵이나 대질신문 과정에 적극 참여하도록 하였다.

사. 증거조사의 효율화

신모델에서는 2002년 개정 민사소송법이 정한 증거의 적시제출(민소 146조)과 증거조사의 집중(293조)을 기본골격으로 하여, 증인 및 당사자신문 이외의 모든 증거조사는 서면공방 과정 또는 쟁점정리기일까지 마치는 것을

원칙으로 하고, 증거조사의 효율성과 실효성을 높이기 위하여 다각적인 방안을 마련하였다.

아. 판결 이유 구성의 다양화

신모델은 심리의 충실과 사법에 대한 국민의 신뢰를 지향하는 것이므로, 판결서의 작성에 소요되던 노력과 시간을 심리의 충실로 전환하고, 판결서는 가능한 범위에서 쟁점 위주로 실시함으로써 당사자에 대한 답변기능을 증시하는 방향으로 바뀌어야 한다. 이러한 내용을 반영하여, 종래에는 판결서의 이유에 당사자의 주장과 공격방어방법 ‘전부에 관하여’ 판단하도록 규정하였으나(구 민소 193조 2항), 2002년 개정 민사소송법은 “주문이 정당하다는 것을 인정할 수 있을 정도로” 판단을 표시하면 되는 것으로 규정하였다(민소 208조 2항).

자. 화해·조정에 의한 분쟁해결의 확대

신모델은 쟁점정리기일 또는 변론종결 단계에서 재판부가 가진 심증을 소송당사자에게 표명하여 적극적으로 화해를 권고하도록 하고, 필요한 경우에는 전문가들의 조력을 받아 분쟁의 화해적 해결을 시도하도록 권장하고 있다.

차. 재판부 개념의 확장과 협동업무 체계의 정립

신모델은 종래의 재판부 개념을 확장하여 소송법상 의미의 법원을 구성하는 법관뿐 아니라 참여사무관등 및 주무관, 속기사까지 포섭하는 넓은 의미의 재판부 개념을 전제로, 사건관리는 그 구성원들의 협동작업에 의하여 진행해 가는 것으로 구성하였다. 이는 법관들이 사건 실체에 대한 판단에 시간을 집중할 수 있도록 여건을 조성하고, 법원의 한정된 인력을 효율적으로 활용하기 위한 것이다.

카. 정보통신기술의 적극적 활용

신모델은 효율적인 사건관리를 위하여 정보통신기술을 적극적으로 활용한 업무지원체계의 구축을 도모하였다. 이에 따라 전자우편을 이용한 기일의 간이통지 및 송달(민소규 45조, 46조, 47조), 소송서류의 전자파일 제출 요청(48조 2항), 인터넷 등 정보통신매체를 통한 공시송달·공고(54조, 142조, 143조), 전자통신매체를 이용한 송달통지 제도(53조), 컴퓨터용 자기디스크·광디스크, 녹음·녹화테이프 등에 저장된 문자정보, 음성·영상자료에 대한 증거조사절차(120조, 121조) 등이 마련되었다.

한편 2020년 초부터 시작된 코로나바이러스감염증-19의 급속한 국내 확산을 막기 위한 사회적 거리두기 정책에 따라 각급 법원에서 상당수 재판이 지연되는 사태가 발생하였는바, 이를 미연에 방지하고 국민의 재판받을 권리를 보장하기 위하여, 재난 등의 사유가 있더라도 적시에 필요한 재판 절차를 진행할 수 있는 방법을 강구할 필요성이 제기되었다. 나아가 최근의 전자통신 및 인터넷 분야 기술의 획기적인 발전은 소송관계인이 직접 법정에 출석하지 않더라도 이른바 ‘비대면’ 방식으로 각종 재판절차를 진행하는 것을 가능하게 하였고, 이는 소송관계인의 편의 증진, 재판 비용 절감, 분쟁 해결의 효율성 제고 등 다양한 장점이 있어 그 이용을 계속 확대하여야 한다는 목소리가 높아졌다. 이에 따라 2021. 8. 17. 민사소송법이 개정되면서, 기존 민사소송규칙에서 영상재판이 인정되던 변론준비기일을 포함하여, 변론기일, 심문기일에서의 영상재판 실시에 관한 법률적 근거가 마련되었다. 즉, 재판장·수명법관 또는 수탁판사가 상당하다고 인정하는 때에는 당사자의 의견을 들어 변론준비기일 또는 심문기일을 영상재판으로 열 수 있도록 하였다(민소 287조의2 1항). 또한 교통의 불편 또는 그 밖의 사정으로 당사자가 법정에 직접 출석하기 어렵다고 인정하는 때에는 당사자의 신청을 받거나 동의를 얻어 변론기일을 영상재판으로 열 수 있도록 하되, 이 경우 심리의 공개에 필요한 조치를 취하도록 하였다(287조의2 2항). 아울러 감정인신문에

서만 허용되던 인터넷 화상장치를 증인신문에서도 이용할 수 있도록 하였다(327조의2 1항).

3. 구술심리 강화와 사건관리방식의 변화

신모델은 충실한 심리로 민사재판에 대한 국민의 신뢰를 증진함을 목표로 삼았으나, 이를 실질적으로 달성하기 위해서는 법정에서의 구술심리를 더 강화하여야 한다는 요청이 대두되었다. 민사소송법(2008. 12. 26. 법률 제 9171호) 개정, 2차례에 걸친 민사소송규칙(2007. 11. 28. 대법원규칙 2115호 및 2009. 1. 9. 대법원규칙 2203호) 개정, 사건관리방식에 관한 예규(2009. 12. 30. 재판예규 1292호) 개정 등은 이러한 요청에 따른 사건관리방식의 변화를 가져왔는데, 그 주요내용은 아래와 같다.

가. 초기 사건분류와 초기 기일지정

현행 민사소송법은 원칙적으로 2회의 서면공방을 선행시켰던 초기 신모델과 달리, 다투는 취지의 답변서가 제출되면 바로 재판장이 기록을 검토하여 기일을 지정하는 초기 사건분류 내지 초기 기일지정을 원칙으로 한다(민소 258조 1항, 민소규 69조 1항, 사건관리예규 9. 가.). 기계적인 서면공방 선행이 오히려 쟁점을 분산시키고 당사자에게는 불필요한 감정적 대립을 유발하며 재판부에게는 기록 검토의 부담을 가중시킬 우려가 있기 때문이다.

나. 변론기일 방식에 의한 구술심리 원칙

신모델에서 쟁점정리기일은 법관과 양쪽 당사자가 최초로 대면하여 사건에 관하여 공방을 펼침으로써 구술주의의 원칙을 구현하는 기일인데, 변론기일이 아닌 변론준비기일 방식이 원칙이었다. 그러나 수명법관이 진행하는 변론준비기일에서 실질적인 구술공방이 이루어지는 경우 공개주의나 직접주의에 반한다는 비판을 받을 우려가 있다. 현행 민사소송규칙은 변론기일과

변론준비기일의 기능을 준별하고 있으며(민소규 28조, 70조의2), 2008. 12. 26. 민사소송법 개정, 2009. 1. 9. 민사소송규칙 개정을 통하여 변론기일 방식을 기일 운영의 원칙적인 형태로 채택하였다(민소 258조 1항, 민소규 69조 1항).

다. 변론준비절차의 신속화·내실화

현행 민사소송법은 변론기일 방식의 구술심리를 원칙으로 채택하고 있지만, 변론준비절차에 부칠 필요가 있는 사건이 여전히 있음은 물론이다(민소 258조 1항 단서, 279조 2항). 다만 이러한 경우에는 신속하고 내실 있는 변론준비가 이루어지도록 유의할 필요가 있다. 재판장은 사건의 신속한 진행을 위하여 필요한 때에는 사건을 변론준비절차에 부침과 동시에 변론준비기일을 정하고 기간을 정하여 당사자로 하여금 준비서면, 그 밖의 서류를 제출하게 하거나 당사자 사이에 이를 교환하게 하고 주장사실을 증명할 증거를 신청하게 할 수 있다(민소규 69조 3항). 재판장은 변론준비절차에서 변론의 준비에 필요한 각종 사항에 관하여 미리 내실 있는 절차협의를 함으로써(70조 3항 내지 5항) 변론의 집중을 실질적으로 도모할 수 있다.

라. 차별적 집중구술심리와 유형별 사건관리

2002년 개정 민사소송법을 통해 당사자는 소송에 대하여 법원에서 변론하여야 한다는 규정이 도입되었고(민소 134조 1항), 2007. 11. 28. 민사소송규칙 개정을 통해 변론은 당사자가 말로 중요한 사실상 또는 법률상 사항에 대하여 진술하거나 법원이 당사자에게 말로 해당사항을 확인하는 방식으로 하도록 하였다(민소규 28조 1항). 다만 변론은 서면으로 준비하여야 한다는 규정도 여전히 존재하므로(민소 272조 1항), 결국 민사소송법은 심리의 효율과 집중을 위해 미리 제출한 서면에 의하여 구술주의를 보완하도록 하고 있다고 볼 수 있다.

구술심리 강화를 위해서는 시차제 소환은 물론이고 주 2회 기일지정 등을 통하여 구술심리의 양적 확대를 도모함이 바람직하나, 한편으로는 사안의 복잡성이나 난이도에 따라 개개 사건별로 법정 심리시간에 다양한 편차가 생길 수밖에 없다. 특히 난이도가 높은 소수의 사건에 대하여는 충분한 시간을 할애하고 시각적 자료를 활용하는 등 구술심리의 질적 향상을 꾀할 필요가 있다. 나아가 다양한 전문분야의 사건, 전국 어디에서나 빈발하는 전형적인 사건, 지역별로 자주 등장하는 사건 등의 경우에는 자주 나타나는 쟁점, 통상 제출되는 증거방법이나 심리의 애로사항 등을 사건유형별로 미리 확인하여 두었다가 이를 심리계획 수립에 반영하는 것도 필요하다.

마. 전자소송 도입과 전자적 사건관리

‘민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률’이 2011. 5. 이후 민사재판절차에도 적용되었다. 재판부는 전자기록사건을 처리할 때 전자소송 시스템을 통하여 사건관리에 필요한 각종 정보를 더 신속하게 추출하여 이용할 수 있게 되었다.

한편 법원행정처는 장기간에 걸쳐 분산 구축된 노후 재판사무 및 전자소송 시스템을 전면적으로 재구축하는 ‘차세대전자소송 시스템 구축사업’을 진행하여 2025. 1. 31. 새로운 전자소송시스템을 개통하였다. 이로써 전자적 사건관리를 위한 물질 기반이 새롭게 다시 확립되었다.

4. 제1심 집중과 항소심 심리방식의 변화

법적 분쟁의 신속한 해결과 그로 인한 당사자들의 사회경제적 부담 및 국가 전체적인 사법비용의 감소, 한정된 사법자원의 합리적 이용 등을 위해서는 가급적 사실심에서, 그중에서도 제1심에서 사건을 마무리하는 것이 바람직하다는 데 이론의 여지가 없다. 구술심리 방식이 민사재판 실무에 어느 정도 정착 단계에 들어선 2010년대 중반을 기점으로 그동안의 신모델 및 구

술심리 시행성과를 바탕으로, 소송을 제1심에서 종국적으로 해결할 수 있도록 제1심의 역량을 강화하고, 이를 기초로 사실상 제1심의 반복과 같은 형태로 이루어지던 항소심 심리방식을 개선해야 한다는 움직임이 두드러지게 나타났다. 현행 사건관리방식에 관한 예규는 이를 반영하여 “재판장은 제1심에서 청구취지와 청구원인이 분명하게 정리되고, 이와 관련된 증거조사도 완료될 수 있도록 노력하여야 한다.”라는 제1심 집중의 원칙을 명시하는 한편(15-2항), 이를 구체화하기 위한 규정들을 두고 있다. 제1심 집중 및 항소심 심리방식의 변화와 관련된 주요 내용은 아래와 같다.

가. 충실한 쟁점정리를 반영한 청구의 확정

제1심의 쟁점정리 과정에 재판부가 적극적으로 개입하여 당사자 사이에 다툼이 있는 사항을 사건 초기에 정리하되, 처음부터 쟁점을 지나치게 단순화하거나 필수적 쟁점만을 추출·정리할 것이 아니라, 당사자의 주장을 기초로 다툼이 있는 사항을 폭넓게 쟁점화한 후 당사자와 토론을 거쳐 압축하고, 쟁점정리 과정에서 당초의 청구에 포섭되지 않는 새로운 쟁점이 나올 경우 변론주의를 침해하지 않는 범위에서 석명권 행사 및 적절한 소송지휘를 통해 청구취지 및 청구원인 변경을 위한 기회를 부여한다.

나. 충실한 증거조사를 위한 사전 절차협의를 강화

절차협의를 증거제출 기회에 대한 통제보다는 증거제출 기회를 시기적으로 놓치지 않도록 사전에 설명·배려한다는 관점에서 접근하여, 당사자가 제1심에서 자기책임 아래 충분한 주장·증명을 펼 기회를 부여하도록 한다. 법원은 적극적인 절차협의를 및 그 과정에서의 석명을 통해 당사자가 필요한 증거를 모두 제출할 수 있도록 유도하여 충실한 증거조사를 도모한다.

다. 폭넓은 증거채택

제1심은 항소심에 비해 상대적으로 소송지연의 방지보다는 당사자들의 절차적 만족감을 증진하는 데 주안점을 두고 당사자의 증거신청을 적극적으로 채택하는 방향으로 절차를 운영한다. 이에 따라 증거가치가 별로 없을 것으로 예상된다는 것을 이유로 증거조사의 필요성을 부정하거나 증거신청을 기각하지 않고, 현장검증·감정 등 법원에 부담을 주는 증거라도 증명할 사실과 관련되고 쟁점 판단에 필요하다면 원칙적으로 채택한다.

라. 항소심 심리방식의 개선

제1심은 중국적 분쟁해결기능을 강화하고, 항소심은 원칙적으로 제1심 심리의 당부를 판단하는 방식으로 사실심 심급구조를 재편하는 것이 바람직하다. 이를 위해 항소심에서는 제1심과 차별화된 방식으로 사건관리를 하여 집중심리를 통해 변론기일을 최소화하고 심리기간을 단축한다. 또한 당사자들에게 실질적인 구술변론의 기회를 부여하고, 항소이유를 중심으로 한 판결서의 답변기능을 강화하는 데 중점을 둔다.

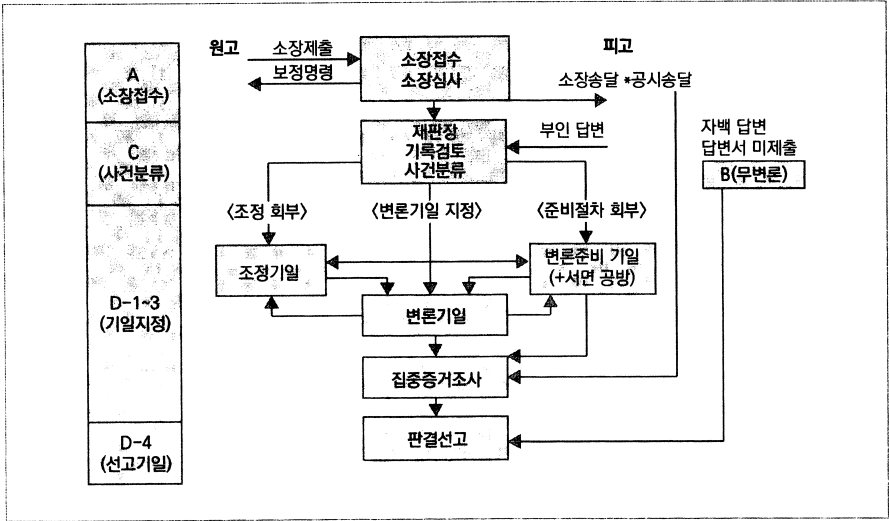
제22장

사건관리
및
변론의
진행

5. 표준적인 사건관리의 개요

현행 민사소송법 아래에서의 표준적인 사건관리 및 심리구조의 개요는 아래에 있는 [사건관리 개요도]와 같고, 법관 및 참여직원이 사용하는 전산시스템에 표시되는 사건진행단계의 구분은 아래 [진행단계별 사건현황표]와 같다(개요도에 표시된 A 내지 D의 영문표시는 사건현황표에 기재된 각 진행단계의 표시부호에 상응한 것이다).

[사건관리 개요도]



[진행단계별 사건현황표]

진행단계		사건수
A. 소장접수 및 송달사건	A-1-가. 소장심사중	
	A-1-나-①. 보정대기중	
	A-1-나-②. 보정기간도과	
	A-1-나-③. 보정서제출	
	A-1-다. 소장송달대기중	
	A-2-가-①. 일반송달진행중	
	A-2-가-②. 특별송달진행중	
	A-2-나-①. 일반송달불능	
	A-2-나-②. 특별송달불능	
	A-3-가. 주소보정대기중	
	A-3-나. 주소보정기간도과	
	A-3-다. 주소보정서제출	
	A-4. 소장송달완료	
B. 답변서 미제출 사건	B-1. 무변론선고대상 사건	
	B-2-가. 보정대기중	
	B-2-나. 답변서대기중	
C. 재판장 검토 대상 사건	C-1. 답변서제출사건	
	C-2. 공시송달진행사건	

진행단계		사건수
D. 기일이 지정된 사건	D-1. 변론기일지정	
	D-2. 조정/검증/감정기일지정	
	D-3. 변론준비기일지정	
	D-4-①. 일반선고	
	D-4-②. 무변론선고	
E. 기일지정 대기사건	E-1. 서면공방	
	E-2. 감정/조회 등 화신	
	E-3. 조정화부된 사건	
	E-4. 관련사건결과	
	E-5. 결정/소취하(소취하간주) 등 확정 여부	
F. 기타	F-1. 공시송달대상사건	
	F-2. 알 수 없는 진행단계	
G. 종국처리된 사건	G-1. 판결로 완결	
	G-2. 조정/화해/소취하/청구포기/인낙/소장각하 명령 등으로 완결된 사건	
	G-3. 이송대기중 사건	
	G-4. 상급심에서 확정되어 반환된 사건	
총계		

제22장

사건관리 및 변론의 진행

가. 소장 심사 및 송달 단계

우선 소장이 접수되면 심사를 하여 특별한 형식적 하자가 없는 한 그 부분을 즉시 상대방에게 송달하고 30일 이내에 답변서를 제출하도록 최고한다. 그 단계에서 소장이 송달불능이 되면 주소보정명령을 하고 결국 공시송달로 처리될 사건은 제1회 변론기일을 지정하여 변론종결이 되도록 운영한다. 이 단계에서 소장송달 및 공시송달 절차가 진행되는 과정까지가 사건현황표의 진행단계상 ‘A. 소장접수 및 송달사건’(공시송달로 처리될 사건의 경우 ‘F-1. 공시송달 대상사건’)으로 분류된다.

나. 사건분류 단계

(1) 기한 내에 답변서가 제출되지 않았거나 자백 취지의 답변서가 제출된 경우에는 일단 무변론판결 대상사건(B)으로 분류된다.

[일반적인 사건관리 방식(예시)]

단계 구분	처리업무 (권장 처리기한)		담당	처리결과
I. 소장 심사	심사의 범위 (배당 후 즉시)	① 당사자표시의 적정 여부 ② 필수 첨부서류(소송위임장 등 각종 자격증명서류, 법인 등기사항 증명서 등) ③ 소송목적의 값 산정과 인지액의 적정 여부 ④ 사물관할, 토지관할, 전속관할의 유무 ⑤ 청구취지 중 누락부분(자연손해금 가산일 또는 별지 등) 유무 ⑥ 청구취지와 청구원인의 부합 여부 ⑦ 기본적 서증의 첨부 여부 ⑧ 소장에 기재된 당사자표시와 전산 시스템에 입력된 내용의 일치 여부 ⑨ 사건유형별 요건사실 등 기타 혐의된 사항	참 여 관	부분발송 지시 소장각하의 대상이 되지 않는 사항에 대한 보정권고(흡결 보완) 발령 - 관할 위반이 분명한 경우 이송결정 초안 작성 후 재판장에게 기록인계 - 소장각하의 대상이 되는 사항에 대한 참여관 또는 재판장 명의의 보정명령 발령 - 소장의 흡결을 보정할 수 없거나 보정 명령을 하였음에도 보정하지 않는 경우 재판장에게 소장각하명령 초안과 함께 기록인계
	소장부분 송달 (보정을 명하는 경우를 제외하고는 배당 후 즉시)	· 송달 실시상황의 점검 · 공시송달 요건의 검토 · 외국송달 사건의 검토 · 다수 당사자 사건의 송달계획의 수립	참 여 관 (실 무 관)	참여관 명의로 주소보정명령 발령 참여관 명의로 공시송달 처분 외국송달 등 기타 송달계획의 건의 및 보고
II. 사건 분류	답변서 미제출 (피고의 지배취지의 답변서 제출 포함) (송달 후 30일)	· 무변론 선고 대상의 추출 · 무변론 선고기일의 지정	참 여 관	무변론 판결 대상 추출 + 판결 초고 작성 선고기일의 지정 건의
	형식답변서 제출 (제출 즉시)	· 실질답변서 제출 촉구	참 여 관	보정권고(실질답변서 제출) 발령 ☞ 보정기한 경과 즉시 변론기일 지정 건의
	실질답변서 제출 (제출 후 7일 내)	· 기록인계 · 사건분류를 위한 기초작업	참 여 관 (실 무 관)	기일지정 가능 일정의 보고 조정화부의 건의

단계 구분	처리업무 (권장 처리기한)	담당	처리결과
II. 사건 분류	실질답변서 제출 (제출 후 7일 내)	재 판 장	기일의 지정 석명준비명령 등의 발령 본인 출석 등의 안내문 발송
III. 1차 기일	- 사건분류의 실시 ① 변론기일/변론준비기일지정 ② 조정화부 - 기일 진행의 준비 - 석명준비명령 or 보정명령/본인 출석 명령 여부	재 판 장	변론/증명 계획서(심리계획서)의 작성 고려 ※ 간단한 경우 조서 기재로 같음
IV. 증거 조사	집중된 증거조사	재 판 장 주심 판사 (참 여 관)	계획심리의 원칙 (진행점검 업무의 위임) 증명계획에 따른 진행상황의 점검 (필요시 보정명령 발령 건의)

(2) 피고가 기한 내에 다투는 취지의 답변서를 제출하는 경우에는 재판장이 바로 기록을 검토하여 사건을 분류하게 된다(C).

그 결과 변론기일 등이 지정되는데(D), 첫 기일은 앞서 살펴본 바와 같이 현행 민사소송법상 원칙적으로 변론기일이 될 것이지만(D-1), 필요한 경우에는 조정절차에 회부되어 조정기일이 지정되거나(D-2), 변론준비절차에 부쳐져 변론준비기일이 지정되기도 한다(D-3).

경우에 따라서는 사건분류 결과 기일을 지정하지 아니한 채 그대로 대기할 수도 있다(E). 재판장이 사건을 변론준비절차에 부쳤으나 변론준비기일을 지정하지 않은 채 석명준비명령 등을 통하여 추가 서면공방을 유도하는 경우(E-1), 검증·감정 등 기일 전에 시행된 증거조사의 결과를 기다리는 경우(E-2), 기일 지정 전에 관련사건의 진행경과를 먼저 살펴야 하는 경우(E-4) 등이 그것이다. 이러한 경우에는 사건처리가 지연 또는 방치되지 않도록 수

시로 점점이 필요하다.

다. 변론기일 이후 단계

(1) 제1회 변론기일(D-1)은 양쪽 당사자와 소송대리인이 법관 면전에서 구술로써 사건의 쟁점을 확인하고 상호 반박의 기회를 가지는 절차이다. 제1회 변론기일은 당사자가 하고 싶은 주장을 충분히 하게 함으로써 재판에 대한 승복률을 높이는 방향으로 운영되어야 한다. 종래 최초 기일을 변론준비기일 방식으로 진행하기도 하였으나, 민사소송법 개정에 따라 원칙적 변론기일 방식으로 전환하였음은 앞서 본 바와 같다. 이와 달리 변론준비기일 방식(D-3)에 의할 경우에는, 합의부에서 재판장 또는 수명법관이 단독으로 절차진행을 할 수 있고, 변론준비기일이 종료되면 그 법적 효과로서 원칙적으로 실권효가 생기게 된다.

(2) 제1회 변론기일 또는 그 이후의 변론기일에서 쟁점정리 및 증거신청 등이 완료되면 그다음 변론기일에는 원칙적으로 집중증거조사가 이루어진다. 사건에 관련된 양쪽 당사자의 증인 및 당사자신문 대상자 전원을 한꺼번에 집중적으로 신문하고, 신문을 마친 사건은 변론을 종결한 후 단기간 내에 판결을 선고한다(D-4).

라. 조정·화해 시도

다툼은 사건에 대해서는 위와 같은 절차진행 과정 중 어느 단계에서든 화해권고결정이나 조정제도를 활용하여 분쟁의 화해적 해결을 시도함으로써(D-2, E-3, E-5), 분쟁을 조기에 종식시키는 것이 바람직하다.

제2절 답변서 미제출 사건의 처리

1. 개 설

답변서 제출기한 안에 답변서가 제출되었는지 여부에 따라 사건은 궤도를 달리하여 전혀 다른 방식으로 후속절차가 진행된다.

먼저, 답변서가 제출되지 아니한 사건(민사소송법 257조 2항에 따라 피고가 청구의 원인이 된 사실을 모두 자백하는 취지의 답변서를 제출하고 따로 항변을 하지 아니한 사건을 포함한다. 이하 같다)은 원칙적으로 무변론판결 대상사건으로 분류하여 바로 선고기일을 지정하며, 무변론판결을 선고할 수 없는 예외적인 경우에는 변론기일을 지정하거나 보정명령을 발령하는 방식으로 후속절차를 진행한다. 민사소송법 257조 3항에 따라 소장부분을 송달하면서 무변론판결의 선고기일을 함께 통지한 사건에 관하여 답변서 제출기한 안에 답변서가 제출되지 아니한 경우에도 이에 준하여 처리한다(이때는 다시 선고기일을 지정·통지할 필요가 없음은 물론이다). 이와 같이 답변서가 제출되지 아니한 사건은 ‘신속한 처리’를 주된 목표로 절차를 진행하여야 한다.

다음으로, 답변서가 제출된 사건은 기록심사를 거쳐 원칙적으로 변론기일을 지정하고, 경우에 따라 변론준비절차에 부칠 사건, 조정에 회부할 사건 등으로 분류한다(민소 258조 1항, 민조 6조). 답변서가 제출된 사건은 효율적인 쟁점정리와 집중증거조사를 통한 사건의 ‘적정한 해결’ 또는 화해·조정을 통한 ‘화해적 해결’ 등을 목표로 절차를 진행한다.

2. 답변서 미제출 사건의 처리

가. 답변서 미제출 사건의 선별 및 기록인계

제출기한 안에 답변서가 제출되지 아니한 사건을 조기에 정확하게 선별하는 것은 참여사무관등과 주무관이 수행하여야 할 중요한 과제 중 하나이다.

참여사무관등은 재판사무시스템을 활용하여 답변서 제출기한 안에 답변서가 제출되었는지를 정기적으로 점검하여야 한다. 점검 결과 제출기한 안에 답변서가 제출되지 아니한 사건에 관하여는 참여사무관등이 소장을 중심으로 기록을 심사하여 무변론판결 선고에 적합한지 여부를 검토한 후 바로 재판장에게 그 검토결과를 보고하고 기록을 인계하여야 한다(사건관리예규 7. 나.).

재판장에게 기록을 인계하는 방식으로는 사유가 발생할 때마다 수시로 인계하는 형태도 가능하지만, 매주 1회 정도 일정한 요일을 정하여 정기적으로 인계하는 방식이 보다 효율적이다. 전자기록의 경우 재판부 구성원 간의 전자기록 인계는 전자소송시스템의 사건진행관리에서 상호 인계하는 방식으로 한다(민전예규 46조 1항).

참여사무관등으로부터 기록을 인계받은 재판장은 기록을 검토한 후, 뒤에서 설명하는 바와 같이 무변론판결 대상사건, 변론기일을 지정할 사건, 변론준비절차나 조정에 회부할 사건 등으로 분류하여 처리하게 된다.

나. 복수의 피고 중 일부가 답변서를 제출하지 아니한 경우의 처리

복수의 피고 중 일부만 답변서를 제출하여 다투는 경우에는 다투지 않는 피고에 대해서는 후속절차의 진행을 일단 유보하였다가, 다투는 피고에 대하여 쟁점정리절차와 증거조사절차를 마치고 선고기일을 지정하는 단계에서 다투지 않는 피고에 대해서도 함께 선고기일을 지정하여 무변론판결로 처리하는 것이 바람직하다. 이러한 경우 피고들 전원에 대하여 바로 변론기일을 지정한 후 답변서를 제출하지 않은 피고에 대해서만 자백간주(민소 150조)로 변론종결을 해 두고, 답변서를 제출하여 다투는 피고에 대해서는 계속 절차를 진행하는 방식도 생각할 수 있으나, 이 방식을 택하게 되면 피고마다 변론기일이 분리되고, 다투는 피고에 대한 심리가 길어질 경우 재판부 구성의 변경으로 인한 변론재개 및 절차 반복 등의 번거로움이 생길 우려가 있다.

다. 다툼 가능성이 높은 사건에서 답변서가 제출되지 아니한 경우의 처리

의료소송, 해고무효확인소송, 국제거래소송, 보험회사를 피고로 하는 손해배상청구소송 등과 같이 특정한 유형의 사건에서는 피고가 답변서 제출기한을 지키지 아니한 경우에도 지정된 선고기일 이전에 답변서를 제출하거나 기일에 출석하여 다툼 가능성이 상당히 높다. 또한 이송된 사건, 조정이 불성립된 조정신청사건, 독촉이의사건, 재심사건, 피고가 국가·지방자치단체인 사건, 관련사건이 다른 재판부에 계속 중인 사건, 기일전 증거신청서가 소장과 함께 제출된 사건 등도 마찬가지이다. 이러한 경우 역시 확실적인 업무처리를 위하여 무변론판결의 선고기일을 지정할 수도 있겠으나, 선고기일 지정이 취소될 가능성이 상당하여 사실상 무용하게 될 것이라면 차라리 신속하게 변론기일을 지정함으로써 피고의 응소준비를 촉진시키는 것이 나을 수 있다.

그러므로 이러한 유형의 사건에 관하여는 굳이 30일의 답변서 제출기한 동안 대기할 필요 없이 소장심사 직후 등 좀 더 이른 시기에 재판장이 기록을 검토하여 기일을 지정함으로써 불필요한 처리 지연을 방지할 수 있을 것이다.

더 나아가, 일반적으로 소장 접수단계에서 분쟁의 배경이나 소송에 이르게 된 경위, 증거관계와 조정·화해의 가능성 등을 파악할 수 있다면 이는 사건관리에 유용한 자료가 될 것이다.

3. 무변론판결

가. 무변론판결의 대상

(1) 답변서 제출기한 안에 답변서가 제출되지 아니한 사건

재판장은 답변서 제출기한(30일) 안에 답변서가 제출되지 아니하거나 피고가 청구원인 사실을 모두 자백하는 취지의 답변서를 제출한 사건은 원칙

적으로 변론 없이 바로 판결선고기일을 지정한다(민소 257조 1항, 2항). 민사소송법 257조 1항은 “... 변론 없이 판결할 수 있다.”라고 규정하고 있지만, 답변서가 제출되지 아니한 사건은 불필요하게 변론기일을 열어 당사자에게 출석의무를 부과하는 것보다 바로 변론 없이 판결을 선고하는 것이 당사자의 의사에 부합되고 소송경제에도 이바지한다는 데에 무변론판결 제도의 도입취지가 있는 만큼, 무변론판결에 적합하지 아니한 예외적인 경우가 아니면 바로 판결선고기일을 지정하는 것이 타당하다.

(2) 무변론판결이 불가능하거나 적합하지 아니한 사건

법률상 또는 성질상 무변론판결을 할 수 없거나 실무운영상 무변론판결에 적합하지 아니한 사건은 변론기일을 지정하여 처리하게 된다. 여기에 해당하는 사건유형으로는 피고에게 공시송달로 소장부분을 송달한 경우(민소 256조 1항 단서), 직권으로 조사할 사항(소송요건의 존부 등)이 있는 경우(257조 1항 단서), 변론주의 원칙의 적용이 일부 배제되는 등 그 소송의 성질상 무변론판결에 적합하지 아니한 경우(형성소송·가사소송·행정소송) 등을 들 수 있다.

소액사건의 경우에는 무변론판결에 관한 민사소송법의 규정이 배제되는 것은 아니지만, 소액사건심판법은 소가 제기되면 법원이 원칙적으로 이행권고결정을 할 수 있도록 하고 있고, 이행권고결정에 대하여 피고가 이의신청을 한 때에는 바로 변론기일을 지정하여야 하며, 이때에는 원고가 주장한 사실을 다룬 것으로 보므로(소액 5조의4 5항), 이행권고결정절차에 회부된 소액사건은 무변론판결의 대상이 될 수 없다. 또 이행권고결정절차를 밟지 않더라도 소액사건의 경우에도 30일간의 답변서 제출기한을 반드시 거치도록 하는 것은 소액사건의 특성에 비추어 적합하지 않고 이보다는 바로 변론기일에 회부하여 제1회의 변론기일로 심리를 마치는 것이 바람직하므로(7조 참조), 실무운영상 소액사건에서 무변론판결을 활용할 여지는 거의 없게 된다. 다만 소액사건에서 소장·준비서면, 그 밖의 소송기록에 의하여 청구가 이유

없음이 명백한 경우에는 변론 없이 청구를 기각할 수 있다는 심리절차상의 특칙이 별도로 마련되어 있다(소액 9조 1항).

또한 채무자가 지급명령을 송달받은 날부터 2주 이내에 적법한 이의신청을 하여 소송으로 이행된 사건(민소 472조 2항)의 경우에는, 이의신청을 한 채무자가 지급명령을 송달받은 날로 소급하여 그때부터 30일 안에 답변서를 제출할 의무를 부담한다고 볼 것인지 여부에 관하여 해석상 이론이 있을 수 있는 점, 이행권고결정에 대하여 피고가 이의신청을 한 경우에는 원고가 주장한 사실을 다룬 것으로 보고 있는 점과의 균형상, 무변론판결에 적합하지 아니하다고 할 것이다. 실무상으로도 이의신청서에 구체적으로 항변, 부인 등 방어방법의 기재가 있는 경우에는 추가로 답변서나 준비서면을 제출하지 않았다 하더라도 바로 자백간주에 의한 채권자 승소판결을 선고하지 않고, 이의신청서 부분을 채권자에게 송달하여 답변서나 준비서면으로 진술 간주하고 채권자에게 주장사실을 증명하도록 하여 그에 따라 판결하고 있다. 아울러 이의신청서에 구체적 방어방법의 기재가 없더라도 일단 변론기일을 지정하는 방식으로 사건을 진행함이 실무이다.

제22장

사건관리 및 변론의 진행

나. 소장송달 후 소장의 흠이 발견된 경우의 처리

법률상으로는 무변론판결이 가능하나 소장에 흠이 있어서 보정이 필요한 경우에 어떠한 절차에 따라 처리할 것인지 문제 된다.

이 경우 청구취지와 청구원인을 대비한 결과 청구취지 중 지연손해금의 이율이나 그 기산점에 착오가 있는 경우와 같이 그 흠이 사소하여 일부기각을 하더라도 원고가 특별한 이의를 제기하지 아니할 것으로 예상되는 경우에는 일부기각의 무변론판결을 선고하는 것도 가능할 것이다. 무변론판결이 무조건 원고 전부승소 판결을 의미하는 것은 아니기 때문이다. 다만 판례는 소액사건이 아닌 사안에서 원고의 청구가 이유 없음이 명백하더라도 변론 없이 청구를 전부 기각하는 판결은 허용되지 않는다고 한다(대법원 2017. 4.

26. 선고 2017다201033 판결).

반면 청구취지와 청구원인이 부합하지 아니하는 경우, 청구취지가 특정되지 아니하거나 청구취지에서 인용한 도면이 붙어 있지 아니한 경우 등 흠이 중대한 경우에는 보정명령을 발령하고 보정서가 제출되면 이를 피고에게 송달하여야 한다. 이 경우의 후속 절차에 관해서는 피고에게 보정서를 송달한 후 30일이 지나면 무변론판결을 선고할 수 있다는 견해와 무변론판결을 선고할 수 없으므로 변론기일을 열어야 한다는 견해가 있다.

다. 선고기일의 지정

무변론판결의 경우에도 반드시 선고기일을 열어 법정에서 판결을 선고하여야 한다. 이 경우 법원은 피고에게 소장부분을 송달할 때에 무변론판결의 선고기일을 함께 통지하는 방식(민소 257조 3항)이나 답변서 제출기한이 지난 후에 따로 선고기일을 지정하여 통지하는 방식 중 하나를 선택하게 된다.

위 두 가지 방식 중 앞의 방식은 ① 무변론판결의 선고기일을 최대한 앞당길 수 있고, ② 선고기일을 별도로 통지하는 데 따르는 노력을 줄일 수 있으며, ③ 다투는 사건의 경우에도 피고로 하여금 조기에 소송준비에 착수하게 함으로써 소송절차의 진행을 촉진할 수 있다는 등의 장점이 있다. 반면 이 방식은 소장부분이 송달불능되거나 피고가 답변서를 제출한 경우, 재판장이 기록을 심사한 결과 무변론판결에 부적합하다고 판단한 경우 등에는 지정된 선고기일을 취소하여야 하는 번거로움이 생기게 된다. 특히 피고가 복수인 경우에는 그중 일부 피고라도 송달불능되면 전체 원고, 피고에 대한 선고기일 지정을 취소하게 되므로 절차상 별다른 효용이 없을 수도 있다.

이에 비하여 답변서 제출기한이 지난 후에 따로 판결선고기일을 통지하는 뒤의 방식은 앞의 방식과 비교하여 무변론판결의 선고기일이 늦어지게 되는 등 절차진행의 신속성이 떨어지는 것이 단점이다. 반면 앞의 방식에 비하여 송달불능이나 답변서 제출에 따라 선고기일 지정이 취소되는 문제점이 크게

줄어들게 될 뿐 아니라, 특히 답변서 제출 단계에서 재판장이 최초로 기록을 심사하는 방식을 원칙적인 심리구조로 하는 경우에는 무변론판결 대상사건의 선별과 그에 대한 선고기일의 지정을 답변서 제출 단계에서 일괄 처리할 수 있게 되어 절차상 간명하다는 장점이 있다.

그러므로 무변론판결 대상사건의 선고기일 지정방식은 이와 같은 양 방식의 장단점과 함께 재판부의 업무량, 사건의 특성 등을 고려하여 결정하면 될 것이다.

이 경우 앞의 방식에 따라 소장부분을 송달할 때에 무변론판결의 선고기일을 함께 통지하는 경우에는, 원고에 대한 선고기일 통지는 소장부분 송달일부터 30일이 지난 후에 전화, 팩시밀리 또는 전자우편 등을 활용한 간이통지방식(민소 167조 2항, 민소규 45조 1항)으로 하고, 선고기일 지정을 취소하는 때에는 별도의 취소결정문을 작성하지 않고 재판사무시스템에만 그 취지를 입력하는 방식을 활용하며, 또 원고·피고에게 송달하는 무변론판결의 선고기일통지서에 “판결선고 전에 피고가 답변서를 제출하여 원고의 청구를 다투는 경우에는 선고기일이 취소된다.”라는 취지의 안내문구를 기재함으로써 원고·피고에 대한 선고기일 취소결정의 개별적 고지를 일부 생략하는 등 그 절차를 효율적으로 운영하기 위한 방안이 강구되어야 한다.

또한 뒤의 방식을 택하는 경우에도 원고에 대한 선고기일 통지는 위와 같은 간이통지방식을 활용할 수 있지만, 피고는 판결이 선고되기까지 답변서를 제출하여 무변론판결의 선고를 저지할 수 있고, 또 무변론판결의 선고기일은 기판력의 기준시점이 되는 등(민집 44조 2항, 민소 218조 1항, 2항) 절차상 중대한 의미가 있으므로, 피고에 대해서는 정식으로 기일통지서를 송달하여야 한다는 점에 유의할 필요가 있다.

라. 지정된 선고기일의 취소

답변서 제출기한이 지난 후 판결이 선고되기까지 답변서가 제출된 경우에

는 무변론판결을 선고할 수 없으므로(민소 257조 1항 단서), 지정된 선고기일을 취소하여야 한다. 선고기일에 임박하여 답변서가 제출된 경우에도 선고기일 지정취소는 불가피하다. 왜냐하면 변론기일과 달리 선고기일을 쟁점정리기일로 활용하는 것은 불가능하고, 또 선고기일을 바로 변론기일로 변경하여 진행하는 것도 절차상 적절하지 아니하기 때문이다. 선고기일 지정을 취소한 때에는 재판사무시스템에 그 취지를 입력하며, 전화 등 간이한 방식으로 원고, 피고에게 그 사실을 고지한다. 이와 함께 답변서 제출기한 안에 답변서가 제출된 경우와 마찬가지로 원칙적으로 변론기일을 지정하게 된다.

피고가 선고기일 이전에 답변서를 제출하지 아니한 채 선고기일에 출석하여 말로 다투는 경우에는 피고에게 답변서를 제출하도록 촉구한 후 선고기일을 연기하거나 선고기일 지정을 취소한 후, 피고의 답변서 제출을 기다려 변론기일을 지정하는 방식으로 운영하는 것이 타당하다.

마. 무변론판결이 불가능하거나 적합하지 아니한 사건의 처리

법률상 또는 성질상 무변론판결을 할 수 없거나 실무운영상 무변론판결에 적합하지 아니한 사건은 제1회 변론기일을 신속하게 지정하여야 하며(민소 258조 1항), 이 경우 선고기일과 변론기일을 일괄 지정하여 운영하는 방식도 적절히 활용할 수 있다. 재판장은 소장부분이 피고에게 송달된 후 30일 이내에 피고로부터 답변서가 제출되지 아니하였으나(또는 피고가 모두 자백하는 취지의 답변서를 제출한 사건 포함) 민사소송법 257조에 따른 무변론판결을 하지 아니하는 사건에 대하여 제1회 변론기일을 지정하여 당사자에게 통지함에 있어 제1회 변론기일과 선고기일을 일괄 지정하여 당사자에게 [전산양식 A1603]과 같은 기일통지서를 송달할 수 있다(제1회 변론기일 및 선고기일 일괄지정에 관한 예규 2조 본문).

제3절 답변서 제출 사건에 대한 기록심사

1. 답변서 제출

가. 답변서 제출의무

공시송달 외의 방법으로 소장부분을 송달받은 피고가 원고의 청구를 다투는 때에는 소장부분을 송달받은 날부터 30일 안에 답변서를 제출하여야 한다(민소 256조 1항). 법원은 소장의 부분을 송달할 때 이러한 취지를 피고에게 알려야 한다(2항). 답변서는 변론기일에서의 진술을 준비하는 서면으로서 준비서면에 관한 규정이 준용되지만(4항), 동시에 변론기일에서의 진술 이전에도 그 자체만으로 무변론판결을 저지하는 법적 효과를 갖는다. 피고가 답변서를 제출하면 그 부분을 원고에게 송달하여야 한다(3항).

나. 답변서의 기재사항과 첨부서류

답변서에는 청구의 취지에 대한 답변과 청구의 원인에 대한 구체적인 진술을 적어야 한다. 특히 청구의 원인에 대한 진술에서는 소장에 기재된 개개의 사실에 대한 인정 여부(민소규 65조 1항 1호) 및 항변과 이를 뒷받침하는 구체적 사실(2호)을 적어야 한다. 이는 소장 기재사항에 관한 민사소송규칙 62조와 더불어 조기기일지정의 실무를 뒷받침하기 위하여 당사자의 주장과 증거가 제1심에서 최대한 조기에 일괄하여 제출되도록 소장과 답변서를 충실하게 적도록 한 것이다.

이와 함께 답변서에는 자신의 주장을 증명하기 위한 증거방법과 상대방의 증거방법에 관한 의견을 함께 적어야 하며, 답변사항에 관한 중요한 서증의 사본이나 답변서에서 인용한 문서의 등본 또는 사본을 붙여야 한다(민소 256조 4항, 274조 2항, 275조, 민소규 65조 2항). 이와 같은 규정에 어긋나는 답변서가 제출된 때에는 재판장은 법원사무관등으로 하여금 방식에 맞는 답변서

의 제출을 촉구하게 할 수 있다(민소규 65조 3항).

2. 답변서에 대한 심사

가. 참여사무관등의 심사권한

효율적인 쟁점정리를 위해서는 실질적인 답변서가 제출되도록 유도하고, 제출된 답변서의 내용에 따라 사건을 신속하게 분류하는 것이 중요하다. 이와 같이 답변서 제출 단계에서 답변서의 내용을 심사하여 실질적 답변서의 제출을 촉구하거나 신속하게 처리하여야 할 사건을 선별하는 것은 재판장의 권한과 책임에 속한다. 다만 재판장은 이에 관한 사무를 참여사무관등에게 위임하여 처리하게 할 수 있다(민소규 65조 3항). 이것은 재판부 내부의 기능 조정과 효율적인 업무분담을 통하여 신속하고 충실한 재판을 실현하기 위한 것이다. 이 경우 재판장이 개별 사건이나 구체적인 사항을 지정하여 참여사무관등으로 하여금 답변서를 심사하고 실질적인 답변서의 제출을 촉구하도록 하는 방식도 가능하겠으나, 재판부 구성 초기에 재판장과 참여사무관등 재판부 구성원 간의 '사전 업무협의'를 통해 답변서가 제출되는 모든 사건에 관하여 위와 같이 업무를 처리하도록 포괄적 위임을 하는 방식이 더 바람직하다(사건관리예규 4. 참조).

나. 심사사항과 제출촉구 등

답변서에 대한 심사는 접수 단계에서부터 필요하다. 접수담당 법원사무관 등은 제출된 답변서에 피고의 전화번호·팩시밀리번호·전자우편주소 등 연락처가 적혀져 있는지를 검토하여야 하고(민소규 2조 1항 2호, 5조 3항), 특히 당사자 본인소송의 경우에는 반드시 그 연락처를 확인하여 둘 필요가 있다. 답변서의 보정권고나 실질적 답변서의 제출촉구를 위해서는 연락처의 기재가 필수적이기 때문이다.

한편 사건을 배당받은 재판부의 참여사무관등은 답변서가 법과 규칙에 규

정된 기재사항과 첨부서류를 갖추고 있는지 여부를 심사하여야 하고, 특히 그 답변내용을 읽어 보아 구체적이고 실질적인 답변이 이루어졌는지를 중점적으로 검토하여야 한다. 답변서를 심사한 후 기재사항이나 첨부서류가 빠져 있거나 “원고의 청구를 전부 부인한다.”라는 식의 형식적인 내용이 적힌 답변서가 제출된 경우에는 전화·팩시밀리 등 적절한 수단을 통하여 실질적인 답변서를 제출하도록 보정권고를 하거나 그 밖에 흠을 보정하도록 촉구하여야 한다. 이 경우 팩시밀리 등 서면으로 제출을 촉구하거나 보정을 권고한 때에는 그 서면이 기록에 포함되도록 하고, 전화 등 말로 제출을 촉구한 때에는 사건메모 등 적당한 곳에 이에 관한 사항을 기록하여 둔다.

참여사무관등의 이와 같은 제출 촉구는 재판장의 권한에 속하는 것을 위임받아 시행하는 것으로서 당사자의 자발적인 이해와 협력을 기대하는 취지이므로 소송법상 강제적 효력은 없다. 그러므로 피고가 참여사무관등의 촉구에 따르지 아니하는 경우에는 재판장 이름으로 준비명령을 하고, 피고가 그 준비명령에도 따르지 아니하는 때에는 참여사무관등이 재판장에게 보고하여 그 지시에 따라 곧바로 변론기일을 지정하거나 원고에게 증명을 촉구하는 석명준비명령을 보내는 등으로 사건관리의 방향을 정하게 된다.

한편 답변서 제출 단계에서 참여사무관등의 권한이 반드시 위와 같은 형식적인 사항의 심사에 한정되는 것은 아니고, ① 관할위반의 항변 유무, ② 당사자의 조정의사 유무를 포함하여 조정회부가 상당한지 여부 ③ 관련 사건에 관한 기재가 있는지 여부, ④ 그 밖에 재판장과의 사전 업무협의를 통해 답변서 심사 시 검토하기로 한 사항(예: 무변론 사건의 선고기일 지정, 필수적 증거신청 촉구 여부) 등도 함께 검토하여 재판장에게 자신의 의견을 함께 보고함이 타당하다(사건관리에규 8. 가, 나. 참조). 특히 소장부분과 함께 피고에게 송달한 답변서 요약표[전산양식 A1510]가 답변서와 함께 제출된 경우에는 원고의 주장을 다투는지 여부, 조정을 희망하는지 여부, 소송요건에 관한 의견 등 피고의 실질적 답변 내용을 손쉽게 파악할 수 있는 이점이 있다.

다. 재판장에 대한 기록인계 및 보고

참여사무관등은 재판장이 달리 정하는 경우가 아닌 한 답변서에 대한 심사가 끝나면 바로 기록과 함께 답변서를 재판장에게 인계하여야 한다. 이 과정에서 이송, 조기조정회부, 변론기일지정 등 사건분류에 대한 의견이나 실질적 답변서의 제출촉구 등 답변서 심사와 관련된 사항을 재판장에게 보고하여야 하며, 이 경우 기록검토 결과보고서[전산양식 A2934]를 활용하는 방식이 권장된다[사건관리예규 8. 나. (2)]. 또한 참여사무관등은 답변서 심사 과정에서 당해 사건에 필수적인 증거신청이 누락된 경우 직접 보정권고를 하거나 석명준비명령 초안을 작성하여 기록과 함께 인계할 수 있다[8. 나. (3)].

재판장에게 답변서를 인계하는 방식은 수시로 인계하는 방식보다는 매주 1, 2회 정도 일정한 요일을 정하여 인계하는 방식이 효과적이다. 재판장에 대한 답변서와 기록의 인계는 신속히 이루어져야 하며, 기록인계가 불필요하게 지연되어서는 안 된다. 답변서의 제출촉구나 보정권고에 관련된 사항이나 그 밖에 재판진행에 관련된 특이한 사항에 관한 의견 등을 사건진행카드 등에 적어서 기록과 함께 인계하는 방식도 활용할 수 있다.

3. 재판장의 기록심사와 사건분류

가. 재판장의 기록심사

재판장은 참여사무관등으로부터 기록과 함께 답변서를 인계받아 기록을 심사하게 된다. 이것이 재판장으로서의 최초의 기록심사시기가 되며 이를 통하여 재판장은 사건을 분류하고 그 처리방향을 1차적으로 결정하게 된다. 이 단계의 기록심사는 소장과 제출된 답변서를 중심으로 사건의 처리방향(변론기일 지정/변론준비절차 회부/조정 회부)을 정하는 데 필요한 범위에서 이루어진다. 합의부의 경우 재판부의 업무부담과 인력구성에 따라서는 주심판사가 심사업무를 분담하는 방식도 가능하다.

나. 사건처리방향의 결정

피고가 답변서를 제출하여 다투는 사건에 대하여, 법원은 양쪽 당사자의 주장과 증거(쟁점)를 정리한 뒤 증인신문과 당사자신문을 집중하여 실시하는 방식으로 소송절차를 진행하게 된다. 여기서 다툼이 있는 사건에서의 쟁점 정리 방식은 크게 ‘변론기일 방식’과 ‘준비절차 방식’으로 나누어지는바, 답변서가 제출된 단계에서 어떠한 방식에 따라 쟁점을 정리할 것인지를 결정하게 된다.

아울러 소송절차의 모든 단계에서 분쟁의 화해적 해결을 위하여 노력하여야 하므로, 재판장은 답변서 심사 단계에서도 화해적 분쟁해결이 적합하다고 판단되는 사건의 경우에는 화해권고결정을 하거나 변론기일 지정에 앞서 조정애 회부할 수 있다(사건관리에규 9. 나. 참조).

제22장

사건관리 및 변론의 진행

다. 원칙: 신속한 제1회 변론기일 지정

민사소송법은 변론 없이 판결하는 경우 외에는 바로 변론기일을 지정하도록 함으로써 ‘변론기일 방식’과 ‘준비절차 방식’의 두 가지 중 전자가 원칙적인 심리방식임을 분명히 하고 있다(민소 258조 1항 본문). 따라서 피고로부터 다투는 취지의 답변서가 제출되면 그 단계에서 바로 변론기일을 지정하고 구술공방을 거쳐 쟁점을 정리한 후 증거조사를 실시하는 방식이 원칙적인 심리형태가 된다.

여기서 “바로 변론기일을 정하여야 한다.”(민소 258조 1항)라는 규정이 사건의 접수순서 내지 답변서 제출순서에 따라 기계적으로 변론기일을 지정해야 한다는 의미가 아니라는 점도 유의할 필요가 있다. 위 규정의 취지는 ① 사건의 난이도, 신속한 사건처리의 필요성 등 제반 사정에 비추어 실질적인 집중 구술심리가 이루어질 것으로 예상되는 가장 이른 시기로 변론기일이 지정되어야 한다는 것과, ② 재판부의 변론기일 지정·통지 행위가 예측 가능한 한도에서 가급적 신속하게 이루어짐으로써 당사자의 절차 지연에 대한

불안감을 최소화하여야 한다는 것을 의미한다. 그런 의미에서 2009. 1. 9. 개정된 민사소송규칙도 “재판장은 답변서가 제출되면 바로 사건을 검토하여 가능한 최단기간 안의 날로 제1회 변론기일을 지정하여야 한다.”라고 규정하였다(민소규 69조 1항). 이에 따라 재판장은 답변서 접수 직후 기록검토 및 사건분류를 하는 시점에서 지체 없이 사건의 분쟁성, 난이도, 조정적합성, 신속처리의 필요성 등 여러 특성을 가늠한 후 실질적으로 변론의 집중이 가능한 최단기간 안의 날로 제1회 변론기일을 지정하면 된다.

특히 사건의 일반적 특성상 신속한 처리가 요청되는 경우 또는 쟁점이 거의 없거나 전형적이어서 별도의 서면공방절차가 필요 없는 경우 등은 변론준비절차 없이 신속하게 변론기일을 지정한다. 건물인도청구사건, 임대차보증금청구사건, 배당이의사건과 청구이의사건 등 집행관계소송 등이 전자의 예라면, 후자의 예로는 쟁점이 간단한 대여금사건, 어음금사건 등을 들 수 있을 것이다.

라. 예외: 변론준비절차 회부

주장과 증거가 복잡하여 이를 정리하여야만 변론기일의 효율적 운영이 가능하다고 판단되는 경우 등과 같이 필요한 경우에는 사건을 변론준비절차에 부칠 수 있다(민소 258조 1항 단서 참조). 이와 같이 2008. 12. 26. 민사소송법 개정 이후에도 변론준비절차는 여전히 활용할 수 있지만, 이에 따라 열리는 변론준비기일은 어디까지나 본격적인 변론의 준비에 필요한 당사자의 주장과 증거를 정리하는 기일이므로(민소 282조 1항, 민소규 70조의2 참조), 변론기일을 지정하지 않고 변론준비절차에 부칠 경우에는 그 기능과 성격을 고려하여 운영하여야 한다. 사건관리방식에 관한 예규 9.의 다항은 변론준비절차에 회부할 사건 유형으로 ① 쟁점과 주장 내용이 복잡하거나 방대한 사건, ② 전문적인 분야나 새로운 형태의 법률관계에 관한 사건, ③ 주장 자체가 불분명하거나 서로 모순되는 사건, ④ 증거가 많고 복잡하여 증명계획 등을 사전에 협의할 필요가 있는 사건을 들고 있다.

한편 재판장은 특별한 사정이 있는 때에는 변론기일을 연 뒤에도 사건을 변론준비절차에 부칠 수 있다(민소 279조 2항). 따라서 원칙에 따라 쟁점정리를 위하여 변론기일 방식을 활용하더라도 형식적으로 속행하는 것은 지양하여야 하며, 효율적인 쟁점정리를 위하여 따로 주장과 증거의 정리가 필요하다고 인정되는 때에는 사건을 변론준비절차에 부치는 등 사전쟁점정리와 집중증거조사, 법정기일의 최소화라는 현행 민사소송 심리방식의 기본 취지를 살리도록 절차가 진행되어야 한다.

마. 조기조정 사건의 선별

답변서 심사 단계에서 화해적 분쟁해결이 적합한 사건이라는 판단이 들면, 재판장은 조정전담판사 등이 주관하는 조정(조정전담판사, 상임조정위원, 조정위원회 등 수소법원 이외의 기관에 의한 조정을 모두 포함한다. 이하 같다)에 회부할지, 아니면 수소법원 조정에 회부할지를 선택하여야 한다.

실무상 절차 초기에는 조정전담판사 등이 주관하는 조정으로, 실체에 관한 심리 후에는 수소법원 조정으로 실시하는 경우가 많다. 일부 당사자나 소송대리인은 재판을 받기 위해 소송을 제기하였는데 조정기일통지서를 받았으며 변론기일 전 조정회부에 다소 불만을 표시하기도 한다. 그러나 답변서 접수 후 기계적으로 조정에 회부하는 것이 아니라 사건의 내용을 충분히 파악한 후 조정에 친한 유형을 선별하여 회부하는 한, 조기조정을 활성화하는 것이 바람직하다.

참여관 등은 조정전담판사 등이 주관하는 조정절차에 회부된 사건이 장기간 방치되지 않도록 정기적으로 확인하고 사건이 조정불성립으로 돌아오면 지체 없이 재판장에게 고지하여야 한다. 재판장도 주기적으로 사건진행관리화면을 열어 '소송절차로 복귀한 사건'의 유무를 확인하는 등의 방법으로 조정전담판사 등이 주관하는 조정절차에서 조정불성립으로 돌아온 사건을 파악할 필요가 있다.

제4절 변론준비절차

1. 의의와 활용범위

가. 의의

‘변론준비절차’란 변론이 효율적이고 집중적으로 실시될 수 있도록 당사자의 주장과 증거를 정리하는 절차를 말한다(민소 279조 1항).

변론준비절차를 진행하는 재판장등은 쟁점과 증거의 정리, 그 밖에 효율적이고 신속한 변론진행을 위한 준비가 완료되도록 노력하여야 하고, 당사자는 이에 협력하여야 한다(민소규 70조 1항).

변론준비절차에는 변론에서의 법원이나 재판장의 권한에 관한 규정 대부분이 준용되는데, 소송지휘(민소 135조), 석명권·구문권 등(136조), 석명준비명령(137조), 합의부에 의한 감독(138조), 석명처분(140조), 변론의 재개(142조), 통역(143조), 진술 보조(143조의2), 변론능력이 없는 사람에 대한 조치(144조), 화해의 권고(145조), 적시제출주의(146조), 제출기간의 제한(147조), 한쪽 당사자의 불출석(148조), 실기한 공격·방어방법의 각하(149조), 자백간주(150조), 소송절차에 대한 이의권(151조), 화해권고결정(225조 내지 232조), 양쪽 당사자의 불출석(268조), 요약준비서면(278조)에 관한 규정이 모두 준용된다(286조). 변론준비기일에서 화해와 청구의 포기·인낙(220조), 소취하(266조 3항 단서)도 할 수 있다.

변론준비절차는 ① 서면에 의한 변론준비절차, ② 변론준비기일의 두 가지로 분류된다.

나. 활용범위

2002년 개정 민사소송법에서는 신모델의 이념을 구현하기 위하여 원칙적으로 모든 사건에서 변론준비절차를 거치는 것으로 규정하였고(구 민소 258

조 1항 본문), 변론준비절차에서 쟁점을 정리할 때에도 변론준비기일을 조기에 지정하는 방식보다 서면공방 선행방식을 원칙으로 하였다(민소 280조 1항, 282조 1항 참조). 이는 종래 소장이 접수되는 것에 연동하여 기계적으로 변론기일이 지정됨에 따라 해당 변론기일에서 비로소 새로운 주장이나 증거가 다수 제출되어 기일이 공전되거나 형식적으로만 진행됨으로써 분산심리를 초래하였다는 반성적 고려에서 비롯된 것이었다. 그러나 신모델이 실무에 정착된 이후 원칙적으로 변론준비절차에 회부하고 서면공방을 선행시키는 방식이 사건처리 지연과 기록분량 증가 등 부작용을 초래한다는 지적이 대두되었고, 다른 한편으로 변론준비기일에서 수명법관의 주재 아래 쟁점정리 등 본격적인 구술심리가 이루어질 경우 공개주의나 직접주의에 반할 우려도 있었다.

그 결과 2008. 12. 26. 개정 이후의 현행 민사소송법에서는 재판장의 기록검토 후 변론준비절차 회부가 아닌 변론기일 지정이 원칙으로 채택되었고(민소 258조 1항), 변론준비절차의 실시에 관한 규정에서 ‘주장과 증거를 정리’한다는 문구만 남고 ‘소송관계를 뚜렷하게 하여야 한다’는 부분이 삭제되었다(279조 1항). 이와 같은 개정의 취지는, 법관이 당사자를 조기에 대면함으로써 심리의 효율성을 높이고 사건의 신속한 처리를 도모함과 더불어, 변론기일과 변론준비기일을 준별함으로써 양자 사이의 심리대상과 심리방법을 구분한다는 데에 있다. 따라서 변론준비절차는 ‘주장과 증거의 정리’라는 본래의 목적에 충실하게 진행하는 것이 바람직하다. 특히 복잡한 사건에서 분쟁의 초기에 쟁점을 정리하고 다툼의 대상이 되는 실질적 쟁점의 범위를 확정하는 작업을 위해 변론준비절차를 활용할 수 있을 것이다.

다만 아래와 같은 경우에는 변론준비절차를 활용하는 것이 불가능하거나 부적절하다.

① 피고가 답변서를 제출하지 아니하거나 원고의 청구를 다투지 아니하는 취지의 답변서를 제출하여 무변론판결을 하는 경우 등을 포함하여 변론 없

이 판결하는 경우에는(민소 124조, 219조, 257조) 사건을 변론준비절차에 부칠 여지가 없다. 소액사건에서 변론 전에 이행권고결정으로 종결되는 사건도 마찬가지이다(소액 5조의3 이하).

② 피고에게 소장부분과 변론기일통지서를 공시송달의 방법에 따라 송달하는 경우에는 피고가 현실적으로 변론준비에 필요한 소송행위를 할 것을 기대할 수 없으므로, 변론준비절차에 부칠 여지가 없다.

③ 소액사건의 경우에 판사는 답변서 제출과 무변론판결, 변론준비절차 회부에 관한 민사소송법 256조 내지 258조의 규정에 불구하고 바로 변론기일을 지정할 수 있고, 되도록 1회의 변론기일로 심리를 마치기 위하여 변론기일 전이라도 당사자로 하여금 증거신청을 하게 하는 등 필요한 조치를 취할 수 있도록 되어 있다(소액 7조). 따라서 소액사건은 변론준비절차에 부치지 아니하고 바로 변론기일을 지정하는 것이 원칙이고 예외적으로만 변론준비절차에 부칠 수 있다.

2. 변론준비절차 회부

가. 재판장의 회부명령

변론준비절차는 재판장의 변론준비절차 회부명령으로 개시된다(민소 258조 1항 참조). 재판장의 회부명령에 대하여는 불복할 수 없다. 종전의 준비절차회부는 법원의 결정을 필요로 하였으나(구 민소 253조 참조), 2002년 민사소송법 개정으로 변론준비절차회부는 재판장의 직권에 의한 것으로 변경되었으며, 이러한 재판장의 권한은 합의부와는 독립한 고유의 권한이다.

변론준비절차의 진행은 재판장이 담당하는 것이 원칙이고(민소 280조 2항), 서면에 의한 변론준비절차 단계에서는 주심판사 등을 수명법관으로 지정할 별다른 필요성도 없으므로, 변론준비절차회부 단계에서는 수명법관을 지정하지 아니하는 것이 보통일 것이다. 만일 주심판사로 하여금 검증 등 기일전 증거조사를 하게 하거나 변론준비기일을 진행하게 할 필요가 있는 경

우에는 그 단계에서 수명법관으로 지정하면 된다.

나. 회부명령의 시기 등

재판장은 답변서 제출 단계에서 무변론판결 대상사건을 선별하고 이를 제외한 나머지 사건 중 필요한 경우에 변론준비절차에 부치게 되므로(민소 258조 1항 참조), 변론준비절차 회부명령은 원칙적으로 답변서 심사 단계에서 이루어지게 된다.

다만 재판장은 특별한 사정이 있는 때에는 변론기일을 연 뒤에도 사건을 변론준비절차에 부칠 수 있다(민소 279조 2항). 여기서 ‘특별한 사정이 있는 때’라 함은 사건분류 후 바로 변론기일을 지정하였으나 제1회 기일을 진행한 결과 소의 변경, 반소의 제기, 소송참가 또는 새로운 공격방어방법의 제출 등으로 새로운 쟁점정리가 필요하게 되는 때와 제1회 기일 진행 결과 서면에 의한 변론준비절차가 필요하다고 판단되는 때 등을 들 수 있다.

본소절차를 변론준비절차에 부친 후에 반소(민소 269조), 청구의 변경(262조), 중간확인 의 소(264조)와 같은 이른바 소송중의 소가 제기된 경우 이에 대하여 따로 변론준비절차에 부쳐야 하는지 여부가 문제될 수 있으나, 반소 등은 본소절차를 전제로 하여 함께 심리되는 것이므로 본소에 대한 변론준비절차회부의 효력이 반소 등에도 당연히 미친다고 보는 것이 타당하다. 만일 이와 반대의 견해를 취하더라도 반소 등에 대하여 본소와 함께 변론준비절차를 진행함으로써 묵시적으로 변론준비절차에 부친 것으로 볼 수 있을 것이므로(절차이익의 상실의 대상으로 볼 여지도 충분하다. 151조 참조), 실무상 따로 회부명령을 하지 아니하더라도 특별한 문제는 없을 것이다.

항소심의 소송절차에는 특별한 규정이 없으면 제1심의 소송절차를 준용하므로(민소 408조), 항소심에서도 변론준비절차를 열 수 있다.

제22장

사건관리 및 변론의 진행

3. 변론준비절차 진행

가. 진행의 담당자

변론준비절차는 단독사건의 경우에는 재판장이 진행할 것이고, 합의사건의 경우에는 다른 조치가 없으면 역시 재판장이 진행하지만 재판장은 합의부원을 수명법관으로 지정하여 이를 담당하게 할 수 있다(민소 280조 2항, 3항).

그리고 단독사건과 합의사건 모두 재판장은 필요하다고 인정하는 때에는 변론준비절차의 진행을 다른 판사에게 촉탁할 수도 있다(민소 280조 4항). 수 소법원을 구성하지 아니하는 판사(사법행정상의 소속법원은 같아야 함)로 하여 금 담당하게 할 수 있다는 취지로서, 보통은 거의 적용되지 않을 것이나, 변 론준비절차만을 전담하는 판사를 두게 된다면 그 근거가 될 것이다.

변론준비절차를 진행하는 재판장, 수명법관, 다른 판사(이하 ‘재판장등’이라 한다)의 권한에 관하여는 앞서 본 바와 같이 변론에서의 법원이나 재판 장의 권한에 관한 규정이 준용된다고 볼 수 있다(민소 286조). 이에 따라 재 판장등은 변론준비절차에서 화해권고결정을 할 수도 있다(286조, 225조 내 지 232조).

재판장등의 권한은 변론의 준비를 위한 것이므로 스스로 그 한계가 있다. 즉 중간판결(민소 201조)이나 종국판결을 할 수 없음은 물론 소송의 이송(34 조 내지 36조), 참가 허부에 대한 결정(73조), 소송인수 허부의 결정(82조), 담 보제공의 결정(120조), 수계신청에 대한 재판(243조), 청구변경 허부의 결정 (262조, 263조) 등의 소송상의 재판도 할 수 없다. 이와 같은 재판사항은 수 소법원에 유보된 권한이므로 이러한 사항이 변론준비절차 중에 생긴 때에는 재판장등은 일단 변론준비절차를 멈추고 수소법원의 재판이 있는 다음에 변 론준비절차를 계속하여야 한다. 합의사건에서 변론준비절차를 주재하는 재 판장등의 변론지휘에 관한 명령이나 석명권 행사, 석명준비명령에 대한 당 사자의 이의에 대하여도 합의부인 수소법원이 재판하여야 하고(138조), 변론 의 제한·분리·병합 역시 수소법원만이 할 수 있다(141조). 다만 수소법원인

단독판사가 직접 변론준비절차를 진행하는 경우에는 이러한 제한이 무의미함은 물론이다.

나. 증거결정과 증거조사

변론준비절차를 진행하는 재판장등은 변론의 준비를 위하여 필요하다고 인정하면 증거결정을 할 수 있고, 변론의 효율적이고 집중적인 실시라는 목적을 달성하기 위하여 필요한 범위 안에서 증거조사를 할 수 있다(민소 281조 1항, 3항). 다만 증인신문과 당사자신문은, 증인 또는 당사자가 정당한 사유로 법원에 출석하지 못하는 때, 증인 또는 당사자가 법원에 출석하려면 지나치게 많은 비용이나 시간을 필요로 하는 때 또는 그 밖의 상당한 이유가 있는 경우로서 당사자가 이의를 제기하지 아니하는 때에 한하여 할 수 있다(3항 단서, 313조).

증거신청은 일반적으로 변론기일 전에도 할 수 있으므로(민소 289조 2항), 변론준비절차와 관계없이 언제라도 할 수 있는데, 2002년 개정 민사소송법은 변론준비절차를 강화하는 차원에서 이를 담당하는 재판장등이 변론준비상 필요하다고 판단하면 스스로 증거결정은 물론 일정한 증거조사까지도 할 수 있도록 하였다. 이는 효율적인 변론준비와 심리의 집중을 도모하기 위하여, 사실인정의 권한과 책임이 있는 수소법원이 증거결정과 증거조사를 한다는 전통적인 원칙에 일부 수정을 가한 것으로 볼 수 있다. 쟁점의 정리를 위해서는 재판장등이 증거신청에 대한 채부의 결정을 하고 이를 바탕으로 하여 다른 공격방어방법이 제출되는 방식으로 진행되는 경우가 많을 것이므로, 재판장등은 적극적으로 증거결정을 할 것이 기대된다. 다만 변론준비절차를 진행하는 재판장등과 수소법원이 일치하지 아니하는 경우(합의부의 경우 또는 촉탁 받은 다른 판사가 변론준비절차를 담당하는 경우)에는 재판장등이 증거결정을 하지 아니한 채 수소법원의 판단에 맡기는 것이 적절한 증거신청도 있을 것이다.

변론준비절차에서의 증거신청과 증거결정 및 증거조사는 변론준비기일을 여는 경우는 물론이고 서면에 의한 쟁점정리절차에서도 가능하므로, 이러한 사항을 증거목록에 기재하고, 증거조사에 관한 조서를 작성하여야 한다. 변론절차에서 이러한 조서가 작성되는 경우와 다를 바 없다. 다만 변론준비기일이 열리지 아니한 채 증거조사기일만 열린 경우에는 이를 구별하여 작성하여야 한다.

다. 당사자의 사실관계 조사의무

민사소송에서 판단의 기초가 되는 사실관계에 관한 자료는 당사자가 제출하는 것이 원칙이기 때문에 소송절차가 원활히 진행되기 위해서는 양쪽 당사자가 사실관계에 관한 주장과 증거를 미리 조사한 후 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하는 것이 전제되어야 한다. 따라서 민사소송규칙은 당사자에게 주장과 증명을 충실히 할 수 있도록 사전에 사실관계와 증거를 상세히 조사할 의무를 부과하고 있다(민소규 69조의2).

사실관계의 조사는 그 취지에 비추어 볼 때, 가능한 한 변론기일 또는 변론준비기일에서 쟁점정리에 들어가기 전까지, 늦어도 그 기일의 절차가 끝나기 전까지 마쳐야 한다. 변론준비절차를 거쳐 지정된 변론기일은 사실과 증거에 관한 조사가 충분하지 않다는 이유로 변경할 수 없다(민소규 72조 3항)는 것을 그 근거로 들 수 있을 것이다.

당사자는 이러한 조사의무가 있을 뿐이고, 이에 기하여 조사의 권한을 새롭게 부여받은 것은 아니다. 그러므로 당사자 본인이나 소송대리인인 변호사 등이 민사소송규칙 69조의2를 근거로 하여 강제적으로 증인의 출석을 요구한다든지 서류의 제출을 강제할 수는 없다. 조사의무의 이행을 위하여 필요한 때에는 변론준비절차에서의 증거조사(민소 281조)나 기일전 증거조사(289조 2항), 증거보전절차(375조 내지 384조) 등을 활용하여야 한다.

한편 직권탐지주의가 적용되는 가사소송·회생·파산 등의 절차, 직권에

의한 증거조사가 인정되는 행정소송(행소 26조) 등에서도 당사자가 사실관계에 관하여 주장 내지 증명책임이 있는 한도에서는 이러한 사실관계 조사의 무가 적용된다.

라. 당사자 간의 협의

변론준비절차에서 당사자는 쟁점과 증거의 정리, 그 밖에 효율적이고 신속한 변론진행을 위한 준비에 관하여 상대방과 협의를 할 수 있고, 재판장등은 당사자에게 변론준비를 위하여 필요한 협의를 하도록 권고할 수 있다(민소규 70조 2항, 1항). 변론준비절차에서 주장과 증거의 정리는 재판장등의 소송지휘로도 어느 정도 가능하지만 가능한 한 당사자 간의 협의에 의한 합의로써 행하여지는 것이 더 바람직하다고 할 수 있다. 변론준비절차에서 당사자 사이에 합의가 성립된 경우에는 일정한 소송법상의 효력을 인정할 수 있을 것이다. 또한 그 합의를 어긴 경우에는 실권효 부과의 유력한 근거가 될 수 있다고 본다.

재판장등은 변론준비절차에서 효율적이고 신속한 변론진행을 위하여 당사자와 변론의 준비와 진행 및 변론에 필요한 시간에 관한 협의를 할 수 있다(민소규 70조 3항). 또한 재판장등은 준비서면의 제출횟수, 분량, 제출기간 및 양식에 관한 협의를 할 수 있고, 이에 관한 합의가 이루어진 경우 당사자는 그 합의에 따라 준비서면을 제출하여야 한다(4항). 그와 같은 합의가 없는 경우 준비서면의 분량은 30쪽을 넘을 수 없다(69조의4 1항). 당사자가 수기로 알아보기 어렵게 작성한 준비서면을 제출하는 경우 위 조항에 근거하여 당사자에게 컴퓨터로 준비서면을 작성하여 제출하도록 협의할 수도 있다. 재판장등은 기일을 열거나 당사자의 의견을 들어 양쪽 당사자와 음성의 송수신에 의하여 동시에 통화를 하거나 인터넷 화상장치를 이용하여 위 각 사항에 따른 협의를 할 수 있다(5항).

4. 서면에 의한 쟁점정리절차

가. 의 의

서면에 의한 쟁점정리절차는 따로 변론준비기일을 열지 아니하고 진행하는 변론준비절차라고 정의할 수 있다.

민사소송법은 변론준비절차에 부쳐진 사건은 기간을 정하여 당사자로 하여금 준비서면, 그 밖의 서류를 제출하게 하거나 당사자 사이에 이를 교환하게 하고 주장사실을 증명할 증거를 신청하게 하는 방법으로 진행하게 함으로써(민소 280조 1항), 쟁점정리에 관한 여러 가지 방식 중 서면공방선행 방식을 표준적인 형태로 채택하였다.

그러나 재판장등은 변론준비절차에서 반드시 서면에 의한 절차를 거친 다음에야 변론준비기일을 열 수 있는 것은 아니므로, 필요하다면 서면에 의한 절차를 생략하고 바로 변론준비기일을 지정할 수도 있다(민소 282조 1항). 특히 지나친 서면공방은 쟁점을 복잡하게 하고 당사자의 불필요한 감정대립을 초래하여 화해적 해결을 어렵게 하며 기록 분량도 증가시키는 문제점이 있으므로, 사건을 변론준비절차에 부침과 동시에 변론준비기일을 정하고 준비서면 제출 및 증거 신청의 기한을 지정하는 등 절차의 신속한 진행을 도모하는 것이 바람직하다(민소규 69조 3항 참조).

나. 서면에 의한 쟁점정리절차와 참여사무관등의 역할

신모델에서는 참여사무관등이 재판장의 위임에 따라 서면에 의한 쟁점정리절차 단계를 주도적으로 관리하게 하였다. 이 단계의 절차는 준비서면의 교환과 서증 등의 제출이 주된 내용을 이루게 되고, 법원은 당사자 사이의 이러한 준비작업이 순조롭게 이루어질 수 있도록 준비서면의 제출기한을 설정하고, 그 제출을 촉구하는 등의 역할을 수행하면 충분하므로, 참여사무관등이 그와 같은 역할을 하는 데 별다른 지장이 없을 뿐 아니라, 법원 인적자원의 효율적인 활용과 이를 통한 심리의 충실화라는 관점에서도 이러한 방

식을 적극 활용하는 것이 바람직하기 때문이다.

이와 관련하여 2015. 1. 28. 개정으로 신설된 민사소송규칙 70조의3은 변론준비절차에서 재판장등은 법원사무관등으로 하여금 그 이름으로 준비서면, 증거신청서 및 그 밖의 서류의 제출을 촉구하게 할 수 있고, 법원이나 재판장등의 결정·명령·촉탁 등에 대한 회신 등 절차이행이 지연되는 경우에도 재판장등은 법원사무관등으로 하여금 그 이름으로 해당 절차이행을 촉구할 수 있도록 하였다. 사건관리방식에 관한 예규는 이를 더 구체화하여 ① 변론준비를 위하여 원고에게 준비서면을 제출하게 하는 경우 재판장은 답변서 발송일부터 3주 정도로 기한을 정하여 피고의 주장에 대한 답변 등과 증거방법에 관한 의견을 기재한 준비서면과 필요한 증거방법을 제출하도록 최고하는 내용의 준비명령[전산양식 A1502]을 하거나 참여사무관등으로 하여금 준비권고[전산양식 A1502-1]를 하도록 하면서, 이때 참여사무관등은 준비명령 또는 준비권고와 함께 소송절차안내서[전산양식 A1176] 및 준비서면요약표[전산양식 A1521]를 송달하도록 하고[사건관리예규 10. 나. (1), (2)], ② 전형적으로 증거신청이 필요하다고 판단되는 사건임에도(예: 인신사고로 인한 손해배상사건에서의 신체감정, 관련 형사사건이 있는 사건에서의 문서송부촉탁 등) 당사자가 필요한 증거신청을 하지 않는 경우 참여사무관 등은 증명촉구서[전산양식 A1550-1, A1551-1, A1552-1]를 송부하거나, 전화 또는 팩시밀리로 신청을 촉구하고, 시행한 증거조사의 결과(예: 송부문서, 사실조회회보서, 감정서 등) 제출이 지연되는 경우에는 그 결과 제출을 촉구하여야 하고, 그 결과가 법원에 도착한 경우에는 이를 양쪽 당사자에게 즉시 통지하여야 한다[12. 나. (1), (5)]. 위와 같은 규칙 및 예규 개정으로 변론준비절차 진행 과정에서 당사자들이 필요한 준비서면이나 증거신청서 등을 제출하지 않거나, 절차이행이 지연되는 경우에 참여사무관등이 재판장의 개별적 결재 없이 사전 업무협의에 의한 포괄적 위임을 받아 자신의 이름으로 이행을 촉구할 수 있게 되었고, 그로 인한 신속한 절차진행이 기대된다.

또한 민사소송규칙 30조, 73조는 재판장의 석명권 행사나 석명준비명령 또는 석명처분이 있는 경우에 재판장 또는 법원은 법원사무관등으로 하여금 그 조치나 처분의 이행 여부를 확인하고 그 이행을 촉구하게 할 수 있다고 규정하고 있다. 위 규정에 의해서도 재판장은 참여사무관 등에게 개별 사건마다 구체적인 사항을 지적하여 석명사항 등의 이행 여부 확인과 이행 촉구를 하게 할 수 있음은 물론, 나아가 주장제출이나 증거신청의 기간을 정한 모든 사건에 대하여 정하여진 기간 안에 필요한 조치가 이행되었는지 여부를 확인하고 이행되지 않은 사건의 당사자에 대해서는 일일이 재판장에게 보고하여 지시를 받을 필요 없이 곧바로 그 이행을 촉구하도록 하는 포괄적인 사무지시를 하는 것도 가능하다고 해석된다.

제22장

사건관리 및 변론의 진행

다. 준비서면

(1) 의 의

준비서면이란 당사자가 변론에서 진술하고자 하는 사항을 기일 전에 미리 적어 법원에 제출하는 서면을 말한다.

민사소송법은 변론은 집중되어야 한다고 하면서, 이를 위하여 당사자는 변론을 서면으로 준비하는 것을 원칙으로 하고 있다(민소 272조 1항 참조). 특히 서면공방에 의한 변론준비절차를 거치는 경우에는 준비서면의 역할과 기능이 더욱 크다고 할 수 있다.

준비서면 제도의 채용은 언뜻 서면심리주의를 취하는 것처럼 보이나, 준비서면에 적은 사항은 변론(준비)기일에서 실제로 진술되거나 진술간주(민소 148조)되어야 비로소 소송자료가 되는 것이 원칙이므로 구술주의에 반하는 것은 아니다. 당사자는 제출한 준비서면을 진술하지 않고 철회할 수 있다.

준비서면인지 여부는 그 내용에 의하여 정해지는 것이고, 서면의 표제에 따르는 것은 아니다. 소장에는 준비서면에 관한 규정이 준용되므로(민소 249조 2항) 임의적 기재사항으로 공격방법을 적을 수도 있고, 이 경우에는 그

한도 내에서 준비서면의 성격도 갖게 되며, 이는 상소장도 마찬가지이다(398조).

한편 소변경신청서(민소 262조), 중간확인의 소에 관한 서면(264조), 반소장(269조) 등은 어느 것이나 소송중의 소의 제기에 관한 것이고 소장에 준하는 것이지 준비서면 자체는 아니다. 상소장, 부대상소장은 물론 상고이유서도 그 제출이 강제되어 있는 것이므로 준비서면은 아니다.

준비서면에는 통상의 준비서면 외에 답변서와 요약준비서면이 있다. 답변서에 관하여는 제3절 참조.

(2) 요약준비서면

당사자 사이에 법정공방이 과열됨에 따라 비슷한 주장이 되풀이되거나 여러 번 준비서면이 제출됨으로써 공격방어방법의 요지를 파악하기 어렵게 되는 경우가 실무상 흔히 발견된다. 재판장은 이와 같이 당사자의 공격방어방법의 요지를 파악하기 어렵다고 인정되는 때에는 쟁점정리를 위한 변론 또는 변론준비절차를 종결하기에 앞서 당사자에게 쟁점과 증거의 정리 결과를 요약한 준비서면을 제출하도록 할 수 있다(민소 278조, 286조).

특히 사안과 쟁점이 복잡다기하여 심리가 장기간 이루어진 사건에서는 요약준비서면의 적절한 활용이 요망된다. 요약준비서면은, 법원이 그것만 읽어 보고도 공격방어방법을 파악·정리할 수 있는 수준에 이르러야 하므로, 특정 부분을 참조하는 뜻을 적는 방법으로 소장, 답변서 또는 앞서 제출한 준비서면의 전부 또는 일부를 인용하여서는 아니 된다(민소규 69조의5).

요약준비서면이 제출되면, 법원은 그 준비서면에 의해서만 판단하면 되고 그에 적혀 있지 않은 종전의 공격방어방법은 철회된 것으로 보아 판단하지 아니하여도 무방한지에 관하여는 명문의 규정이 없어 의문의 여지가 있으므로, 실무에서는 사전에 “종전의 준비서면을 갈음하는” 요약준비서면의 제출을 명하고 그 진술 시에 당사자의 의사를 확인하여 “요약준비서면과 상충되거나 기재가 없는 주장은 모두 철회한다.”라는 취지의 진술을 한 것으로 정

리하는 예가 많다. 이러한 경우 요약준비서면의 제출을 명령받은 당사자는 종전까지 제출한 공격방어방법 중 판단에 필요한 사항을 빠짐없이 종합·정리하도록 유의하여야 한다.

재판장등의 준비서면 제출명령은 변론준비의 지휘에 관한 명령이므로 합의사건에서 그 제출명령에 불복이 있는 당사자는 이의를 신청할 수 있다(민소 286조, 138조, 137조).

다만 요약준비서면의 제출명령에 불응한 당사자에 대한 제재가 없으므로 이 제도의 실효성이 문제될 수 있는데, 이때에는 취지가 분명하지 아니한 공격방어방법에 대하여 석명에 응하지 아니한 경우 이를 이유로 각하할 수 있도록 한 규정(민소 149조 2항)에 근거하여, 요약준비서면을 제출하지 아니한 당사자에 대하여 위 공격방어방법 각하의 요건을 갖춘 경우에 그 규정에 따라 각하하는 수밖에 없다.

(3) 기재사항, 작성방법 및 분량

가) 총 설

준비서면의 기재사항은 민사소송법 274조에 규정되어 있는데 1, 2, 3호 및 6, 7, 8호는 형식적 기재사항이고 4호 및 5호는 실질적 기재사항이다. 실질적 기재사항은 준비서면의 실질적 내용을 이루는 것이므로 반드시 적어야 하며, 이 기재가 없다면 가사 그 서면의 표제가 준비서면으로 되어 있더라도 준비서면으로서의 효력이 없다. 형식적 기재사항은 부수적인 사항에 불과하므로 일부 빠졌다 하더라도 준비서면으로서의 효력에는 영향이 없다.

준비서면에는 당사자 또는 대리인이 기명날인 또는 서명하여야 한다(민소 274조 1항). 누가 작성자인지 알아볼 수 있다면 서명 또는 기명만 있고 날인이 없어도 무방하다(대법원 1978. 12. 26. 선고 77다1362 판결). 준비서면에는 인지를 붙일 필요가 없으나 거기에 본안 또는 소송상의 신청이 적혀 있다면 인지를 붙여야 한다(인지 10조 단서 참조).

준비서면은 간결한 문장으로 분명하게 작성하여야 하고, 특별한 사정이

없으면 다음 양식에 따라 세워서 적어야 한다(민소규 4조).

① 용지는 A4(가로 210㎜×세로 297㎜) 크기로 하고, 위로부터 45㎜, 왼쪽 및 오른쪽으로부터 각각 20㎜, 아래로부터 30㎜(장수 표시 제외)의 여백을 둔다.

② 글자크기는 12포인트(가로 4.2㎜×세로 4.2㎜) 이상으로 하고, 줄간격은 200% 또는 1.5줄 이상으로 한다.

(나) 형식적 기재사항

1호의 당사자와 2호의 대리인의 표시에 관하여는 제16장(소의 제기) 제2절 2. 참조.

3호의 ‘사건의 표시’는 사건번호와 사건명에 의하여 사건의 동일성을 밝히는 것이지만 사건번호만 적어도 좋다.

6호의 ‘덧붙인 서류’는 준비서면에 인용한 문서의 등본 또는 사본(민소 275조 1항), 그 밖에 위임장, 가족관계등록사항증명서, 자격증명서 등 준비서면에 덧붙여 제출한 서류의 목록과 통수를 적는다.

7호의 ‘작성한 날짜’는 준비서면의 작성일을 적는다.

8호의 ‘법원’은 당해 사건이 계속 중인 관청으로서의 법원을 적으면 충분하나 실제로는 사건을 배당받은 재판부까지도 표시함이 통례이다.

(다) 실질적 기재사항

4호의 ‘공격방어방법’에 관하여는 제21장(변론) 참조.

5호의 ‘상대방의 청구와 공격 또는 방어의 방법에 대한 진술’이란 상대방의 청구에 대한 판결사항의 신청(소의 각하 또는 청구기각의 신청)과 개개의 공격방어방법, 즉 청구를 이유 있게 하는 진술, 항변, 재항변 등으로 주장된 사실에 대한 인부(인정, 부지, 부인)의 진술을 말하는 것으로 이에 의하여 쟁점을 명확하게 할 수 있게 된다.

준비서면에 공격방어방법과 상대방의 청구 및 공격방어방법에 대한 진술을 적을 때에는 사실상 주장을 증명하기 위한 증거방법과 상대방의 증거방

법에 대한 의견을 함께 적어야 한다(민소 274조 2항).

(라) 분량의 제한 등

준비서면의 분량은 재판장등과 당사자 사이에 민사소송규칙 70조 4항에 의한 합의가 이루어진 경우를 제외하고는 30쪽을 넘어서는 안 되고, 재판장등은 이를 어긴 당사자에게 해당 준비서면을 30쪽 이내로 줄여 제출하도록 명할 수 있다(민소규 69조의4 1항, 2항). 또한 준비서면에는 소장, 답변서, 앞서 제출한 준비서면과 중복·유사한 내용을 불필요하게 반복 기재하여서는 아니 된다(3항).

한편 법원은 제출자의 의견을 들어 변론기일이나 변론준비기일에서 진술되지 아니한 준비서면 등 불필요한 소송서류를 돌려주거나 폐기할 수 있는 데(민소규 4조 3항), 이를 통해 분량제한 규정을 위반하거나 내용이 정리되지 아니한 준비서면은 당사자나 대리인과 협의하여 반환 또는 폐기하고 간결한 준비서면을 제출하도록 유도하는 실무 운용이 가능하다.

(마) 인용문서의 첨부

당사자가 가지고 있는 문서로서 준비서면에 인용한 것은 준비서면에 그 등본 또는 사본을 붙여야 한다(민소 275조 1항). 문서의 일부가 필요한 때에는 그 부분에 대한 초본을 붙이고, 문서가 많을 때에는 그 문서를 표시하면 된다(2항). 준비서면은 그 부분을 상대방에게 송달하여야 하는데(273조 후단), 현행 민사소송법은 서증 인부에 관한 의견을 미리 준비서면에 기재하도록 하고 있으므로(274조 2항 참조), 이 경우에 준비서면에 붙인 문서나 당사자가 변론에서 제출할 서증으로서 준비서면에 붙여 낸 것도 준비서면과 함께 상대방에게 송달하여야 한다. 다만 그 문서의 분량이 송달하기에 부적당할 정도로 많은 경우 등에는 기록과 함께 보관하다가 법정에서 교부하거나 상대방에게 연락하여 법원에 와서 받아가도록 할 수도 있을 것이다.

외국어로 작성된 문서에는 그 번역문을 첨부하여야 한다(민소 277조). 당사자가 가지고 있는 문서로서 준비서면에 인용한 것은 상대방이 요구하면

그 원본을 보여주어야 한다(275조 3항).

(4) 준비서면의 제출 및 송달

가) 부분의 제출

준비서면의 교환은 원칙적으로 법원을 통하여 이루어지므로(민소 273조 후단), 당사자는 상대방에게 송달하는 데 필요한 수의 부분을 원본과 함께 법원에 제출하여야 한다(민소규 48조 1항). 상대방이 여러 명 있더라도 공동으로 한 사람의 소송대리인이 선임되어 있는 때에는 그 소송대리인에게 송달할 부분 1통이면 되고, 한 사람의 상대방에게 소송대리인이 여러 명 있는 때에도 각자가 상대방을 대리하므로(민소 93조) 원칙적으로 1통의 부분으로 충분하다. 이때 여러 소송대리인 중 주로 변론에 관여하는 대리인에게 송달함이 바람직하므로, 경우에 따라 준비서면을 송달받을 대리인이 누구인지 미리 신고하도록 안내할 필요가 있다.

현재는 대부분 전자파일로 문서를 작성하고 있고 법원으로서도 준비서면의 전자파일이 필요한 경우도 있으므로, 법원은 전자소송이 아닌 경우라도 필요하다고 인정하는 때에는 준비서면 등의 소송서류를 제출한 사람에게 그 문서의 전자파일을 전자우편이나 그 밖에 적당한 방법으로 법원에 보내도록 요청할 수 있다(민소규 48조 2항). 준비서면 원본의 제출을 갈음하여 전자파일의 제출을 명하는 취지는 아니고, 그 원본과는 별도로 전자파일을 제출받아 이를 활용하고자 하는 취지이다. 다만 준비서면을 제출한 사람이 이 요청에 불응하는 경우를 상정한 별도의 제재 규정은 마련되어 있지 않다.

한편 전자소송시스템의 활용도를 높여 충실한 심리를 뒷받침하기 위해 2018. 1. 1.부터 전자소송 이용자에 대하여 부득이한 사정이 없는 한 문자정보의 검색 및 추출이 가능한 파일로 문서(서증 제외)를 제출하도록 하였으므로(민전규 8조 4항), 전자소송 이용자가 출력문서를 스캔하거나 전자문서를 암호화하는 등으로 문자정보의 검색과 추출이 불가능한 파일을 제출한 경우 위 규정에 근거하여 보정을 명할 수 있다.

(나) 제출시기

준비서면은 원칙적으로 제소 이후 변론 종결 시까지 어느 때나 제출할 수 있다. 그러나 현행 민사소송법은 공격 또는 방어의 방법은 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하여야 한다(적시제출주의, 민소 146조)고 규정하고 있으므로, 그에 따른 제출시기의 제한이 있다. 특히 재판장은 당사자의 의견을 들어 한쪽 또는 양쪽 당사자에 대하여 특정한 사항에 관하여 주장을 제출하거나 증거를 신청할 기간을 정할 수 있고, 그 기간을 넘긴 때에는 원칙적으로 주장을 제출하거나 증거를 신청할 수 없다(재정기간 제도, 147조). 나아가 소송에 관하여 변론준비기일이 열린 때에는, 준비서면은 원칙적으로 변론준비기일이 종결되기 전까지 제출하여야 한다(285조 1항 참조). 이를 위반한 경우의 실권효에 관하여는 제4절 참조.

준비서면의 제출기간을 준수하지 아니한 경우에 재판장등은 준비서면에 기재된 공격방어방법을 적시제출주의 위반을 이유로 각하하거나(민소 149조), 준비서면을 늦게 제출하여 소송이 지연된 때에는 승소의 경우에도 이로 인한 비용을 부담시키거나(100조), 당사자의 법정대리인이나 소송대리인의 고의 또는 중과실로 인하여 무익한 비용을 지급하게 한 경우에는 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 그에게 비용을 갚도록 명하는 등(107조)의 조치를 적절히 활용하는 것이 바람직하다.

한편 준비서면은 예고적 기능을 다하기 위한 것인 만큼 그 기재사항에 대하여 상대방이 준비하는 데 필요한 기간을 두고 제출하여야 한다(민소 273조 전단). 기일에 임박하여 준비서면이 제출되면 법원이 그 준비서면을 검토하거나 상대방이 준비서면에 적힌 사항에 대하여 변론을 준비할 시간이 없게 되고, 그로 인하여 불가피하게 기일이 공전되는 사례가 있으므로 변론의 집중을 위하여 준비서면을 제출할 시간상 제약을 가할 필요가 있다. 여기서 ‘준비하는 데 필요한 기간’이란 상대방에게 송달할 시간과 상대방이 이에 대한 응답을 준비함에 필요할 시간을 포함하는 것으로서 그 기간의 장단은 당

사자가 준비서면에 적은 사항과 관련하여 구체적으로 결정될 문제이다. 준비서면에 적혀 있는 사항이 전혀 새로운 공격방어방법인가, 단지 종래의 변론을 보충함에 그치는 것인가에 따라 소요되는 시간이 달라질 것이기 때문이다. 순수한 법률의 해석·적용에 관한 의견진술은 법원의 직권사항에 관한 것이므로 원칙적으로는 그에 대한 상대방의 준비기간은 필요 없다. 민사소송규칙은 “새로운 공격방어방법을 포함한 준비서면은 변론기일 또는 변론준비기일의 7일 전까지 상대방에게 송달될 수 있도록 적당한 시기에 제출하여야 한다.”라고 규정하고 있다(민소규 69조의3).

(다) 준비서면의 송달

법원은 준비서면의 부분을 상대방에게 송달하여야 한다(민소 273조 후단). 준비서면이 접수되면 바로 송달함이 원칙이고, 송달의 방식은 민사소송법 174조 이하의 규정에 의한다. 전화·팩시밀리·전자우편 또는 휴대전화 문자 전송을 이용한 송달(민소규 46조), 변호사에 의한 사적 송달(47조) 및 법원 안에 있는 송달함을 이용한 송달(민소 188조) 등도 가능하다. 자세한 내용은 제 20장(송달) 참조.

(라) 준비서면의 부진술

당사자가 준비서면 등을 제출한 후 변론(준비)기일에서 이를 진술하지 아니하는 경우에는 그 제출 당사자의 의견을 들어 해당 준비서면을 돌려주거나 폐기할 수 있다(민소규 4조 3항). 그렇지 않더라도 제출 당사자로 하여금 당해 준비서면 등에 “부진술”이란 취지를 적고 날인하도록 하거나, 재판장이 그 취지를 적고 날인하는 것이 재판부의 변경이나 상소심에서의 기록 검토 시 혼란을 방지할 수 있다. 전자기록뷰어의 기록목록에 있는 진행 항목에 ‘부진술’로 표시하는 것이 실무이다.

(5) 제출·부제출의 효과

(가) 개 요

민사소송법은 준비서면에 의한 변론준비를 권장하기 위해 준비서면을 제

출하지 아니하거나 주장사실을 준비서면에 적지 아니한 경우에는 불이익을 받도록 하는 한편 그에 의한 변론준비를 완료한 때에는 유리한 취급을 받도록 규정하고 있다.

단독사건의 변론은 서면으로 준비하지 아니할 수 있고, 다만 상대방이 준비하지 않고서는 진술할 수 없는 사항에 관해서만 준비서면의 제출이 요구되지만(민소 272조 2항), 실무상 단독사건의 경우에도 서면으로 준비하지 않는 변론은 찾아보기 어렵다.

(나) 준비서면을 제출하지 아니한 경우

합의사건의 경우, 준비서면에 적지 아니한 사실은 상대방이 출석하지 아니한 때에는 변론에서 주장하지 못한다(민소 276조. 단독사건의 경우에도 민소 272조 2항 단서에 해당할 때에는 마찬가지이다). 상대방이 출석하지 아니한 변론(준비)기일에서 당사자가 준비서면에 적지 아니한 새로운 사실을 주장할 수 있게 한다면 상대방은 전혀 예상하지 아니한 소송자료에 기하여 판결을 받게 되어 불합리할 뿐 아니라 출석한 당사자의 사실상의 주장에 대하여 반대진술의 기회가 부여되지 아니한 채 이를 자백한 것으로 간주되어(150조 3항) 공격방어의 기회를 평등하게 부여하여야 한다는 쌍방심리주의의 원칙에도 어긋나기 때문이다. 피고가 출석하지 아니한 기일에 원고에게 청구원인에 관하여 석명하여 이를 변경하게 함으로써 피고에게 방어 기회 주지 아니한 채 심리종결하는 것도 허용되지 않는다(대법원 1964. 11. 30. 선고 64다991 판결).

상대방이 출석하지 아니하여 주장할 수 없는 것은 사실(주요사실과 간접사실을 포함함)에 관한 것에 한하며 단순한 법률상 견해의 진술, 증거조사의 결과에 관한 의견의 진술, 상대방이 충분히 예견할 수 있는 상대방의 주장사실에 관한 인부는 포함되지 아니한다. 법률상 견해의 진술은 참고자료에 불과하고, 그 나머지는 상대방이 능히 예상할 수 있는 사항이므로, 상대방의 절차권을 침해하지 않기 때문이다.

증거의 신청도 사전에 서면에 의한 준비가 필요한지에 관하여, 실무는 증거신청 가운데 적어도 상대방이 예상할 수 있는 사실에 관한 증거신청 정도이면 여기의 '사실'에서 제외시켜 증거신청을 허용하고 있다.

상대방이 출석하지 아니한 경우에 준비서면에 적지 아니한 사실을 주장할 수 없도록 한 것은 상대방을 보호하기 위한 것이므로, 상대방이 출석하지 아니한 기일에 법원이 준비서면에 적지 아니한 사실 또는 상대방에게 송달되지 아니한 준비서면의 기재사실을 진술하게 하고 이에 대한 증거신청을 채택하였다 하더라도, 상대방이 소송절차에 관한 이익권을 포기하거나 바로 이익하지 아니함으로써 이익권을 상실하게 되면(민소 151조) 그 진술이나 증거신청의 위법은 치유된다(대법원 1954. 2. 27. 선고 4286민상19, 20 판결).

상대방이 출석하지 아니한 경우 준비서면에 적지 아니한 사실을 주장하려면 속행기일의 지정을 구하여 그때까지 준비서면을 제출하여야 한다.

그러나 준비서면에 적지 아니한 사실이라도 상대방이 출석한 경우에는 주장할 수 있다. 다만 민사소송법 272조의 규정 취지에 비추어 미리 예고하지 아니하였기 때문에 상대방이 즉시 답변할 수 없는 때에는 기일을 속행하여 상대방에게 답변을 준비할 수 있는 기회를 부여하는 진행이 바람직하고, 그로 인해 소송이 지연된 때에는 당사자가 승소하더라도 지연으로 말미암은 소송비용의 전부나 일부를 승소한 당사자에게 부담하게 할 수 있다(민소 100조 참조).

(다) 준비서면을 제출한 경우

준비서면을 제출한 때에는 상대방이 변론(준비)기일에 출석하지 않더라도 그 기재사실을 주장할 수 있고, 상대방이 변론 전체의 취지에 의하여 그 사실을 다룬다고 인정되는 경우 이외에는 이를 자백한 것으로 간주되므로(민소 150조 3항) 그에 관한 증명책임을 면하게 된다. 또한 이를 제출한 당사자가 변론(준비)기일에 출석하지 아니하여도 그 기재사항을 진술한 것으로 간주할 수 있으므로(148조, 286조) 불출석한 당사자의 불이익을 줄일 수 있다. 그러나 불출석으로 인한 불이익의 위험이 이로써 완전히 없어지는 것은 아니다.

준비서면은 어디까지나 변론의 예고에 그치는 것이기 때문에 이를 제출한 것만으로 소송자료가 될 수 없으며(예외: 민소 148조) 소송자료가 되기 위해서는 변론에서 진술이 이루어져야 한다(대법원 2001. 12. 14. 선고 2001므1728 판결). 따라서 당사자는 준비서면을 제출한 뒤에도 이를 진술하지 않고 그 기재사항을 정정할 수 있다. 이처럼 준비서면은 반드시 변론(준비)기일에서 진술 또는 진술간주되어야만 하는 점에서 증거의 신청과 다르다. 기일에서 실시하는 증거조사와 달리 증거의 신청은 변론기일 전에도 할 수 있다(289조 2항 참조).

변론준비절차 전에 제출한 준비서면에 적은 사항은 변론준비기일에서 진술하지 아니하였더라도 변론에서 주장할 수 있다(민소 285조 3항).

피고가 본안에 관한 준비서면을 제출한 후에는 변론을 하기 전이더라도 소취하에 관하여 피고의 동의가 필요하게 된다(민소 266조 2항).

라. 준비서면의 공방

(1) 공방의 개시

서면공방절차, 즉 서면에 의한 변론준비절차에서는 참여사무관등이 재판장의 지시에 따라 절차진행을 관리한다. 준비서면의 공방은 피고의 답변서를 원고에게 송달하면서 원고에게 일정한 기한 안에 반박 준비서면과 필요한 증거를 제출하도록 하는 재판장 명의의 준비명령[전산양식 A1502] 또는 참여사무관등 명의의 준비권고[전산양식 A1502-1]를 보내는 것으로 시작되는데, 이것이 원고에 대해서는 최초의 송달기회이므로 이때 소송절차안내서[전산양식 A1176]와 준비서면 요약표[전산양식 A1521]도 함께 보낸다. 이어 원고로부터 반박 준비서면이 제출되면 이를 피고에게 송달하는데, 이때 참여사무관등은 신속한 기록검토를 위하여 피고에게 다시 반박서면의 제출을 최고하지는 아니한 채 바로 기록을 정리하여 재판장에게 인계한다[사건관리 예규 10. 나. (4)]. 특히 참여사무관등은 같은 내용의 준비서면이 반복 제출되

거나, 준비서면에 더 이상 주장할 사항이 없음 또는 기일지정을 바란다는 뜻을 밝혔음에도 형식적으로 서면공방이 지속되지 않도록 주의하여야 한다.

서면공방의 개시와 관련하여 문제가 되는 것은 피고별로 답변서 제출 시기가 다르거나 또는 여러 피고들 중 일부에 대하여 소장부분이 송달불능된 경우, 어느 시점에서 원고에게 반박 준비서면을 제출하도록 할 것인가 하는 점이다.

먼저, 소장부분을 여러 피고들에게 동시에 발송하더라도 실제 송달된 날짜는 다를 수 있고, 각 피고가 답변서를 제출하는 시기는 각자 소장부분을 송달 받은 날부터 30일 내라 하더라도 다양하게 분포될 수 있다. 이와 같이 피고들 모두에 대하여 소장부분이 정상적으로 송달된 때에는 원칙적으로 피고들에 대한 답변서 제출기간이 모두 만료될 때까지 기다렸다가 그 당시까지 제출된 답변서를 일괄하여 원고에게 송달함으로써 서면공방절차를 개시한다. 서면공방절차에서 각 당사자별로 따로 준비서면 제출기한을 관리하고 점검하는 것은 절차상 여러 가지 어려움이 따를 수 있으므로, 사건 단위로 기한을 관리하고 점검하는 것이 효율적인 사건관리를 위하여 바람직하기 때문이다. 다만 피고별 답변서 제출 여부를 별도로 관리하는 데 따른 번거로움을 피하기 위해 개별 피고가 제출하는 답변서를 바로 원고에게 송달하는 실무도 있다.

다음으로, 일부 피고에 대해서는 소장부분이 송달불능된 반면 송달을 받은 다른 피고들은 원고의 주장사실을 다투는 내용의 답변서를 제출한 경우, 송달불능이 된 피고들에 대해서도 주소보정명령 등을 거쳐 소장부분이 모두 송달되도록 하고 그 피고들의 답변서 제출기한까지 기다렸다가 그때까지 제출된 답변서를 일괄하여 원고에게 송달함으로써 서면공방을 개시하는 방식이 있을 수 있다. 이 방식은 절차진행 측면에서는 편리하겠지만, 이미 답변서를 제출하여 다투는 피고들에 대하여 절차가 장기간 지연될 수 있으므로 소송절차의 신속성과 효율성을 저해할 우려가 크다. 따라서 이러한 경우에는 다투는 피고들에 대해서 먼저 변론준비절차에 부쳐 서면공방절차를 개시하고 송달불능된 피고에 대해서는 주소보정을 명하는 등 피고별로 절차를

분리하여 병렬적으로 진행하는 방식이 타당하다. 이와 같이 서면공방절차와 주소보정절차를 병행하여 진행하면서, 그 후 송달불능된 피고가 소장부분을 송달받은 다음에 원고의 청구내용을 다룰 경우에는 종전에 이미 다투던 피고에 대해 제출하였던 원고의 준비서면 등을 일괄하여 새로 다투는 피고에게 송달하는 방식으로 절차를 진행하면 된다. 다만 이 경우에도 일부 피고에 대해 쟁점정리와 증거조사절차가 먼저 끝나더라도 곧바로 일부 판결을 하기 보다는 모든 피고들에 대하여 심리를 마친 다음 일괄하여 판결을 선고하는 것이 효율적이다.

(2) 준비서면의 제출기한

가) 제출기한의 설정

원고에게 반박 준비서면의 제출을 최고하는 때에는 제출기한을 설정하여야 한다. 반박 준비서면 등의 제출기한은 “이 답변서(준비서면)를 송달받은 날부터 3주일 안에”의 형식보다는 “○○년 ○월 ○일까지” 형식으로 마감날짜를 특정하여 보내는 것이 나중에 기한 안에 준비서면이 제출되었는지 여부를 점검하는 데 편리하다.

준비서면을 제출할 기한은 재판장의 준비명령(전산양식 A1502)이나 참여사무관등의 준비권고(전산양식 A1502-1)에서 정하는 기한이므로, 당사자의 의견을 들어 한쪽 또는 양쪽 당사자에 대하여 특정한 사항에 관하여 주장을 제출하거나 증거를 신청할 기간을 정하는 재정기간(민소 147조)과는 그 성질이 다르다는 점에 유의할 필요가 있다.

반박 준비서면 등의 제출기한은 개별 사건마다 따로 정하는 것보다는 미리 일정한 기준을 정하여 두는 것이 편리하며, 재판부 사이에도 그 기준을 가급적 통일하는 것이 당사자나 대리인의 혼란을 막고 그들로부터 원활한 협조를 얻는 데에 효과적이다. 실무상으로는 통상 답변서 발송일로부터 3주 정도로 제출기한을 정하고 있다(사건관리예규 10. 나. (1) 참조). 다만 쟁점이나 사실관계가 매우 복잡한 사건 등 특별한 사정이 있는 때에는 당사자에게

준비서면의 제출에 필요한 기간을 물어 상당한 기간을 부여하는 것이 효율적일 수 있다.

(나) 제출기한을 지키지 아니하는 경우의 대처방안

당사자가 정하여진 기한 안에 반박 준비서면 등을 제출하지 않으면 더 이상 주장·증명할 사항이 없는 것으로 보아 재판장의 기록심사에 회부하여야 한다. 참여사무관등은 제출기한이 지난 사건이 있는지 주기적으로 살펴서 사건이 적시에 처리될 수 있도록 하여야 한다[사건관리에규 10. 나. (3) 참조].

재판장은 기록심사를 토대로 더 이상 서면공방이 필요하지 않거나 서면공방만으로는 효율적인 쟁점정리가 곤란하다고 인정되는 경우 등에는 바로 쟁점정리를 위한 변론(준비)기일을 지정한다.

재판장의 기록심사 결과 서면공방을 계속하게 할 필요가 있는 때에는 참여사무관등을 통하여 준비서면의 제출을 촉구하거나 다시 준비명령이나 준비권고를 보내는 방식 등으로 서면공방의 속행을 명하며, 석명할 사항이 있는 때에는 석명준비명령을 발령한다. 아울러 효율적인 절차진행을 위하여 필요한 때에는 재정기간(민소 147조)의 설정도 검토한다.

아울러 서면공방 단계에서 제출기한이 준수되었는지를 효율적으로 관리하고 제출기한 도과에 적절하게 대처하기 위해서는 신속하고 정확한 전산입력과 전산을 통한 기한도과 사건의 주기적 점검 등이 요청된다는 점에도 주의하여야 한다.

(다) 제출기한 연장신청이 있는 경우의 처리

당사자로부터 준비서면 제출기한을 연장하여 달라는 취지의 신청이 있는 경우에는 신청사유에 대한 소명을 요구하여 합리적인 사유가 있는지 여부에 따라 신중하게 처리할 필요가 있다. 물론 이 경우 준비서면 제출기한의 연장을 허용하지 않는다고 하더라도 바로 실기한 공격방어방법으로서 각하하는 등의 불이익을 주기는 어렵겠지만, 연장신청의 경위와 그 사유의 소명에 관한 사항을 기록상 명확하게 하여 두는 것은 서면공방절차의 효율적이고 적정한

진행을 위하여 유용하기 때문이다. 부수적으로는 대리인 등으로 하여금 유사한 상황에서 제출기한 연장신청을 남용하지 못하게 하는 효과도 기대된다.

(3) 준비서면 요약표의 활용

참여사무관등은 당사자에게 준비명령 또는 준비권고를 송달하는 경우 준비서면 요약표[전산양식 A1521]를 함께 송달하여야 한다[사건관리예규 10. 나.

(2) 참조]. 이는 참여사무관등이 서면에 의한 쟁점정리절차를 실질적으로 관리함에 있어 편의를 제공하기 위한 것이자, 형식적인 서면공방이 방지되어 소송이 지연되는 것을 방지하기 위함이다.

[전산양식 A1521] 준비서면 요약표

제22장

사건관리 및 변론의 진행

〈준비서면 요약표〉

구분	의견 요약(해당란에 ☑ 표시)
중전 주장 대비	☐ 중전 주장을 보완 또는 보충함(새로운 주장 없음) ☐ 중전 주장과 실질적으로 다르거나 새로운 주장을 제출함 (주장의 요지:) ☐ 중전 주장을 모두 철회하고 새로운 주장을 제출함 (주장의 요지:)
절차진행에 관한 의견	☐ 화해¹⁾·조정²⁾ 희망 ☐ 기일 전 증거조사(문서송부촉탁·검증·감정·사실조회) 희망 ☐ 변론기일 지정 희망(조기 변론기일 지정 필요) ☐ 변론준비기일 지정 희망(변론 전 주장과 증거의 정리 필요) ☐ 기일지정 대기 희망(관련사건결과·감정결과 등 대기 필요) ☐ 기타 의견 ()
작성자: 20 . . . (서명 또는 ㉡)	

※ 이 〈준비서면 요약표〉의 해당 항목에 ☑ 표시를 한 다음, 준비서면의 표지 다음 장 (표지가 없는 경우에는 맨 앞장)에 붙여서 제출하시기 바랍니다.

1) 소송상 화해라 함은 소송의 계속 중에 수소법원·수명법관 또는 수탁판사 앞에서 당사자가 소송 물인 권리 또는 법률관계에 관하여 상호 그 주장을 양보함에 의하여 다툼을 해결하는 소송상 합의를 말합니다.

2) 민사조정제도란 민사에 관한 분쟁에 있어서 중립적인 제3자가 당사자의 동의를 얻어 당사자가 쉽게 협상할 수 있도록 도와주는 분쟁해결방법으로서, 법원은 특별한 사정이 없는 한 다툼 있는 사건에 대하여 소송절차의 어느 단계에서든 1회 이상 조정에 회부하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

(4) 공방의 횟수

서면공방의 횟수는 재판장이 정하게 되는데 실무상으로는 ① 모든 사건에 대하여 1회의 공방, 즉 피고의 답변서에 대한 원고의 반박 준비서면이 제출 되면 일단 서면공방을 완료하는 방식(사건관리예규 10. 나.), ② 당사자 본인 소송 등 특정 유형의 사건을 미리 지정하여 1회 공방을 원칙으로 운영하는 방식, ③ 원고 측 1회, 피고 측 2회를 원칙으로 하되, 서면공방 과정에서 접수되는 문건을 참여사무관등이 바로 검토하여 쟁점이 충분히 정리되었다고 판단되거나 서면공방을 계속하는 것이 무의미하다고 판단되는 사건은 2회 공방이 끝나기 전이라도 재판장에게 기록을 인계하는 방식 등이 이용되고 있다.

과거에는 원고 측 2회, 피고 측 2회의 서면공방을 마친 이후에 재판장이 사건분류를 하는 방식을 원칙으로 삼기도 하였다. 서면공방절차를 엄격하게 운영하지 아니하면 충분히 쟁점이 현출되지 않은 상태에서 제1회 변론기일이 형식적으로 진행됨으로써 종전의 분산심리방식으로 회귀할 가능성이 높다는 우려가 있었기 때문이다. 그러나 서면의 내용을 확인하지 않은 채 형식적인 횟수에만 주목하여 기계적으로 서면공방이 이루어지는 실무운영의 경우가 나타나면서, 사건처리가 지연·방치되는 폐해가 지적되었다. 심지어 쟁점과 무관한 사항에 관하여 무익한 공방이 반복되어 기록분량이 증가하고 기록검토에 큰 업무부담이 초래되는 한편 사소한 다툼으로 인한 감정적 대립을 유발하여 화해적 해결에 지장을 초래하기도 하였다.

이에 사건관리방식에 관한 예규가 수차례에 걸쳐 개정되어 표준적인 서면공방 횟수를 지속적으로 단축시켜 왔으며, 결국 현행 사건관리방식에 관한 예규는 서면공방 횟수에 관한 규정을 삭제하면서, 재판장의 조기 사건분류를 전제로 하는 ①을 원칙적인 처리방식으로 삼고 있다. 따라서 재판장이 달리 정한 바가 없는 한 위와 같은 1회의 공방이 끝나면 참여사무관등이 재판장에게 기록을 인계하여 소송의 지연을 막을 필요가 있다. 한편 재판장은 사건분류 단계에서 가능한 한 조속히 제1회 변론기일을 지정하되 그와 동시에

석명준비명령을 발하는 등 사전에 쟁점을 충분히 현출시키도록 유도함으로써 제1회 변론기일의 내실을 기할 필요가 있다.

(5) 당사자가 기일지정신청을 한 경우

서면공방 진행 중 한쪽 또는 양쪽 당사자가 더 이상의 주장이나 제출할 증거가 없다는 취지로 신속한 기일지정을 신청한 때에는 참여사무관등은 바로 재판장에게 기록을 인계하여야 한다. 이 단계에서는 재판부보다 당사자나 대리인이 쟁점이 충분히 부각되었는지를 더 잘 알고 있을 것이므로, 즉시 기록을 검토하여 기일을 지정하는 등 적절한 조치를 취할 필요가 있기 때문이다. 이러한 기일지정신청은 별도의 신청서로 이루어지는 경우 외에도 준비서면에 그 취지를 적어서 내는 사례가 빈번하므로, 참여사무관등은 이 점에도 유의할 필요가 있다. 이 경우에도 준비서면 요약표[전산양식 A1521]를 활용하면 유용할 것이다.

기록을 심사한 결과 쟁점이 충분히 부각되어 있으면 기일을 지정하게 되지만, 반대로 추가공방이 필요하거나 석명사항이 있으면 그에 상응하는 조치를 취하여야 한다.

(6) 공방의 기간

사건이 변론준비절차에 부쳐진 뒤 변론준비기일이 지정됨이 없이 4월이 지난 때에는 재판장등은 즉시 변론준비기일을 지정하거나 변론준비절차를 끝내야 하므로(민소 282조 2항), 준비서면의 공방기간은 4월 안에 마치는 것이 원칙이다. 따라서 준비서면의 공방을 진행할 때에는 이 기간을 염두에 두고 절차진행이 불필요하게 지연되지 아니하도록 유의할 필요가 있다. 이 기간의 기산일은 변론준비절차 회부명령이 고지된 때이고, 그 명령을 따로 고지하지 아니한 경우에는 변론준비절차의 일부를 이루는 준비명령 등이 처음으로 고지된 때가 된다.

다만 위 4월의 기간은 훈시규정으로 해석되므로 쟁점이 복잡하여 충분한 기간을 두고 준비서면의 공방을 할 필요가 있는 사건에서는 공방기간을 탄

력적으로 운영할 수 있다.

(7) 서면공방의 종료 및 증명촉구

서면공방의 마지막 단계에서 참여사무관등은 기일전 증거신청과 증인신청 상황 등을 다시 점검하여 전형적인 증거신청이 필요하다고 판단됨에도(예: 인신사고로 인한 손해배상사건에서의 신체감정, 관련 형사기록이 있는 사건에서의 문서송부촉탁 등) 증거신청이 이루어지지 아니하거나 증인신청서가 제출되지 아니한 경우에는, 당사자에 대하여 마지막 준비서면의 제출을 촉구하는 준비명령을 송달하는 기회에 증명촉구서[전산양식 A1550-1, A1551-1], 증인신청촉구서[전산양식 A1552-1]를 함께 보내는 방안을 활용할 필요가 있다(사건관리예규 12. 나. (1) 참조). 준비명령과 함께 증명촉구서면을 보내는 때에는 증거신청기한을 준비서면 제출기한과 같은 날로 정하는 것이 절차상 간명할 것이다.

원고의 마지막 준비서면이 제출되어 서면공방이 종료되면, 참여사무관등은 그 준비서면을 피고에게 송달한 후 곧바로 기록을 정리하여 재판부에 인계하게 된다. 원고의 마지막 준비서면을 송달한 때에는 피고에 대하여 준비명령을 보낼 필요가 없다(사건관리예규 10. 나. (4) 참조).

마. 기일전 증거의 신청 및 조사

민사소송법은 공격방어의 방법을 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하도록 하는 적시제출주의를 채택하고 있으므로(민소 146조), 변론준비기일의 종결일 또는 쟁점정리 및 절차협의를 완료된 후 그다음 변론기일까지는 양쪽 당사자의 '주장'과 함께 '증거관계'에 대한 정리를 완결하여야 하고, 증인신문·당사자신문을 제외한 모든 증거신청 및 증거자료의 현출도 가급적 쟁점정리 및 절차협의를 완료된 후 그다음 변론기일까지는 마쳐져야 한다.

다만 민사소송법이 채택한 적시제출주의의 구체적인 의미는 소송절차의 진행단계나 증거방법에 따라 차이가 있을 수 있다.

(1) 기본적인 서증은 소장 또는 답변서가 제출되는 단계에서 함께 제출되어야 한다(민소 254조 4항, 민소규 63조 2항, 65조 2항 등 참조). 제출된 서증의 사본은 그 주장서면과 함께 상대방에게 송부하여 미리 검토할 기회를 부여함으로써 첫 변론(준비)기일에 증거의 정리가 효율적으로 이루어질 수 있도록 하여야 한다. 당사자나 대리인은 쟁점이 되는 중요 서증에 대한 의견을 첫 변론(준비)기일 이전에 준비서면 등을 통하여 미리 밝혀야 한다(민소 274조 2항).

(2) 증거조사의 실시를 위하여 후속절차가 필요하거나 기간이 오래 걸리는 증거신청(예: 문서송부촉탁, 감정·검증·사실조회 등)은 소송절차의 초기 단계에 이루어져야 한다. 이러한 증거방법에 대한 조사결과가 가급적 쟁점정리기일 이전에 법원에 현출되어 상대방과 법원이 그 내용을 검토하는 것이 바람직하기 때문이다.

(3) 증인의 신청은 특별한 사정이 없는 한 서증 등 다른 증거방법의 제출 상황과 이에 대한 상대방의 의견 등을 고려하여 신청 여부와 범위를 정하게 되므로, 늦어도 쟁점정리 및 절차협의를 마친 후 그다음 변론기일까지는 완료되어야 할 것이다(사건관리예규 12. 가. (1) 참조). 다만 주장과 증거가 정리된 뒤에는 증거조사가 한 기일에 집중적으로 이루어져야 하므로, 증인신문은 부득이한 사정이 없는 한 일괄하여 신청하여야 한다(민소규 75조 1항).

각 증거방법에 따른 기일전 증거의 신청 및 조사의 구체적인 절차에 관하여는 제25장(증거조사) 참조.

바. 재판장의 기록 재심사 및 2차 사건분류

(1) 개요

변론준비절차에서 서면공방이 끝나고 재판장에게 기록이 인계되면 재판장에 의한 2차 사건분류가 이루어진다. 이 단계에서의 기록심사는 서면공방을 통해 주장 및 증거가 충분히 제출되고 쟁점이 부각되었는지를 점검하고 추

가서면공방을 할지 혹은 쟁점정리를 위한 기일을 지정할 것인지 등 사건의 진행방향을 결정하는 것을 목표로 하므로, 1차 사건분류 시점보다 더 충실한 기록검토가 필요하다.

현행 민사소송법에 의한 절차진행에서는, 관련사건의 결론을 기다리는 등 다른 특별한 사정이 없는 한, 소장접수로부터 서면공방과 재판장의 사건분류 및 기일전 증거조사를 거쳐 기일지정 이전 단계에 이르기까지 모든 사건이 휴면상태로 방치됨이 없이 계속적으로 절차진행이 이루어지지 않으면 안 된다. 위와 같은 단절 없는 절차진행이 가능하기 위한 가장 중요한 관건은 “재판장에 의한 적기의 충실한 사건분류”이다. 답변서 제출 단계 또는 준비절차 회부 후 서면공방이 완료된 단계에서 재판장이 제때 기록검토를 하고 향후 진행방향을 결정해 주는 사건분류를 하지 않으면, 사건은 그 상태에서 진행이 정지되고 더 이상 어떤 절차도 진전될 수 없기 때문이다.

따라서 참여사무관등은 재판사무시스템의 진행단계 중 C단계(재판장 검토 대상사건)의 사건이 적체되지 않는지를 수시로 확인·점검하여 적기에 기록을 인계하여야 하고, 재판장은 E-1단계(서면공방)로 넘어온 사건이 장기간 방치되는 일이 생기지 않도록 유념하여야 한다.

(2) 재판장의 기록 재심사

재판장이 기록을 재심사하는 순서는 사건번호순이 아니라 기록을 인계받은 순서, 즉 서면공방을 마친 순서로 하여야 한다.

재판장은 이 단계의 기록심사를 통하여 사건의 쟁점이 충분히 부각되었는지를 확인할 뿐 아니라, 제출된 증거를 검토·정리하고, 필요한 경우에는 증명촉구 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

서증에 관해서는 필요한 서증이 빠짐없이 제출되었는지를 확인하고 누락된 서증에 대해서는 석명준비명령 등으로 제출을 촉구하여, 제1회 변론(준비)기일 전까지 필요한 서증이 모두 제출되도록 하여야 한다. 또 제출된 서증에 대한 인부가 필요한지 여부를 파악하여 인부가 필요한 처분문서 등에

대해서는 석명준비명령 등을 통하여 상대방에게 인부의견을 밝히도록 하여야 한다. 이와 함께 제출된 서증의 증명취지와 문서의 내용을 개별적으로 확인하여 첫 변론(준비)기일에서의 채부결정을 준비하여야 한다.

한편 근래 IT기술의 급속한 발전으로 불필요한 준비서면이나 서증이 대량 제출되고, 재판장이 그 주장이나 증명취지를 개별적으로 확인하지 아니한 채 그대로 받아들임으로써 기록의 분량이 필요 이상으로 증대되는 경우가 자주 생기고 있는데, 이를 개선하기 위해서는 제출된 준비서면의 내용이나 서증의 증명취지를 개별적으로 확인하는 노력이 필요하다. 특히 참여사무관 등은 재판장의 지시를 받아 법원에 제출된 문서 중 당사자가 서증으로 제출하지 아니하거나, 서증으로 제출하였으나 증거로 채택되지 아니한 문서 또는 증거로 채택되었다가 증거채택이 취소된 문서, 변론기일이나 변론준비기일에서 진술되지 아니한 문서를 제출자에게 반환하거나 폐기하여야 하고, 공공기관으로부터 송부된 인증등본도 공공기관으로부터 반환 요청이 없는 한 서증 신청인에게 반환하거나 폐기하여야 하므로(문서 등의 반환·폐기 등에 관한 예규 2조 참조), 미리 그와 같은 조치를 취할 대상이 있는지 확인하여 둘 필요가 있다. 종이사건뿐만 아니라(민소규 4조 3항) 전자사건에서도 법원은 제출자의 의견을 들어 변론기일 또는 변론준비기일에서 진술하지 아니하거나 불필요한 전자문서를 돌려주거나 폐기할 수 있다(민전규 22조).

서증의 수가 방대하여 개별적으로 증명취지를 확인하기 곤란한 경우, 서증의 내용을 이해하기 어렵거나 그 증명취지가 불명확한 경우 또는 서증의 작성자나 그 작성일이 불명확한 경우 등에는 이 단계에서 당사자에게 증거설명서의 제출을 요구하여 서증 채부결정의 판단자료로 활용한다(민소규 106조 1항). 증거설명서(전산양식 A1870)에는 문서의 제목, 작성일, 작성자 및 증명취지 외에 원본의 소지 여부 등을 적어야 한다. 증명취지는 증명의 대상인 주요사실을 기재하는 외에, 사안에 따라서는 작성경위나 그 서증으로 구체적으로 증명하려는 간접사실을 함께 적는 것이 타당하다.

제22장

서증과 증인 등에 대한 채부결정은 원칙적으로 첫 변론(준비)기일에 이루어지게 되지만, 절차의 효율적인 운영을 위해서는 재판장의 기록 재심사 단계에서 서증이나 증인 등의 채택 여부를 미리 검토하여 방향을 설정하여 둘 필요가 있다.

(3) 2차 사건분류

재판장은 1차적으로 답변서 제출 단계에서 기록을 검토하여 원칙적으로 변론기일을 지정하고, 필요한 경우 변론준비절차에 회부한다. 이중 변론준비절차에 부쳐진 사건에 관하여 서면공방이 끝나고 나면 기록을 재검토한 후 2차적으로 사건을 분류하여 심리방향을 결정한다. 재판장은 사건을 분류하여 심리방향을 결정할 때에 대리인, 당사자 등과 기일 내에서는 물론 법정 밖에서도 양쪽 당사자와 음성의 송수신에 의하여 동시에 통화를 하거나 인터넷 화상장치를 이용하여 향후 기일진행의 방향과 일정 등을 협의하는 방법을 유용하게 활용할 수 있다(민소규 70조 2항 내지 5항). 재판장이 기록심사를 통하여 사건의 심리방향을 결정하게 되면 참여사무관등은 그 결과를 바로 재판사무시스템에 입력하여 사건의 진행단계를 변경하여야 한다.

(가) 석명준비명령 및 추가 서면공방

청구원인 및 항변 내용에 불명확한 점이 있는 경우에는 석명준비명령(민소 137조)을 한다. 이 석명준비명령[전산양식 A1504]에서 당사자가 '변론을 준비할 기한'이 특정되므로, 참여사무관등은 나중에 당사자의 준비서면 또는 증거신청 등이 기한 안에 이루어졌는지 여부를 확인하여, 기한 안에 당사자로부터 준비서면이 제출되지 않거나 필요한 증거신청이 이루어지지 않을 경우 전화·팩시밀리·전자우편 등으로 제출을 촉구한다(민소규 73조, 30조).

그런데 위와 같이 석명준비명령에서 특정하는 '변론을 준비할 기한'과 민사소송법 147조 1항의 규정에 의한 재정기간은 그 요건, 설정절차, 효과 등에 차이가 있음을 유의할 필요가 있다. 즉 서면공방의 진행경과 등에 비추어 통상적인 석명준비명령만으로 부족하다고 인정되는 때에는 서면이나 그 밖

에 적당한 방법으로 당사자의 의견을 들은 후 특정사항에 관하여 주장을 제출하거나 증거를 신청할 재정기간을 설정하여 석명준비명령을 할 수 있다. 이 경우에는 설정된 기한이 민사소송법 147조 1항의 규정에 따른 재정기간으로서, 그 기간을 넘긴 때에는 주장을 제출하거나 증거를 신청할 수 없다는 취지를 명시하는 것이 타당하다.

한편 따로 특정하여 석명할 사항은 없지만 사건의 성질상 추가공방이 필요한 경우, 원고의 마지막 준비서면에 새로운 공격방법이 제기되어 그에 대한 피고 측의 대응을 확인해 볼 필요가 있는 경우 등에는 피고에 대하여 원고의 마지막 준비서면에 대한 반박을 하도록 기한을 정한 재판장 명의의 준비명령 [전산양식 A1502] 또는 참여사무관등 명의의 준비권고[전산양식 A1502-1]를 보내어 추가 서면공방을 하도록 한다.

재판장의 기록심사를 거쳐 석명준비명령이 내려지거나 추가 서면공방을 명한 사건은 재판사무시스템의 진행단계를 'E-1. 서면공방'으로 분류하여 관리한다.

(나) 관련사건 또는 감정 결과등 대기

기록심사 결과 관련사건이 다른 법원에 계속 중이어서 그 결과를 기다려 보아야 하거나 수사진행 중인 사건과 같이 성질상 곧바로 기일지정을 할 수 없는 경우에는 양쪽 당사자로부터 기일에 관한 의견을 청취하여 관련사건 또는 수사 중인 사건의 완결 시 곧바로 법원에 그 사실을 고지하도록 안내한다. 나아가 관련사건 완결 사실이 자동으로 통지될 수 있도록 재판사무시스템에 직접 알림사건으로 등록하는 방법도 적극 활용하는 것이 바람직하다.

사실조회서나 감정서 또는 송부촉탁한 문서가 도착되지 않은 상태로 기록이 인계된 경우에는 참여사무관등으로 하여금 조회기관, 감정인, 송부촉탁기관 등에 그 결과 제출을 촉구하게 하고[사건관리예규 12. 나. (5)], 그 결과 또는 문서가 도착했을 때 다시 기록을 인계하도록 하는 등 적절한 조치를 취한다.

위와 같은 경우에는 재판사무시스템의 진행단계를 ‘E-2. 감정/조회 등 회신’이나 ‘E-4. 관련사건 결과’ 단계로 분류하여 관리한다.

(다) 화해권고결정 및 조정회부

사건의 성질에 비추어 화해적 해결이 적당하다고 인정되는 사건의 경우에는 화해권고결정(민소 225조)의 활용을 적극 검토하고, 아울러 조정이 필요하다고 판단되는 사건은 적극적으로 조정절차에 회부한다. 화해적 해결이 적당하다는 판단이 들면, 조정위원 또는 조정담당판사가 주도하는 조기조정 회부절차(통칭 ‘머’ 사건)를 이용할 것인지, 수소법원 조정을 이용할 것인지를 선택하여야 한다. 실무상 절차 초기에 화해적 해결을 시도하는 조정은 조정위원 또는 조정담당판사가 주도하는 조기조정으로, 실체에 관한 심리 후 시도하는 조정은 수소법원 조정으로 실시하는 경우가 많다. 수소법원에서 직접 조정을 할 사건의 경우에도 따로 조정기일을 정하는 방식과 변론(준비)기일을 지정하여 그 진행경과를 보아가면서 조정기일을 지정하는 방식 중에서 적절하게 선택할 수 있다.

화해권고결정을 하거나 조정을 갈음하는 결정을 한 후 그 이의 여부를 기다리는 사건은 ‘E-5. 결정/소취하(소취하간주) 등 확정 여부’ 단계로 분류하여 관리한다. 참여사무관등은 조기조정에 회부한 사건이 장기간 방치되지 않도록 정기적으로 확인하고, 사건이 조정불성립으로 돌아오면 지체 없이 재판장에게 보고하여야 한다. 재판장도 전산을 통해 주기적으로 조정불성립으로 돌아온 사건을 파악할 필요가 있다.

(라) 변론(준비)기일의 지정

쟁점이 드러나고 기일전 증거 제출이 완료된 사건은 변론기일 또는 변론준비기일을 지정하여 기일에서의 쟁점정리절차에 들어가게 된다. 쟁점정리를 위한 기일 운영의 형식으로는 변론기일 방식과 변론준비기일 방식이 있는데, 이중 변론기일 방식이 원칙이나, 내용이 복잡하거나 방대한 등으로 필요한 경우에는 변론준비기일 방식을 활용할 수 있다(민소 258조 1항 본문).

(4) 기일 미지정 사건의 정기적 점검

서면공방절차에서는 일정한 기간 단위로 기일을 진행하면서 그 과정에서 주기적으로 절차진행 상황을 점검하는 종래의 심리방식과 달리, 준비서면의 공방이 이미 끝났음에도 방치되거나 기일전 증거조사와 관련하여 결과회보의 독촉 등 적절한 조치가 이루어지지 아니한 상태로 있을 가능성이 상대적으로 높다. 이를 방지하고 서면공방절차가 효율적으로 진행되도록 하기 위해서는 참여사무관등의 적극적인 확인 노력이 긴요함은 물론이고, 재판부 역시 기일이 지정되지 아니한 사건을 전반적으로 정기 점검하는 것이 필요하다.

재판장은 'E. 기일지정 대기사건' 단계의 사건 등을 포함하여 기일이 지정되지 않은 모든 사건을 대상으로 1~2개월마다 진행상황을 확인·점검할 필요가 있다. 점검결과 누락되거나 방치되고 있는 사건은 구체적인 처리방향을 정하고 석명준비명령이나 감정 결과 회보독촉을 하는 등 진행단계에 상응하는 조치를 하여야 한다.

참여사무관등은 재판사무시스템을 활용하여 'C. 재판장 검토 대상사건' 및 'E-1 서면공방' 단계의 목록을 수시로 점검하여 서면공방이 끝난 후에도 방치되는 사건이 없도록 하여야 한다. 아울러 기일전 증거조사의 실시나 조사 결과의 도착과 관련하여 절차가 진행되지 아니한 채 그대로 방치되는 사례도 적지 아니하므로, 참여사무관등은 이 점에도 각별히 유의할 필요가 있다.

(5) 변론(준비)기일로의 이행

(가) 변론준비기일의 지정

재판장등은 서면에 의한 변론준비절차를 진행하는 동안에 주장 및 증거를 정리하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 변론준비기일을 지정한다(민소 282조 1항).

준비절차에 부친 경우라면 적시에 변론준비기일을 여는 것이 중요하다. 변론준비기일은 서면공방이 어느 정도 진행되고 재판장의 2차 기록심사까지

이루어진 후에 지정될 수도 있겠으나, 그 경우 사건처리가 지연되거나 방치될 수 있다. 따라서 재판장은 사건의 신속한 진행을 위하여 필요한 때에는 사건을 변론준비절차에 부침과 동시에 변론준비기일을 지정함으로써(민소규 69조 3항) 서면공방 선행에 따른 지연 및 방치를 미연에 방지할 필요가 있다.

변론준비기일이 지정되면 서면에 의한 쟁점정리절차는 종료되고, 지정된 변론준비기일을 입력함에 따라 재판사무시스템상의 진행단계가 'D-3. 변론준비기일지정'로 자동변경된다. 다만 서면에 의한 쟁점정리절차와 변론준비기일은 모두 변론준비절차의 일부로서 그 진행주체가 동일할 뿐 아니라 서면에 의한 변론준비절차의 종결만으로는 실권효가 생기지 않으므로, 소송절차상으로는 따로 조치를 취할 필요가 없다.

사건이 변론준비절차에 부쳐진 뒤 변론준비기일이 지정됨이 없이 4월이 지난 때에는 재판장등은 즉시 변론준비기일을 지정하거나 변론준비절차를 종결하여야 한다(민소 282조 2항).

(나) 변론기일의 지정

변론준비절차에 부친 사건에서 서면에 의한 쟁점정리 단계를 거쳐 재판장등이 바로 변론기일을 쟁점정리를 위한 기일로 지정하면, 변론준비절차가 종결된다. 변론준비절차가 종결된 후로는 증거결정과 증거조사 등을 수소법원의 이름으로 하여야 하는 등 소송절차의 진행주체와 방식에 변화가 생기는데, 이 경우 변론준비절차를 종결한다는 취지의 재판서를 별도로 작성할 수도 있지만, 그러한 재판서 작성 없이 변론준비절차 종료를 전제로 바로 당사자에게 변론기일통지서를 송달하는 것이 실무이다.

실무상으로는 변론기일까지 장기간 기다려야 하여 그 대기기간을 활용하여 심리를 진행할 필요가 있는 등의 예외적인 경우가 아닌 한 변론준비기일 지정 없이 오로지 서면공방을 위하여 변론준비절차에 부치는 경우는 거의 없다. 답변서 제출 단계에서의 사건분류에 따라 바로 변론기일을 지정하는 경우에도, 다투는 사건의 경우 통상 제1회 변론기일 이전에 추가 서면공방

이 이루어지고 있고, 변론준비기일을 거치지 아니한 경우에는 실권효도 발생하지 않으므로(민소 285조 참조) 변론준비기일 지정 없이 서면공방만을 위한 변론준비절차를 이용할 실익이 크지 않기 때문이다.

5. 변론준비기일

가. 의의와 활용범위

(1) 의 의

변론준비기일은 변론준비절차에 부쳐진 사건에서 장차 변론기일이 효율적으로 운영될 수 있도록 미리 양쪽 당사자의 주장과 증거를 정리하는 기일이다(민소 282조 참조).

현행 민사사건 심리방식에서 주요 심리내용을 기준으로 한 기일의 유형은 크게 보아 쟁점정리기일과 집중증거조사기일의 두 가지로 분류할 수 있다. 그중 쟁점정리기일은 이어지는 집중증거조사기일에 모든 증거조사를 마치고 심리를 종결하기 위한 준비를 하는 기회인데, 이를 운영하는 구체적인 방식에는 변론기일 방식과 변론준비기일 방식이 있다. 기일은 쟁점의 현출과 정리를 집약하여 최소화된 횟수로 진행하여야 하므로, 쟁점정리기일도 가급적 1회의 진행으로 마치는 것을 기본으로 한다. 나아가 그 기일에는 주장과 반박에 의한 진정한 법적 공방이 전개됨으로써, 당사자나 방청객이 기일의 진행상황을 지켜보는 것만으로도 심리가 어느 쪽 당사자에게 유리하게 진행되고 있는지를 짐작할 수 있도록 운영되는 것이 바람직하다.

이처럼 변론준비기일 방식에서의 변론준비기일과 변론기일 방식에서의 제 1회 변론기일은 다 같이 실질적으로 쟁점정리를 위한 기일의 성격을 가지고 있는바, 따라서 집중증거조사를 제외한 모든 논리공방과 구술심리가 위 두 가지 방식의 기일 중 어느 것에 의해서든 이루어질 수 있다. 그중 변론준비기일방식의 경우, 종래에는 합의부원 중 일부가 수명법관이 되어 절차진행을 맡아 할 수 있으므로 업무처리의 효율성을 높일 수 있다거나, 법정 밖에

서 비공개로도 진행할 수 있어 당사자 본인으로 하여금 직접 법관의 면전에서 하고 싶은 말을 할 수 있는 기회를 제공하는 데 유리하다는 점이 장점으로 거론되기도 하였다.

그러나 변론준비기일은 어디까지나 변론을 준비하는 기일일 뿐 변론기일과 동일시할 수는 없으므로, 변론준비기일을 변론기일처럼 운영하는 것은 공개주의·직접주의의 원칙에 반한다는 지적이 대두되었다. 이러한 점을 고려하여 2008. 12. 26. 개정된 민사소송법 258조 1항은 조기 제1회 변론기일 지정을 원칙으로 채택하는 한편 민사소송법 279조 1항 및 민사소송규칙 70조의2는 변론준비기일의 기능이 “변론이 효율적이고 집중적으로 실시될 수 있도록 주장과 증거를 정리”하는 데에 있음을 명확히 함으로써 변론기일과 변론준비기일을 준별하였다.

결국 동일하게 쟁점정리기일의 성격을 가지고 있더라도 제1회 변론기일은 양쪽 당사자의 집약적인 구술변론을 토대로 쟁점을 추출하는 한편 즉석에서 서증 기타 증거자료와 대조하는 등 필요한 증거조사를 실시함으로써 재판부 전원이 쟁점에 대한 1차적인 심증을 직접 형성하기 위한 기일이라 할 것이다. 반면 변론준비기일은 변론기일에 집약적인 구술심리가 이루어질 수 있도록 미리 양쪽의 주장과 증거를 정리하여 둘 필요가 있는 사건 등의 경우에 그러한 필요에 부응하는 한도 내에서 활용되는 기일이라고 할 수 있다.

(2) 활용범위

다음과 같은 유형의 사건은 변론준비기일을 거침으로써 실권효 등을 활용하여 불필요한 공방을 조기에 종식시키고 향후 변론기일이나 집중증거조사기일에서 증거조사가 필요한 쟁점을 확실하게 부각시키는 것이 바람직할 수 있다(사건관리예규 9. 다. 참조).

① 쟁점과 주장 내용이 복잡하거나 방대한 사건: 기본 서면공방으로 부족하여 추가로 서면공방을 거친 사건, 청구원인과 항변·재항변이 예비적 주장 등으로 복잡하게 섞여 있는 사건, 피고들 상호 간 또는 참가인 등과 사이에

이해관계가 상충하고 다양하게 얽힌 사건 등

② 전문적인 분야나 새로운 형태의 법률관계에 관한 사건: IT·생명공학 등 신기술 개발이 활발히 이루어져 사실 확정 및 판단에 감정인·전문심리위원 등 외부 전문가의 조력이 필요한 사건, 새로운 국제·금융거래, 엔터테인먼트 관련 분쟁 등 기존 법리로 해결이 어려운 유형의 분쟁으로 사실관계 파악 및 주장 이해에 상당한 시간과 노력이 필요한 사건 등

③ 주장 자체가 불분명하거나 서로 모순되는 사건: 수차례의 서면 공방을 통해서도 당사자의 주장이 논리적으로 명확하게 설명되지 않는 사건 또는 복수의 주장들 상호 간에 논리적 모순이 있거나 제출된 증거에 의해 밝혀진 사실관계와 상충되어 이를 정리하지 않고서는 변론기일에서의 쟁점정리 및 집중증거조사가 어렵다고 판단되는 사건 등

④ 증거가 많고 복잡하여 증명계획 등을 사전에 협의할 필요가 있는 사건: 증거의 내용이 방대하거나 전문적이어서 제출된 증거의 내용을 이해하기 어려운 사건, 양쪽 당사자가 제출한 처분문서의 내용이 서로 배치되거나 관련 민·형사 사건의 확정판결 내용이 엇갈리는 등 증명취지의 파악이 어려운 사건, 증거의 종류와 개수 등에 비추어 절차협의 없이는 증거조사의 집중을 도모하기 어려운 사건, 사건처리 시한을 미리 협의하여 적시에 처리하지 아니하면 분쟁이 근본적으로 해결되지 아니하는 사건, 당사자가 고의적으로 절차진행을 지연시키는 등 변론 집중을 위하여 실권효의 제재를 활용할 필요가 있는 사건 등

다만 위 각 경우 중 어느 하나에 해당하더라도, 당사자나 이해관계인이 다수이고 사회적 이목이나 언론의 관심이 집중되어 공개된 법정에서 치열한 공방이 예상되는 사건은 변론기일 방식을 적극적으로 활용할 수도 있을 것이다.

나. 변론준비기일의 준비

(1) 기일의 준비

(가) 서면공방결과와 파악과 사건장악

변론준비기일은 가능한 한 1회에 마치는 것을 원칙으로 하고 속행이 되더라도 최소한에 그쳐야 한다. 만약 변론준비기일이 여러 번에 걸쳐 속행이 되면, 쟁점의 분산에 따른 사건의 실체파악과 심증 형성의 어려움, 반복적인 기록검토에 따른 시간손실, 당사자나 대리인의 기일출석 불편 등의 문제가 발생할 염려가 있고, 피고가 재판기간을 부당하게 연장하는 데 악용될 수 있기 때문이다.

따라서 변론준비기일을 진행하기 전에 재판부와 소송관계인 모두가 철저한 사전준비를 하여야 한다. 특히 재판부가 서면공방 단계까지의 진행결과를 정확하게 파악하여 사건을 장악하는 것이 필수적이며 그러한 준비가 제대로 안 된 상태에서 변론준비기일에 들어가는 것은 지양하여야 한다.

(나) 증명추구와 석명

서면공방이 끝난 후 재판장이 기록을 검토하여 사건을 분류하는 단계에서 당사자들의 주장 제출이나 증거 신청이 충분하지 못한 경우 석명준비명령이나 증명추구서를 통하여 이를 보완하도록 한다. 석명준비명령의 송달은 팩시밀리·전자우편 등을 적극적으로 활용하여 절차의 지연을 피하도록 한다. 효율적인 쟁점정리를 위하여 반드시 필요함에도 당사자가 위와 같은 석명준비명령 등에 응하지 않을 때 또는 재판장의 기록심사 후 변론준비기일까지 사이에 새로 제출된 중요 서증에 대한 인부의견을 미리 밝히도록 할 필요가 있을 때 등에도 증명추구와 석명을 하게 된다.

(다) 중간합의

합의사건에서 사실관계가 복잡하거나 법률적인 쟁점이 특이한 문제인 경우 또는 법원이 미리 쟁점정리안이나 화해권고안을 만들어 기일에 당사자에게 제시할 필요가 있는 경우 등에는 변론준비기일 이전 시점에서 중간합의

를 거치는 것이 바람직할 수 있다. 반면 일반적인 사건에서라면 변론준비기일이 끝난 후 집중증거조사기일 직전 단계에서 변론준비기일의 주재자가 아닌 재판장이나 주심판사가 기록을 상세하게 검토한 다음 그때까지의 심리결과를 토대로 중간합의를 하는 방식이 권장된다.

(㉔) 쟁점정리안의 구상

다수의 쟁점이 복잡하게 얽혀 있거나 서로의 주장이 첨예하게 대립하는 사건의 경우에는 법원이 미리 서면공방결과를 기초로 쟁점사항을 정리하여 양쪽 당사자에게 보내고 이를 기초로 각자 변론준비기일에 할 진술을 요령 있게 준비하거나 쟁점정리서면을 작성·제출하도록 하는 것이 효율적일 수 있다.

(2) 기일의 지정

(가) 시차제 기일지정

변론준비기일은 시차제 지정 방식을 적극 활용하여 가능한 한 시간대를 세분화하고(민소규 39조 참조), 변호사가 선임된 사건과 당사자 본인 사건을 구별하여 별도의 시간대로 지정하는 것이 효율적일 수 있다. 당사자와 대리인이 불필요하게 대기하는 일이 없도록 하고 충분한 심리시간을 확보하기 위함이다. 이와 같이 기일을 시차제로 운영하기 위해서는 미리 기록심사를 통해 사건당 예상소요시간을 추산하여 지정하여야 한다.

시차제 소환의 철저한 정착을 위하여, 기일 변경은 최대한 자제되어야 한다. 첫 변론(준비)기일의 경우 기일변경에 관한 당사자들의 합의가 있으면 현저한 사유가 없더라도 이를 허가하여야 하겠지만(민소 165조 2항), 그 이외에는 특별한 사정이 없는 한 기일변경을 허가하여서는 아니 된다(민소규 41조). 대신 기일을 지정할 때 당사자와 소송대리인의 의견을 충분히 들음으로써 이후 기일변경 불허로 인한 당사자와 소송대리인의 불만이 생기지 않도록 해야 할 것이다.

(나) 신속한 기일지정과 대리인의 의견청취

변론준비절차를 진행하는 재판장등은 주장과 증거를 정리하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에 변론준비기일을 열 수 있다(민소 282조 1항). 사건을 변론준비절차에 부친 뒤 4월이 지난 때에는 즉시 변론준비기일을 지정하거나 변론준비절차를 종결하여야 한다(2항). 이는 혼시규정이지만 재판장은 서면공방 단계에서 사건이 방치되지 않도록 각별히 주의할 필요가 있다. 한편 참여사무관등은 정해진 기간 내에 준비서면이 제출되지 아니하면, 바로 기록을 재판장에게 인계하여 사건이 적시에 처리될 수 있도록 하여야 한다[사건관리에규 10. 나. (3) 참조].

실무상 변론준비절차에 부쳐진 사건은 서면공방만으로 쟁점정리가 완결되어 바로 변론기일을 열 수 있는 경우가 아닌 한 변론준비기일이 지정될 것이다. 이러한 변론준비기일은 서면에 의한 쟁점정리가 완결되는 즉시 가능한 한 가장 이른 시기로 지정되어야 할 것이다. 나아가 사건의 신속한 진행을 위해 필요한 경우 재판장은 변론준비절차에 부침과 동시에 변론준비기일을 정하고 기간을 정하여 당사자로 하여금 준비서면, 그 밖의 서류를 제출하게 하거나 당사자 사이에 이를 교환하게 하고 주장사실을 증명할 증거를 신청하게 할 수 있다(민소규 69조 3항).

변론준비기일 지정 없이 서면공방만 진행될 경우, 대리인의 입장에서는 서면공방을 마친 후 언제 변론준비기일이 지정될지 전혀 알지 못하다가 갑자기 기일이 지정되는 바람에 재판준비에 차질을 빚거나 다른 재판기일과 중복되어 곤란을 겪을 수 있다. 이에 대한 대처로는 참여사무관등을 통하여 양쪽 대리인의 의견을 들은 다음 이를 참작하여 변론준비기일을 지정하는 방안, 기일통지서에 지정기일에 출석할 수 없는 사정이 있는 경우 즉시 재판부에 알려주도록 하는 안내문구를 포함하는 방안 등을 활용할 수 있을 것이다.

(3) 변론준비기일의 진행 담당자

(가) 재판장과 주심판사의 역할분담

변론준비기일은 재판장이 진행을 담당하되, 합의사건의 경우 재판장이 합의부원을 수명법관으로 지정하여 그 진행을 담당하게 할 수 있도록 하고 있다(민소 280조 2항, 3항). 실무상 변론준비기일을 원활하게 운영하기 위해서는 풍부한 재판경험이 요구되고, 배석판사들의 업무부담이 적지 않기 때문에 합의부의 경우 재판장이 변론준비기일을 진행하는 예가 많다. 다만 이와 같은 방식으로 운영할 경우 재판장의 업무부담 역시 지나치게 가중될 염려가 있으므로, 사건의 성격이나 배석판사의 경력 등을 적절하게 감안하여 일정한 정도 역할을 분담할 필요도 있을 것이다.

따라서 재판장이 풍부한 경험을 바탕으로 쟁점정리를 하는 것이 효율적이라고 판단되는 사건, 신중한 증거조사나 기일진행상황에 따른 기민한 대처가 필요하다고 판단되는 사건 등은 재판장이 진행하고, 서면공방 단계를 거쳐 쟁점이 이미 상당한 정도로 드러났다고 판단되는 사건, 쟁점이 비교적 간단하고 의견차이가 크지 않기 때문에 화해적 해결 가능성이 높은 사건 등은 주심판사를 수명법관으로 지명하며, 쟁점이 많고 복잡한 사건으로서 변론준비기일의 진행 중에도 중간합의가 필요하다고 판단되는 사건은 재판장과 주심판사가 함께 변론준비기일에 참여함으로써 직접심리에 의한 심증 형성이라는 직접주의 원칙의 취지를 살리도록 하는 등 다양한 운영방식을 탄력적으로 활용할 필요가 있다.

(나) 변론준비기일 진행 중 법관이 변경된 경우의 절차

합의부원 중에서 지정된 수명법관이 변경되면 재판장은 새로 수명법관을 지정하거나 직접 변론준비기일을 진행하여야 한다. 이 경우 수명법관이 새로 지정되더라도 변론갱신에 관한 민사소송법 204조 2항의 규정은 변론준비기일에는 준용되지 아니하므로(민소 286조), 변론준비기일의 소송행위를 갱신할 필요가 없다. 합의부의 구성이 변동되었지만 지정된 수명법관이 그

합의부의 구성원으로 남아 있는 경우에는 기왕에 이루어진 수명법관 지정행위는 그대로 효력을 유지하므로, 다시 수명법관을 지정할 필요조차 없다.

(4) 변론준비기일의 진행장소와 공개 여부

(가) 장 소

변론준비를 위해서는 주장사실과 증거의 대조가 필요하고, 재판부와 당사자 사이에 구두 의견교환이 필수적으로 요청된다. 따라서 변론준비기일은 법정보다는 준비절차실, 심문실 또는 조정실을 사용하는 것이 바람직하다. 변론준비기일을 법정 이외의 장소에서 진행할 경우에는 법복을 입지 아니한 상태로 편안한 분위기에서 진행할 수 있다(법관, 사법보좌관 및 법원사무관등의 법복에 관한 규칙 2조 1항 참조).

(나) 공개 여부 및 이해관계인의 출석

변론준비기일의 심리절차를 공개하여야 하는지에 대해서는 논란이 있을 수 있다. 법원조직법 57조 1항은 재판의 심리와 판결은 공개한다고 규정하고 있는데, 여기서 말하는 공개하여야 할 심리는 변론절차에 국한되며, 변론준비절차는 포함되지 않는다는 것이 일반적인 견해이다. 판례도, 수명법관이 수소법원 밖에서 증인을 신문하거나 현장검증 및 기록검증을 할 경우에는 반드시 공개심리의 원칙이 적용되는 것은 아니라고 하여 이와 같은 해석을 간접적으로 뒷받침하고 있다(대법원 1971. 6. 30. 선고 71다1027 판결 참조).

다만 변론준비기일을 비공개로 진행하더라도 당사자가 대동한 이해관계인에 대해 그 출석을 일률적으로 불허할 것은 아니다. 오히려 재판장의 허가를 받은 때에는 당사자가 변론준비기일에 제3자와 함께 출석할 수 있도록 되어 있으므로(민소 282조 3항), 위 규정을 적절하게 활용함으로써 실질적 당사자의 지위에 있거나 분쟁에 직접적인 중요한 이해관계를 가지고 있거나 당사자의 의사결정에 상당한 영향력을 가지고 있는 제3자를 참여시켜 효율적으로 쟁점을 정리하고 화해·조정에 의한 분쟁해결의 여지를 넓힐 수 있을 것이다.

변론준비기일에 제3자가 하는 진술은 조서에 기재할 수 있지만 그 자체가

어떤 소송법적 효력을 갖는 것이 아니다. 다만 당사자가 이를 원용하여 진술할 수 있고, 민사소송법 313조에 해당하는 특별한 사정이 있으면 그 제3자를 증인으로 신문할 수도 있을 것이다(민소 281조 3항 단서).

(5) 당사자 협의 제도의 활용

가) 의 의

변론준비절차에서 당사자는 ‘쟁점의 정리’, ‘증거의 정리’, ‘효율적이고 신속한 변론진행을 위한 준비’에 관하여 상대방과 협의할 수 있고, 재판장등은 당사자에게 변론진행의 준비를 위하여 필요한 협의를 하도록 권고할 수 있다(민소규 70조 2항). 실무상 당사자 협의는 서면공방 단계보다는 변론준비기일이 열린 경우에 이루어질 가능성이 높다.

이와 같은 변론준비절차에서의 당사자 협의 제도는 일본의 ‘계획심리(計劃審理)’나 프랑스의 ‘절차계약(contrat de procédure)’과 마찬가지로 합리적인 계획을 세워 심리를 촉진하는 한편 소송의 주체인 당사자의 절차적 권리를 존중한다는 취지에서 법원과 당사자가 사건의 쟁점이 무엇이며, 어떤 일정으로 심리를 진행할 것인지 미리 합의한다는 데에 의미가 있다. 법원의 일방적 주도가 아니라 당사자의 의견과 희망을 반영함으로써 당사자나 대리인이 자발적으로 심리일정을 준수해 가는 환경을 조성한다는 점에서 중요한 의미를 찾을 수 있다.

나) 대상과 방법

당사자 협의는 다투는 범위를 명확히 하고 불필요한 쟁점의 확대를 미연에 방지하는 ‘쟁점협의’와 증인의 수와 조사방식, 증거조사에 필요한 시간, 증거조사의 순서, 증인의 출석확보방안 등에 관한 ‘증거협의’를 포괄한다. 또한 심리의 절차 면에 관한 심리계획의 협의와 심리의 실질 면에 관한 쟁점결정의 협의를 모두 포함한다. 현행 민사소송규칙에서 명시적으로 언급하고 있는 절차협의의 대상은 아래와 같다.

① 재판장등은 변론준비절차에서 당사자와 변론의 준비와 진행 및 변론에

제22장

사건관리 및 변론의 진행

필요한 시간에 관한 협의를 할 수 있다(민소규 70조 3항). 예컨대 향후 변론 기일에서 양쪽 당사자의 진술이나 증인의 증언에 소요되는 시간(75조 2항 참조), 시청각 자료의 활용 여부 등 세부적인 사항은 물론, 변론준비절차 및 증거신청의 종결시한, 증인신문 등 증거조사와 최종변론의 종결시한, 개략적인 선고예정일시 등 사건 전체의 일정에 대한 협의도 미리 하여 두는 것이 바람직할 것이다. 이러한 절차협의를 통하여 당사자는 절차에 대한 예측가능성이 높아지고, 재판장은 절차협의를 어긋난 당사자의 소송행위에 대하여 제재를 가할 수 있게 된다.

② 재판장등은 변론준비절차에서 당사자와 준비서면의 제출횟수, 분량, 제출기간 및 양식에 관한 협의를 할 수 있고, 이에 관한 합의가 이루어진 경우 당사자는 그 합의에 따라 준비서면을 제출하여야 한다(민소규 70조 4항). 그와 같은 합의가 없는 경우 준비서면의 분량은 30쪽을 넘을 수 없다(69조의4 1항). 준비서면은 변론할 사항을 법원 및 상대방에게 예고하는 것이므로, 법원 및 상대방이 변론할 사항을 미리 알 수 있도록 효율적으로 작성되어야 하며, 이러한 절차협의를 통하여 기록 분량 감소 및 채점 위주 심리, 재판의 충실을 꾀할 수 있다. 당사자가 수기로 알아보기 어렵게 작성한 준비서면을 제출하는 경우 위 조항에 근거하여 당사자에게 컴퓨터나 타자기로 준비서면을 작성하여 제출하도록 협의할 수도 있다.

재판장등은 기일을 여는 방법으로 절차협의를 할 수 있고, 당사자의 의견을 들어 기일을 열지 않은 채 양쪽 당사자와 음성의 송수신에 의하여 동시에 통화를 하거나 인터넷 화상장치를 이용하는 방법으로도 절차협의를 할 수 있다(민소규 70조 5항). 양쪽 당사자가 원거리에 있거나 당사자가 참석할 필요가 없는 간단한 절차협의를 경우에는 후자의 방법을 활용하면 편리할 것이다. 변론준비기일에 이러한 협의가 성립된 경우에는 그 내용을 조서에 기재하여 둬으로써[전산양식 A1650-1] 향후 변론기일에 협의사항을 위반하였을 때 적절히 대처할 수 있도록 함이 바람직하다.

[전산양식 A1650-1] 절차협의안

구분	원고		피고		비고
	기한	내용	기한	내용	
☐ 준비서면	20 . . .	◎ 분량: 10쪽 이하 (서증을 포함하지 아니함) ◎ 글자크기: 12포인트 ◎ 제출횟수: 2회 이하	20 . . .	원고의 경우와 같음	
☐ 서증 또는 증거 신청	20 . . .	이 사건 토지(○○동 ○ 번지)에 대한 등기사항전 부증명서 2부 제출			
☐ 제1회 변론기일	◎ 기일: 20 . . . ◎ 예정: 양쪽 당사자 준비서면 진술 서증조사 증인 ○○○신문, 당사자 본인(피고)신문 변론종결 ◎ 증인에 대한 신문기일이 ○○회를 공전하는 경우 신청인 은 증인을 철회하기로 한다.				당사자 본인 출석 요(要)
☐ 기타 협의사항	1. 양쪽 당사자가 2회를 초과하여 준비서면을 제출하고자 하 는 경우에는 사전에 재판장의 허가를 받아야 한다. 2. 양쪽 당사자는 기일의 협의를 변경하고자 하는 경우에는 사전에 재판장의 허가를 받아야 한다.				

제22장

사건관리 및 변론의 진행

(다) 효 령

변론준비기일에 당사자 사이에서 성립된 합의와 같이 소송절차에서 당사자 사이에 성립된 합의, 즉 소송상 계약(부제소약정, 소취하약정, 쟁점약정, 증거계약 등)은 그 내용과 형태가 매우 다양할 뿐 아니라 그 계약의 소송법상 효력이나 근거에 관하여도 학설상 여러 가지 견해가 있다. 그러나 단순한 사법상의 계약과 달리 소송절차상 법관의 면전에서 이루어진 합의인 이상 일정한 소송법상의 효력이 생기게 된다는 점은 일반적으로 인정되고 있으며, 실무상으로도 이러한 합의는 소송절차를 효율적으로 진행하는 데 유용하게 활용될 수 있다.

특히 당사자 협의는 신의칙 위반과 결합함으로써 실권효에 대한 저항감을 완화하여 무리 없이 실권효를 적용할 수 있는 여건을 조성하는 데에도 도움이 된다. 민사소송규칙 70조 3항, 4항에 의한 절차협의 결과에 따르지 않을 경우에는 변론준비기일 종결로 인한 실권효(민소 285조)나 재정기간 제도에 따라 부과되는 실권효(147조), 실기한 공격방어방법 각하(149조)의 제재도 가할 수 있을 것이다. 다만 이러한 당사자 협의가 소송의 동태적·발전적 성격과 모순된다는 비판도 있을 수 있으므로, 합리적인 사유가 있으면 사정변경을 인정하는 등 운영의 묘를 발휘할 필요가 있다.

다. 변론준비기일의 진행

(1) 당사자의 출석 등

변론준비기일 역시 변론기일에서와 같이 사건 호명과 출석 확인 등으로 시작된다. 재판장등은 변론준비기일에 당사자 본인 또는 그 법정대리인에게 출석을 명할 수 있고(민소 282조 1항, 민소규 29조의2 1항, 출석명령[전산양식 A1637]) 소송대리인에게 이를 요청할 수도 있다(민소규 29조의2 2항, 당사자 본인출석요청[전산양식 A1638]). 또한 당사자는 재판장등의 허가를 얻어 변론준비기일에 제3자와 함께 출석할 수 있다(민소 282조 3항). 다만 당사자가 출석명령에 따르지 않을 경우의 제재방법에 관해서는 아무런 규정이 없으므로, 실권효의 적용 여부를 결정할 때 참고하거나 변론 전체의 취지로 고려할 수밖에 없다.

석명처분에 의한 출석명령이나 화해권고를 위한 출석명령은 법원이 하는 것임에 비하여 민사소송법 282조 1항에 따른 당사자 본인 등에 대한 출석명령의 주체는 변론준비절차의 주재자인 재판장등이라는 점에서 차이가 있다. 이는 당사자 본인의 참여를 통하여 사건의 실체를 조기에 정확하게 파악하는 한편 당사자에게 절차진행에 대한 신뢰감을 제고하기 위한 것이다. 재판장등은 이러한 취지를 고려하여 당사자 본인이 출석한 경우 필요한 범위

에서 사건의 취지 및 이후 소송의 진행과정을 설명하고, 당사자 본인으로부터 이후 심리과정에서 재판부가 특히 고려하여 주기를 바라는 사항이 있는지 여부를 물어 확인하는 것이 바람직하다.

(2) 쟁점정리

종래에는 변론준비기일에 사실상의 변론까지 하고, 변론기일에는 증인신문 등 추가적인 증거조사만을 하는 방식으로 심리를 진행하여 변론기일의 변론이 형해화되는 사례가 있었다. 그러나 현행 민사소송법과 민사소송규칙은 변론의 대상과 변론준비의 대상을 준별하고 있으므로, 변론준비기일에서는 변론에서 공방할 쟁점을 정리하여 확정하고, 변론기일에서는 확정된 쟁점에 관한 본격적인 구술공방이 이루어져야 한다. 반면 변론준비절차를 거치지 않은 채 변론기일이 지정되는 원칙적인 형태에서는 쟁점의 정리와 쟁점에 대한 공방이 통합적으로 이루어질 것이다.

따라서 변론준비기일에서의 '쟁점정리'란 당사자 사이에 다툼이 있는 사실관계의 범위를 확인·정리함으로써 장차 변론기일에서 공방과 증명의 대상이 될 쟁점의 범위를 특정하는 것을 의미한다. 즉 불명료한 주장을 명확히 하고 불필요한 다툼을 제외시키며 분쟁의 핵심과 무관한 감정적인 대립을 제거하고 주장·증거를 대조해 봄으로써 오해나 착오에서 비롯된 주장을 철회하도록 하는 등, 쟁점을 집약함으로써 이후 변론단계에서 구술공방이 핵심적 쟁점에 집중되도록 하는 것이다. 재판장등은 이를 위하여 당사자에게 사실상·법률상 사항에 관한 질문을 하거나 필요한 증명을 촉구하는 등 석명권을 행사할 수 있으며, 때로는 간과된 법률상 사항을 쟁점에 포함시키도록 하여야 한다(민소 286조, 136조 1항, 4항).

민사소송법 134조는 변론준비절차의 준용대상에 포함되어 있지 않지만, 변론준비기일에서의 심리도 구술로 행해져야 함은 명백하다. 이에 따라 변론준비기일에서는 당사자가 말로 변론의 준비에 필요한 주장과 증거를 정리하여 진술하거나, 법원이 당사자에게 말로 해당사항을 확인하여 정리하여야

한다(민소규 70조의2). 당사자의 소송행위가 구술로 이루어지는 점은 변론기일과 같으나, 변론준비기일에서는 실질적인 변론이 변론기일에 이루어질 것을 염두에 두고서 장차 변론에서 다루게 될 주장과 증거의 범위를 검토·정리함으로써 이를 준비하는 데에 그치게 된다. 따라서 쟁점정리 과정에서 제출된 서면을 변론준비기일에서 진술한 것으로 처리하였더라도, 그 서면을 기초로 변론기일에서 쟁점에 관하여 충분한 구술공방(변론)이 이루어지도록 하여 재판의 직접주의와 공개주의를 구현함이 타당하다.

한편 재판장등은 당사자가 변론준비기일에서 쟁점을 정리한 이후에도 계속하여 준비서면을 제출하여 쟁점을 분산시키거나 불필요하게 기록의 양을 늘리지 않도록 쟁점정리과정에서 적절하게 소송지휘권을 행사함이 바람직하다. 특히 변론준비기일이 종결되면 실권효가 발생하므로(민소 285조), 재판장등은 변론준비기일의 종결단계에서 변론준비기일이 종결된 후에는 정리된 쟁점과 증거 이외에 다른 공격방어방법은 소송에서 제외되어 제출할 수 없음을 명확히 고지하여 이후 변론이 집중될 수 있도록 한다.

(3) 증거신청 및 채부결정과 증거조사

재판장등은 변론준비기일에 변론의 준비를 위하여 필요하다고 인정하면 증거신청에 대한 채부를 결정할 수 있고(민소 281조 1항), 변론이 효율적이고 집중적으로 실시될 수 있도록 하기 위하여 필요한 범위 안에서 증거조사를 할 수 있다(3항 본문, 279조 1항). 다만 증인신문과 당사자신문은 ① 증인 등이 정당한 사유로 수소법원에 출석하지 못하는 때, ② 증인 등이 수소법원에 출석하려면 지나치게 많은 비용 또는 시간을 필요로 하는 때, ③ 그 밖의 상당한 이유가 있는 경우로서 당사자가 이의를 제기하지 아니한 때에 한하여 가능하다(281조 3항 단서, 313조). 따라서 변론준비기일의 주된 증거조사절차는 증인신문을 제외한 서증의 조사, 사실조회, 검증, 감정 등과 같은 기일전 증거조사결과의 상정과 증인의 채부결정 등이다. 서증 등 변론준비기일에서 즉시 증거조사가 가능한 증거에 관하여 채부결정을 한 경우 곧바로 증거조

사를 하게 되나, 증인을 채택한 경우 증인신문을 위한 변론기일을 지정하여야 한다.

서증의 조사와 사실조회, 검증, 감정 등 기일전 증거조사결과의 상정은 재판장등이 그 증거조사의 결과를 확인하고 당사자에게 그 요지를 말로 진술하게 하거나 직접 이를 고지한다(민소규 70조의2 참조). 이는 증거가 요증사실의 증명에 있어 어떠한 증거가치를 갖는 것인지를 재판장등이 확인한 다음 그에 대하여 객관적 입장에서 구체적으로 인식한 내용이 무엇인지를 설명하여 줌으로써 심증형성의 과정을 공개하는 역할을 한다. 다수의 증거가 있는 경우에는 요증사실의 증명과 주요한 관련이 있는 증거에 한정하여 요지고지절차를 밟을 수 있다. 재판장등은 개별 증거의 요지 고지 시마다 또는 증거의 요지 고지를 모두 마친 후 일괄하여 당사자에게 그에 대한 의견을 진술할 기회를 부여하고 필요한 경우 그 진술의 요지를 조서에 기재하도록 한다.

(4) 화해적·대안적 해결의 모색

쟁점정리와 증거조사를 마친 단계에 이르러서는 어느 정도 사건의 윤곽이 드러나기 마련이므로, 당사자의 입장에서도 소송승패의 예측이 가능할 수 있다. 이때 판결 이외의 화해적·대안적 해결방안이 분쟁해결에 더 적절할 것으로 보이면, 먼저 당사자에게 자율적 해결방안을 협의할 여지가 있는지, 즉 당사자가 구체적인 해결방안을 제시하고 상대방이 이를 수용할 수 있는지 타진하고, 자율적 해결방안의 도출이 어려운 경우라도 법원의 조정에 응할 의사가 있는지를 확인하여 조정기일을 지정하거나 조정안이 단순한 경우 즉일 조정을 시도함이 바람직하다. 다만 이때 제시하는 조정안은 그때까지 증거조사 결과에 바탕을 둔 잠정적인 것임을 당사자로 하여금 충분히 이해하도록 하여, 조정이 불성립된 이후 판결과 결론이 달라질 경우에 생길 수 있는 불필요한 오해를 미리 불식시킬 필요가 있다.

(5) 증거조사계획의 수립 및 기일 협의

(가) 증거조사계획의 수립

주장과 증거의 정리가 마쳐지면 정리된 쟁점을 바탕으로 증명이 필요한 다툼이 있는 사실을 확인하고, 증거조사기일에 조사할 증인과 조사방법 등을 결정하게 된다. 현행 민사소송법은 1회의 기일에 집중적인 증거조사(증인신문 및 당사자신문)를 통하여 변론을 종결하는 것을 원칙으로 하므로, 집중 증거조사가 효율적으로 시행되기 위해서는 재판부와 당사자·대리인의 치밀한 사전준비와 긴밀한 협력이 필요하다.

집중증인신문을 효과적으로 실시하기 위하여 증인의 선정 이외에도 증인의 출석가능성 및 출석확보 방안, 예상되는 증인신문 소요시간, 대질신문 및 재정신문 활용 여부 등에 관하여 재판부와 당사자가 긴밀하게 의견을 교환하고 협의할 필요가 있다. 또한 개별 증인별로 그 증인의 증명취지, 증인과 당사자의 관계 등을 고려하여 ① 증인진술서 제출방식, ② 증인신문사항 제출방식, ③ 서면에 의한 증언방식 중 하나를 채택하여 양쪽 당사자에게 고지할 필요도 있다.

(나) 변론기일의 지정 및 진행에 관한 협의

변론준비절차를 종결하는 경우에 재판장등은 당사자의 의견을 들어 변론기일을 미리 지정할 수 있다(민소 284조 2항, 민소규 72조 2항). 이렇게 지정된 기일은 사실과 증거에 관한 조사가 충분하지 아니하다는 이유로 변경할 수 없다(민소규 72조 3항). 기일지정에 당사자의 희망을 반영함으로써 기일의 변경 등을 방지하고, 증인출석확보에 대한 적극적인 협력을 이끌어 낼 수 있도록 한 것이다.

따라서 변론준비기일을 끝내는 단계에서는 반드시 출석한 당사자 또는 대리인과 변론기일의 지정 및 진행에 관한 협의를 하는 것이 바람직하다. 이때 양쪽에 증인을 확실하게 출석시킬 수 있는 기일이 언제인지를 묻고 그에 따라 변론기일을 지정함으로써 당사자나 대리인에게 기일엄수에 대한 책임을

분명히 인식시켜야 한다. 만일 증인이 출석하지 않을 경우에는 그에 따른 불이익이 주어질 수 있음도 함께 고지하여야 한다. 증인의 상당수가 당사자의 영향권 안에 있고, 다수가 대동증인으로 신청되는 실정이므로, 이와 같은 점을 확인하여 두는 것은 증인의 출석확보와 변론기일의 공전 방지에 큰 도움이 될 수 있다.

라. 변론준비기일에 당사자가 불출석한 경우의 처리

(1) 한쪽 당사자의 불출석

한쪽 당사자가 변론준비기일에 출석하지 아니한 경우 그가 제출한 소장·답변서, 그 밖의 준비서면에 적혀 있는 사항을 진술한 것으로 보고 출석한 상대방에게 진술을 명할 수도 있고(민소 286조, 148조 1항), 그대로 준비절차를 종결할 수도 있다. 당사자가 변론준비기일에 출석하지 아니한 경우 변론준비절차를 종결하여야 함이 원칙이지만(284조 1항 3호), 변론의 준비를 계속하여야 할 상당한 이유가 있는 때에는 당사자의 불출석에도 불구하고 변론준비절차를 계속할 수 있기 때문이다(1항 단서).

서면공방만으로는 부족하고 기일을 열어 쟁점정리를 할 필요가 있다고 판단하여 변론준비기일을 지정한 이상, 가급적 양쪽 당사자가 출석한 상태에서 기일을 열어 쟁점정리를 하는 것이 변론준비기일 제도의 취지에 부합하고, 아울러 변론준비기일 종결의 효과로서 실권효가 인정되므로 한쪽 당사자만 출석한 상태에서 변론준비기일을 진행하는 경우 출석한 당사자로부터 기일에 새로운 주장이 제기되었거나, 불출석한 당사자가 미리 제출한 준비서면의 취지에 비추어 반론의 기회를 주지 않고 변론준비절차를 종결하여 실권효의 제재를 가하는 것이 부적절하다고 보이는 특별한 사정이 있는 경우에는 변론준비기일을 종결하지 말고 다시 기일을 정하여 한 번 더 기회를 주는 방식으로 실무를 운영함이 바람직하다.

한쪽 당사자가 불출석한 경우의 변론준비기일 진행에 관하여는 진술간주

와 자백간주의 법리가 준용된다(민소 286조, 148조, 150조).

(2) 양쪽 당사자의 불출석

양쪽 당사자가 모두 변론준비기일에 출석하지 아니하였거나, 출석하였더라도 진술하지 아니하는 경우에는, 재판장은 변론준비기일을 다시 지정하고 기일을 통지하여야 한다(민소 286조, 268조 1항).

양쪽 당사자 불출석에 의한 소취하간주 규정은 변론준비기일에도 준용된다(민소 286조, 268조). 따라서 변론준비기일에 2회에 걸쳐 양쪽 당사자가 출석하지 아니하거나 출석하였더라도 변론하지 아니한 때에는 1개월 안에 기일지정신청이 없으면 소를 취하한 것으로 간주된다. 당사자 사이에 화해가 성립되거나 원고가 소송을 계속할 의사가 없어서 불출석한 경우에는 위 규정에 따라 사건을 종결하는 것이 효율적이므로, 양쪽 당사자 또는 원고가 불출석한 경우에는 위와 같은 취하간주의 가능성이 있는 이상 한 번 더 변론준비기일을 지정할 필요가 있다.

(3) 변론준비기일 1회, 변론기일 1회 불출석의 경우

변론준비기일에 양쪽 당사자가 불출석하거나 출석하였더라도 변론하지 아니한 경우 그 효과가 변론기일에 승계되는지 여부가 문제 된다. 예컨대 양쪽 당사자가 1회 변론준비기일에 출석하지 아니하여 변론준비절차를 종결하였는데, 그 후 열린 변론기일에 다시 양쪽 당사자가 출석하지 아니하거나 원고가 불출석하고 출석한 피고가 변론하지 아니한 경우 1개월 안에 기일지정신청이 없으면 소취하간주의 효력이 발생하는가 하는 점이다. 이와 관련하여 대법원은, 변론준비기일에서 생긴 양쪽 당사자 불출석의 효과는 변론기일에 승계되지 아니한다고 판시하였다(대법원 2006. 10. 27. 선고 2004다69581 판결).

나아가 배당이의 소송의 경우 원고가 첫 변론기일에 출석하지 아니한 때에는 소를 취하한 것으로 간주되는데(민집 158조), 이때의 첫 변론기일에는 첫 변론준비기일이 포함되지 아니한다. 따라서 원고가 첫 변론준비기일에 불출석한 것만으로 소를 취하한 것으로 간주되지는 아니하나(대법원 2006.

11. 10. 선고 2005다41856 판결), 첫 변론준비기일에 출석하였더라도 첫 변론기일에 불출석하면 소를 취하한 것으로 간주된다(대법원 2007. 10. 25. 선고 2007다34876 판결).

마. 조서의 작성과 변론준비결과와 서면화

(1) 참여사무관등의 기일 참여

쟁점정리를 위한 기일은 변론준비기일 또는 변론기일 형식이므로, 참여사무관등은 해당 기일에 참여하여 기일조서를 작성하여야 한다. 다만 변론을 녹음·속기하는 경우 그 밖에 이에 준하는 특별한 사정이 있는 경우에는 참여사무관등의 참여 없이 변론기일 및 변론준비기일을 열 수 있다(민소 152조, 283조). 따라서 이러한 요건에 해당할 경우에는 기일의 처음부터 끝까지 참여사무관등의 참여 없이 기일을 진행할 수 있다. 녹음(속기)을 하는 경우에는 재판장이 기일을 시작할 때 그 사실을 당사자에게 고지하여야 한다(속기·녹음예규 4조). “그 밖에 이에 준하는 특별한 사정이 있는 경우”의 의미는 변론을 녹음·속기하는 것에 준하는 정도로 참여사무관등의 참여 없이도 조서작성이 충분히 가능한 경우라고 해석된다.

실무상으로도 변론기일의 형태로 법정에서 쟁점정리절차를 진행하는 경우에는 예외 없이 참여사무관등이 참여하고 있으나, 준비절차실이나 조정실 등 법정 밖에서 변론준비기일의 형태로 쟁점정리기일이 진행되는 경우에는 참여사무관등의 참여 없이 기일을 진행하다가 쟁점정리의 마지막 단계에서 양쪽 당사자에게 쟁점정리 결과를 확인할 때 참여하게 하거나, 나아가 기일 후에 재판장등이 정리하여 준 내용을 토대로 조서를 작성하는 운영방식도 이루어지고 있다.

참여사무관등이 사건관리, 특히 서면공방절차에서 실질적인 역할을 수행하기 위해 당사자가 제출하는 주장서면들을 일일이 검토하는 경우 등에는, 참여사무관등의 시간활용을 효율화한다는 측면에서 재판부 사정에 따라 변

론준비기일을 참여사무관등의 기일참여 없이 진행하는 방식도 적극적으로 활용할 필요가 있다. 이 경우 녹음·속기가 이루어지거나 그에 준하는 특별한 사정이 있어야 하고, 그 기일이 끝난 뒤에는 즉시 재판장등의 설명에 따라 조서를 작성하여야 하나, 쟁점·증거의 정리를 목적으로 하는 변론준비기일의 성격에 비추어, 기일에서 재판장이 사건별로 조서 기재사항을 메모하는 정도로 녹음·속기에 준하는 사정을 인정해도 무리가 없을 것이다. 녹음·속기를 실시하는 때에는 재판장등은 녹음물과 속기록을 변론준비기일조서의 일부로 삼을 수 있다(민소규 36조 1항).

(2) 변론준비기일조서의 형식적 기재사항

변론준비기일의 조서에는 변론조서에 관한 규정이 준용되므로(민소 283조 2항, 152조 내지 159조), 기일의 공개 여부를 적고, 녹음·속기 등의 사정으로 참여사무관등의 참여 없이 기일을 진행한 경우에는 기일이 끝난 뒤에 재판장등의 설명에 따라 조서를 작성하고 그 취지를 덧붙여 적어야 하며, 판결 이외의 방법으로 소송이 종결된 경우 조서작성을 생략할 수도 있다.

수명법관이 변론준비기일을 진행한 경우 조서상의 표시방법은 합의부를 대표하여 소송절차를 진행한다는 의미에서 “수명법관 판사 ○○○”의 형식으로 그 자격을 표시하는 것이 적절하다. 재판장과 주심판사가 함께 변론준비기일에 참여한 경우 변론준비기일조서의 ‘형식적 기재사항’란에는 관여한 법관 모두를 기재하되, 조서 말미에는 재판장만이 기명날인하면 된다.

(3) 쟁점정리결과 서면화의 필요성

변론준비기일의 조서에는 형식적 기재사항 외에 당사자의 진술에 따라 공격방어방법, 상대방의 청구와 공격방어방법에 대한 진술을 적어야 하며, 특히 증거에 관한 진술은 명확히 하여야 한다(민소 283조 1항). 또한 변론준비기일의 조서에는 변론준비절차의 시행결과를 적어야 한다(민소규 71조 1항).

이와 같이 쟁점정리결과를 서면화하는 것은 이후 절차에서 쟁점에 집중하여 증거조사를 할 수 있게 하고, 변론준비기일 종결에 따른 실권효의 적용근

거를 명확히 밝혀 둔다는 데 중요한 의미가 있다. 따라서 쟁점정리결과를 어떤 형태로든 기록에 표시하여 두는 것이 필요하며, 당사자 사이에 의견대립이 심하여 쟁점정리가 안 되었으면 그 취지라도 조서에 기재하는 것이 타당하다.

다만 쟁점정리의 과정까지 서면화할 필요는 없고, 최종결과만 기재하면 되며, 또한 서면공방만으로 쟁점이 충분히 부각되어 변론준비기일에는 이를 확인하는 데 그친 경우나 굳이 조서에 기재할 필요가 없을 정도로 쟁점이 간명한 경우에는 예외적으로 쟁점정리결과를 당사자에게 말로 확인하는 것으로 충분할 것이다.

한편 쟁점정리 과정에서 향후 정리된 쟁점에서 벗어난 주장을 하지 않는 다거나 기왕의 주장 중 일부를 철회하기로 하는 협의가 성립한 경우에는 그 협의결과를 조서에 기재하여 변론준비기일 종결에 따른 실권효의 적용근거로 활용함으로써 쟁점정리의 실효성을 확보할 수 있다.

서면화의 대상은 ① 당사자 사이에 사건의 쟁점이 어떤 것인가에 관하여 의견이 일치된 경우에는 그 취지, ② 당사자 사이에 사건의 쟁점이 되는 사항 중 합의가 이루어진 사항, ③ 당사자가 이미 제출한 공격방어방법 중 어떤 것을 철회한다고 한 경우에는 그 취지, ④ 당사자가 이미 제출한 공격방어방법 이외의 새로운 공격방어방법을 제출하지 아니하기로 한 경우 그 취지, ⑤ 증거조사결과에 대한 당사자의 의견, ⑥ 당사자 사이에 절차협의(민소규 70조)가 이루어진 경우 그 내용 등이다. 조서기재 방식의 예를 들면 다음과 같다.

[조서기재례]

- ① 이미 제출한 주장 이외의 새로운 공격방어방법을 제기하지 않는다는 진술의 기재

양쪽 당사자

주장 및 증거는 이미 제출한 것으로 한정한다.

원고는 A라는 주장을, 피고는 B라는 주장을 하지 아니한다.

② 기왕의 공격방어방법을 철회한다는 진술의 기재

원고

주위적 청구를 취하한다고 진술

피고

위 취하에 동의하고, 사무집행 관련성을 부정하는 주장을 제외한 나머지 주장을 철회한다고 진술

(4) 쟁점정리결과 서면화의 방식과 유형

① 구술 확인만으로 쟁점을 정리하여 조서에 기재하는 방안

사건의 쟁점이 비교적 단순한 경우에는 법관이 당사자의 면전에서 개개의 쟁점에 관하여 하나씩 말로 확인한 다음, 정리된 쟁점을 요약하여 조서에 기재하는 것이 효율적이다. 실무상 이 방식이 가장 많이 활용되고 있는데 구체적인 예를 들면 다음과 같다.

[조서기재례]

① 주요사실이 쟁점정리의 대상이 된 사건

양쪽 당사자

이 사건의 쟁점은 ○○지방법원에서 20 . . . 선고한 판결의 대여금채무가 이 사건 근저당권의 피담보채무의 범위에 포함되는지 여부라고 일치하여 진술

② 중요한 간접사실이 쟁점정리의 대상이 된 사건

양쪽 당사자

이 사건의 쟁점은 피고가 원고로부터 임차목적물인 이 사건 아파트를 인도받은 후 그에 관하여 임대차 중개를 의뢰한 사실이 있는지 여부라고 일치하여 진술

③ 핵심적인 처분문서의 성립인정 사실이 쟁점정리의 대상이 된 사건

피고

원고가 제출한 갑 제1호증(매매계약서)은 피고의 아버지인 망 A가 생전에 작성한 문서가 맞다라고 진술

이 방식에 의할 경우에는 변론준비기일의 진행을 녹음한 녹음물을 조서의 일부로 삼는 방법(민소 283조, 152조 3항, 민소규 36조 1항)과 결합하면 더욱

효과적일 수 있다.

② 당사자가 제출한 쟁점정리서면을 활용하는 방안

이 방식은 기일 전에 미리 양쪽 당사자에게 다툼이 없는 부분과 다투는 부분을 구분하도록 하고, 다투는 부분(쟁점)에 대한 사실적·법률적 주장과 그에 대한 증거를 적시하는 쟁점정리서면을 제출하도록 하여 이를 조서의 일부로 삼되, 조서에는 각 쟁점정리서면의 내용 중 기일에서 수정된 쟁점만을 기재하는 방안이다. 이때 쌍방에 쟁점준비서면에 기재되지 않은 주장은 철회하도록 한 후 그 취지를 조서에 남겨두면 향후 심리와 판결 작성에 도움이 될 수 있다. 다만 이러한 방안이 아직까지 폭넓게 활용되고 있지는 않은데, 그 이유는 대리인이 없는 사건의 경우 법률지식이 부족한 당사자 본인에게 쟁점정리서면의 제출을 기대하기 어렵고, 대리인이 있더라도 쟁점정리서면의 구체적 작성방법이 정립되어 있지 않은 관계로 대리인의 협력을 구하기가 쉽지 않으며, 자칫하면 그동안 제출된 준비서면의 반복이 될 우려가 있기 때문이다. 따라서 이러한 방식을 활용하고자 하는 경우 재판장등은 쟁점정리서면이 또 다른 준비서면이 되지 않도록 당사자에게 각자의 쟁점에 관한 주장을 요약하는 정도로만 제출하게 하여야 한다. 전자소송에서는 쌍방 당사자로 하여금 같은 표에 쟁점별 주장의 요지를 입력하도록 하여 하나의 화면에서 쌍방의 주장을 확인할 수 있는 ‘대조형 쟁점요약표’ 기능을 활용할 수도 있다.

③ 법원이 직권으로 작성한 쟁점정리안을 조서에 편철하는 방안

이 방식은 법원이 기일 전에 직권으로 쟁점정리안을 작성하여 양쪽 당사자에게 미리 송부하고, 당사자로부터 서면으로 또는 기일에 말로 의견을 들어 정리한 결과를 조서에 기재하거나 별지로 조서에 첨부하는 방안이다.

쟁점정리안의 예시는 쟁점정리안(다툼 없는 사실과 쟁점 적시)[전산양식 A1530], 쟁점정리안(쟁점 및 석명사항 적시)[전산양식 A1531]과 같고, 이 경우의 조서 기재 방법은 다음과 같다.

[조서기재례]

수명법관 판사
 별지와 같은 쟁점정리안을 제시
 양쪽 대리인
 위 쟁점정리안에 대하여 이의가 없다고 진술

특히 쟁점이 복잡한 사건이나 재판부가 인식하고 있는 쟁점이 명확히 전달되지 아니하여 주장 및 증명이 표류하고 있는 사건 등에는 법원이 쟁점정리안을 작성하여 제시하는 방안이 효율적일 수 있다. 변론준비기일의 준비와 진행에 관한 재판장의 업무가 지나치게 무거운 상황이라면, 주심판사가 쟁점정리안 초안을 작성하는 등의 역할을 분담할 필요가 있다.

(5) 쟁점정리결과와 고지·확인

변론준비기일에 양쪽의 주장과 증거를 비교하여 정리된 쟁점의 요지만을 간략하게 조서에 기재하는 경우에는 따로 당사자에 대한 고지·확인절차를 거치지 않는 것이 일반적이다. 또한 법원이 미리 작성한 쟁점정리안을 양쪽 당사자에게 보내 의견을 밝히도록 하고 이를 기초로 변론준비기일에 수정·보충하는 방식을 활용할 경우에도 이미 변론준비기일 전에 쟁점정리안이 당사자에게 고지되고, 수정된 최종내용 역시 기일의 진행과정에서 당사자가 확인할 수 있으므로, 다른 조치를 취할 필요가 없다.

그러나 쟁점정리 과정에 논란이 많았거나 쟁점이 많고 복잡하여 당사자나 대리인에게 서면화될 최종적인 쟁점정리결과를 알려 주는 것이 나중에 다툼의 소지를 없애는 데 도움이 된다고 판단되는 경우에는 변론준비기일에 쟁점을 정리한 직후(당일 또는 다음 날) 쟁점정리사항 고지서[전산양식 A1532]를 작성하여 양쪽 당사자에게 발송하고, 정해진 이의기간 내에 이의제기가 없으면 그 내용대로 조서를 작성하는 방식을 활용하는 것이 바람직하다.

바. 변론준비기일의 속행 및 종결

(1) 변론준비기일의 속행·추후지정과 변경

현행 민사소송법은 사건이 준비절차에 회부된 경우 변론준비기일을 1회로 종결하는 것을 원칙으로 하고 있다. 그러나 1회 기일만으로 쟁점정리를 완료하기에 부족한 경우에는 부득이 변론준비기일을 속행할 수밖에 없다. 변론준비기일을 속행하게 되는 주된 사유는 당사자가 법원과 상대방이 예상하지 못한 새로운 주장을 제기하거나 서증을 제출하여 상대방에게 이를 탄핵할 기회를 부여하는 것이 필요한 경우가 대부분이지만, 사건 내용이 복잡하여 1회 기일만으로 쟁점정리를 마칠 수 없거나, 대리인이 사건내용을 제대로 파악하지 아니한 채 출석하여 쟁점정리 자체가 불가능하거나, 당사자가 변호사 선임을 위하여 속행을 원하기 때문에 기일이 속행되는 경우도 있다. 예컨대 쟁점이 복잡하거나 감정 등 증거조사에 상당한 시간과 전문가의 조력이 필요하여 첫 변론준비기일을 심리계획을 수립하는 절차협의기일로 진행한 경우에는, 그 절차협의의 결과에 따라 다음 변론준비기일에 쟁점정리와 증거조사를 진행한다.

실무상 불가피하게 기일을 속행하더라도, 변론준비기일은 필요 최소한도로 집중해서 운영하여야 한다. 양쪽 당사자, 특히 속행의 원인을 제공한 당사자에게 다음 기일까지는 반드시 모든 주장 및 증거의 제출을 마칠 것과 그렇게 하지 않을 경우 바로 증거조사기일로 넘어가게 됨을 명확하게 주지시킬 필요가 있다. 예컨대 당사자가 변론준비기일의 직전 또는 기일에서 새로운 주장이 담긴 준비서면을 제출하거나 당사자가 서면에 의한 쟁점정리 단계에서 사실조회 등 필요한 증거의 신청을 마치지 못하는 등의 사유로 속행되는 경우라면, 재판장등은 당사자에게 주장과 증거의 제출 지연으로 인한 불이익(민소 286조, 146조, 149조)을 고지하거나, 추가적인 주장 또는 증거를 제출하려는 당사자에게 그에 관한 기한을 정하여 고지하고 조서에 이를 고지한 사실을 기재한 후 적절한 제재를 가함으로써(286조, 147조) 기일

의 속행을 최소화하여야 할 것이다. 이와 함께 재판장등은 사건 내용을 철저히 파악하여 석명준비명령을 하는 등 가급적 최소한의 기일에 모든 쟁점 정리가 마쳐질 수 있는 여건을 조성하도록 노력하여야 한다.

또한 쟁점정리과정에서 추가 증거조사의 필요성이 제기되어 감정 등 새로운 증거조사를 시행하게 되는 경우가 생길 수 있다. 이때 감정 등을 위하여 상당한 시간이 소요될 것으로 예상되는 반면 그 결과가 도착하기 전에는 쟁점정리를 완료할 수 없는 사정이 있다면, 다음 쟁점정리기일을 지정하기보다 추후 지정으로 하는 것도 고려할 수 있을 것이다. 그러나 이 경우에는 사건처리가 방치되지 않도록 유의하여야 한다.

속행된 변론준비기일도 첫 변론준비기일과 같은 방식으로 진행한다. 다만 기일의 진행에 앞서 이전 기일의 결과를 간략히 고지함으로써 재판장등이 사건의 쟁점을 제대로 기억하고 있음을 보여주고, 특히 당사자 본인이 처음 출석한 경우 그동안의 진행 경과를 알 수 있도록 하여 줌이 바람직하다.

한편 기일을 변경하는 때에는 바로 당사자에게 그 사실을 알려야 한다(민소규 42조 2항). 당사자가 불필요하게 변경된 기일에 출석하는 것을 방지하기 위한 것이다. 당사자에게 고지하는 방법은 전화번호·팩시밀리번호 또는 전자우편주소 등의 연락처를 활용하는 간이한 방법이 적당할 것이다.

(2) 변론준비기일의 종결, 재개

(가) 종 결

재판장등은 변론의 준비를 계속하여야 할 상당한 이유가 있는 때를 제외하고는 ① 사건을 변론준비절차에 부친 뒤 6월이 지난 때, ② 민사소송법 280조 1항에 의하여 미리 고지된 기간 이내에 준비서면 등을 제출하지 아니하거나 증거신청을 하지 아니한 때, ③ 당사자가 변론준비기일에 출석하지 아니한 때에는 준비절차를 종결할 수 있다(민소 284조 1항). 한편 사건을 변론준비절차에 부친 뒤 4월이 지난 때에는 즉시 변론준비기일을 지정하거나 변론준비절차를 종결하여야 한다(282조 2항). 따라서 재판장등은 서면에

의한 쟁점정리절차가 끝난 후 가능한 한 빨리 변론준비기일을 열고, 특별한 사정이 없는 한 1회의 변론준비기일에 쟁점정리가 마쳐질 수 있도록 노력하여야 할 것이다.

변론준비기일에 쟁점정리가 완결되면 재판장등은 변론준비절차를 종결한다. 변론준비절차의 종결은 변론준비기일에 재판장등이 하는 소송지휘에 관한 재판이고 서면으로 작성하지 아니한 재판이므로 이를 변론준비기일조서에 적어야 한다. 재판장등은 변론준비기일을 종결하는 경우 당사자의 의견을 들어 변론기일을 미리 지정할 수 있다(민소 284조 2항, 민소규 72조 2항).

변론준비기일에 쟁점과 증거를 정리한 결과 추가적인 증인신문 등 증거조사의 필요 없이 바로 변론을 종결할 수 있는 상태에 도달하는 경우도 있을 수 있다. 이와 같은 상황이 처음부터 예상되는 경우라면 애당초 쟁점정리를 위한 기일을 변론준비기일 방식으로 운영하지 않는 것이 바람직하다. 다만 변론준비기일을 진행한 결과 사실관계에 대한 양측의 인식이 일치되어 신청한 증인의 신문이 필요 없게 된 경우도 생길 수 있다. 이 경우 양쪽 모두 출석하였다면 변론준비기일을 종결함과 동시에 그 날을 바로 변론기일로 정한 다음 합의부 구성원의 참여 하에 변론기일을 열어 바로 변론을 종결하는 방안도 활용할 수 있다.

(나) 재 개

재판장등은 변론준비기일을 종결한 후에 변론준비를 계속할 필요가 있다고 인정하면 변론기일이 열리기 전에는 변론준비절차를 재개하여 다시 변론준비기일을 지정할 수 있다(민소 286조, 142조). 이때 기일의 차수는 재개 전의 기일에 연속하는 것이 되며, 변론재개결정에 준하여 결정서를 작성하여 기록에 첨부함이 타당하다. 또한 재판장은 특별한 사정이 있는 때에는 변론기일을 연 뒤에도 사건을 변론준비절차에 부칠 수 있으므로(279조 2항), 변론준비절차를 종결한 후에 변론기일을 진행하는 과정에서 새로 제기된 쟁점에 관하여 변론준비절차를 거쳐야 할 부득이한 사정이 생긴 때에는 다시 변

론준비절차에 부칠 수 있다. 이 경우 변론기일 전후의 각 변론준비절차는 형식상으로는 별개의 것이지만, 같은 사건의 변론준비를 위한 목적으로 행해지는 절차라는 점에서 뒤의 변론준비절차에서 여는 변론준비기일의 차수는 앞의 변론준비절차에서 열었던 변론준비기일의 차수에 연속된다고 보아야 한다.

사. 변론준비기일 종결의 효과(실권효)

(1) 실권효 일반

‘충실한 심리’를 통한 ‘신속한 권리구제’는 민사소송의 목표이나, 위 두 가지 목표는 상충할 여지가 많다. 민사소송법은 소송촉진을 위한 여러 규정을 두고 있는데, 여기에서 의도하는 촉진은 심리의 충실을 희생하는 단순한 심리기간 단축을 의미하는 것이 아니라, 의도적인 지연이나 무성의, 준비부족 등으로 인한 합리적인 이유 없는 절차지연을 막고자 하는 것이며, 이를 위한 대표적인 수단이 바로 실권효 제도이다.

현행 민사소송법은 실기한 공격방어방법의 각하 규정(민소 149조)과 재정기간 제도에 따라 부과되는 실권효 규정(147조)을 변론준비기일에 준용하는 외에도, 변론준비기일 종결의 효과로서 인정되는 실권효 규정(285조 1항)을 별도로 덧붙여 실권효 제도를 강화하고 있다. 민사소송규칙은 이를 뒷받침하기 위하여, 당사자는 법원의 변론 집중을 위한 노력에 협력하여야 하고(민소규 69조 2항), 주장과 증명을 충실히 할 수 있도록 사전에 사실관계와 증거를 상세히 조사하여야 한다(69조의2)고도 규정하고 있다.

적시제출주의와 실기한 공격방어방법의 각하 및 재정기간에 관한 자세한 설명은 제21장(변론) 참조.

(2) 적용범위

변론준비기일이 종결되기 전에 제출하지 아니한 공격방어방법은 원칙적으로 다음의 예외 사항에 해당하지 아니하면 그 뒤의 변론에서 제출할 수 없

다(민소 285조 1항, 3항).

- ① 그 제출로 인하여 소송을 현저히 지연시키지 아니하는 때
- ② 중대한 과실 없이 변론준비절차에서 제출하지 못하였다는 것을 소명한 때
- ③ 법원이 직권으로 조사할 사항인 때
- ④ 소장 또는 변론준비절차 전에 제출한 준비서면에 적힌 사항인 때(변론준비절차에서 철회되거나 변경된 때에는 그러하지 아니하다)

‘변론준비기일’의 종결효과로서 실권효를 인정하는 것이기 때문에, 변론준비절차에 부쳤지만 ‘서면에 의한 변론준비절차’를 거친 후에 변론준비기일을 열지 아니한 채 바로 변론준비절차를 종결하고 변론기일을 지정한 경우에는 위 규정에 의한 실권효를 적용할 수 없다.

(3) 절차 및 효과

실권효가 엄격하게 적용되지 아니할 경우 기일의 분산과 주장·증거의 지연 제출이 초래될 수 있다. 다만 실무상으로는 실권의 제재를 가하는 것이 소송의 동태적·발전적 성격에 비추어 당사자에게 가혹할 수 있으므로 그 적용에 신중을 기하고 있다. 실무상 실권효의 적용을 적극적으로 고려하는 경우로는 당사자가 실권효 적용의 예외조항에 해당한다고 볼만한 합리적인 사유를 제시하지 못하고 상대방 당사자가 실권효 적용을 강력히 주장하는 경우, 쟁점정리와 절차협의를 마친 후에 명백히 새로운 공격방어방법을 제출한 경우, 부당한 소송지연 의도가 명백한 경우, 반복된 석명준비명령에 정당한 이유 없이 불응하는 경우 등을 들 수 있다.

실권효를 적용하고자 할 경우에는 그 전제로서, 변론주의 원칙을 손상하지 않는 범위 내에서 필요한 사항에 대하여 보다 적극적인 석명과 증명추구를 함으로써 당사자가 예상하지 못한 결과가 발생하지 않도록 배려할 필요가 있다. 석명준비명령이나 조서 기재 등을 통하여 기록상 실권효를 적용하는 이유 내지 근거를 분명하게 표시하여 놓는 것이 필요하며, 이 점은 특히 실권효의 명확한 기준 설정과 당사자의 예측가능성 보장을 위해서도 중요하다.

실권효를 적용할 여지가 있다고 판단되는 경우에도 일단 당사자에게 그 예외규정에 해당하는 사유를 소명할 기회를 준 후 이를 참고로 실권효의 적용 여부를 결정하는 것도 고려할만 하다.

실권효를 적용하는 경우 “민사소송법 제285조 제1항에 따라 피고의 소멸시효 주장을 각하한다.”와 같은 방식으로 별도의 결정서를 작성하거나 조서에 기재하고 당사자에게 고지할 필요가 있다.

제1심의 변론준비절차는 항소심에서도 그 효력을 가지므로(민소 410조), 변론준비기일 종결의 효과(실권효)는 항소심까지 그대로 유지된다.

제5절 변론기일의 운영

1. 총 설

가. 개 요

(1) 변론기일의 의의와 중요성

변론기일은 변론을 목적으로 지정·실시되는 기일이다. 변론이라는 말은 여러 가지 의미로 쓰이지만, 넓은 의미로는 법원 및 당사자가 기일에 말로 하는 소송행위를 총괄하는 개념이고, 좁은 의미로는 그중 당사자의 변론(신청과 이를 이유 있게 하는 진술)만을 가리킨다. 후자의 변론은 당사자가 공개된 법정에서 재판부와 상대방에게 구술로 주장하는 내용을 제시하고 상대방은 이에 대하여 반박하는 과정을 뜻하게 된다.

당사자는 소송에 대하여 법원에서 변론하여야 한다(민소 134조, 필요적 변론). 다만 결정으로 완결할 사건에 대하여는 법원이 변론을 열 것인지 아닌지를 정한다). 따라서 소송당사자가 자기의 주장사실을 서면에 기재하여 법원에 제출하였더라도 변론에서 이를 진술하지 아니한 이상 당해 사건의 판단자료로 삼을 수 없다(대법원 2001. 12. 14. 선고 2001므1728, 1735 판결). 또한 판결